

臺灣法學發展史及其省思*

王泰升**

摘 要

臺灣於1895年之後，方因新來的日本統治者已繼受現代法制及法學，而有可能發展現代法學知識。日治前期因配合日本帝國對臺灣採取特殊統治主義，發展出關心臺灣在地法律慣行的「舊慣法學」；但在統治政策轉向「內地延長」的日治後期，在臺灣的法學僅僅是作為戰前日本法學的一個分支。例如1928年所設的臺灣第一所現代法學教育機構：臺北帝大政學科，即是以日本法律及現代法學理論的研究為主，少有生產與殖民地臺灣或臺灣人有關的法學知識。雖從1920年代起已出現以現代法學知識，維護臺灣人主體性及權利的「臺灣人法學」，但其幾乎被排除於臺灣學術界之外，其實臺灣人在日治時期根本就很少能踏入法學界。至日治晚期，臺灣的法學更是跟隨著二次大戰而走向法西斯化。

* 本文有許多內容曾刊載於：王泰升，四個世代形塑而成的戰後台灣法學，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1367-1428（2011年）、王泰升，殖民現代性法學：日本殖民統治下臺灣現代法學知識的發展（1895-1945），政大法學評論，130期，頁199-255（2012年）、王泰升，四個世代形塑而成的戰後台灣法學，收於：台灣法學會台灣法學史編輯委員會編，戰後台灣法學史（上冊），頁1-66（2012年）。在此欲從19世紀末現代法學的來到臺灣開始，不間斷地論其迄今的發展歷程，故以之為敘事架構而進行鋪陳。原發表於中央研究院法律學研究所主辦，「2014兩岸四地法律發展」學術研討會（2014年6月18-19日），會後再為修改，包括增補其後所出版的論著。在註釋的參考文獻及其格式上，感謝臺大法律學院博士生王志弘做最後的校對。
責任校對：林庭伊、鄧婉伶。

** 國立臺灣大學法律學院臺大講座教授、中央研究院臺灣史研究所暨法律學研究所合聘研究員。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/02114171.pdf>。



戰後臺灣，改為施行民國時代中國所發展出的「中華民國法制」。此時所形成的臺灣第一代法學者，大多數係承襲民國時代中國法學經驗的外省族群，僅少數是接續日治時期臺灣法學經驗的本省人族群。法學內涵上以關於中華民國法條的釋義為主，但法學者不問族群或職業背景，均相當受戰前日本法學影響。1960年代中期以後，學院內的第二代法學者逐漸帶回戰後歐陸與日本傾向於自由民主的法學內涵，婉轉地批判國民黨主政下同樣具有法西斯色彩的法學，並藉以深化既有的法釋義學。於1980年代中期之後，加入了第三代法學者。在1990年代臺灣自由化與民主化浪潮中，法學者強化其立法論上研究，甚或積極主導立法，且和其他學門的合作與對話逐漸增多，學術表達方式也呈現多樣化。於2000年代，再加入第四代法學者。臺灣的法學界已走出單純的繼受外國法學理論的巢臼，而採取多源且多元的研究途徑，處理在地的法律議題，並向國際學界表述臺灣的法律經驗。

總之，源自近代西方的法學知識體系，自19世紀末起由分別來自戰前日本、民國中國的政權攜入臺灣，故存在於臺灣的法學知識起初非為臺灣而建構。但臺灣本地法學者在吸收由日中兩國學者帶入的法學知識後，再繼受來自戰後歐美日本的法學，而形塑出具臺灣特色的法學體系，並持之與國際學界交流。

關鍵詞：法學、舊慣、戰前日本、殖民地、繼受、內地延長、法西斯、戰後臺灣、民國時代中國。

目 次

- 壹、由日本法學者開啟的「舊慣法學」(1895-1922)
 - 一、戰前日本法學及臺灣殖民地法制
 - 二、以歐陸法概念轉譯臺灣固有法
 - 三、舊慣法學沒落但為後代留下史料
- 貳、作為日本法學支流及臺灣人法學者的出現(1923-1945)
 - 一、兩地法制相近以致法學內涵相似
 - 二、以日本內地法律為法學教育核心的臺北帝大政學科
 - 三、日本法律及現代法學理論的研究為主、臺灣在地法律問題為輔
 - 四、法學大眾化的肇始
 - 五、「臺灣人法學」的出現及初試啼聲的臺灣人法學者
 - 六、以跟隨日本帝國的「法西斯化法學」作結
- 參、戰後初期兩源匯合為今之臺灣法學奠基(1945-1949)
 - 一、戰前中國的法制及法學發展經驗
 - 二、大幅移植民國中國小量繼承日治臺灣的法學經驗
 - 三、戰後之初中國自由主義法學的乍現與消逝
 - 肆、動員戡亂戒嚴法制下的承襲與新創(1949-1987)
 - 一、法學者之世代概念及其根據
 - 二、起初欠缺可參考的華文法學文獻
 - 三、戰前學說與戰後自由學風的相遇與交鋒
 - 四、戰後西方法學的繼受及學術發表形式和論壇
 - 伍、自由民主法制下多元與在地化的法學(1987年迄今)
 - 一、與歐美當代自由民主法學理論同步發展
 - 二、多元的法學研究取徑以追求臺灣人民福祉
 - 三、法學論著之經審查及多樣化
 - 四、法學研究活動的國際化
 - 陸、結論：外來學術知識的在地化

壹、由日本法學者開啟的「舊慣法學」(1895-1922)

一、戰前日本法學及臺灣殖民地法制

本文所稱的「法學」，係指探究近代西方基於個人主義、自由主義等所建構之具有現代(modern)意義的法律體系的學問，尤其著重於法理的詮釋、法規範的制定或解釋適用等，故亦可稱為「現代意義的法學」，或簡稱「現代法學」。在此定義下，今之臺灣社會／共同體(在地域上包括臺澎金馬)¹，直到1895年日本領有臺灣，並施行已西方化的日本現代意義法律體系²，始一併將現代法學帶入臺灣社會。按姑且不論在日治之前的清治時期(1683-1895)及鄭治時期(1661-1683)係施行著傳統中國法制，即令曾有來自西歐的荷蘭、西班牙統治者(1624-1662)，也僅施行著前近代的西方法制，故均未引進現代法學³。又，在此欲探究的是法學內涵的演變歷程，故以法學者及其所發表的論著，作為主要的論述根據。各時代的政治情勢、法律制度，乃至於法學教育諸般狀況，雖經常是法學者提出某種法學論述的重要因素，但為聚焦於主題，

1 在此係從當今在臺灣的生活共同體(社群)來回溯人們的歷史，故包括了現今在同一個國家的實證法底下的臺澎金馬，但金、馬在歷史上並未與臺、澎同樣自1895年起為日本所統治。

2 日本帝國並沒有將其存在於日本內地的法律制度完全施行於臺灣，於不同的時代，在怎樣的範圍內日本將其已西方化的法律制度施行至臺灣，筆者曾以專文討論之，故此不再詳述，請參見王泰升，台灣日治時期的法律改革，修訂2版，頁65-129(2014年)。

3 參見王泰升，台灣法律史概論，4版，頁5-6、8-10、23-31、35-36、55-56、77(2012年)。傳統中國存在著對律例等官府成文規定應如何制定或執行予以解說的學問，或可稱之為「律學」，但其有別於在此所探究的法學，猶如傳統中國固然有用以治病的中醫／漢醫，但其不同於今稱現代醫學的西醫，況且傳統中國法與近代西方法之差異，不僅僅是規範技術的面向，還及於價值的選擇或利益的偏好，故相關學問的內涵大相逕庭。至於荷蘭人是否將其於17世紀當時所發展出來的法理論，某程度帶入或運用於其在臺灣38年的統治，值得未來進一步考察。

將僅僅在詮釋法學發展所必要的範圍內才論及。

日治臺灣有其特定的族群分類。當時在臺灣人口中占絕對多數（95%-90%）的是國家法上的「本島人」，即社會上所稱的「臺灣人」，包括了漢族移民（內含福佬、客家兩個漢人族群）以及原住民族中被漢化的平埔族人。此外即原住民族中，因未漢化故被漢族移民乃至日治時期國家法稱為「生蕃」、「蕃人」、「高砂族」的高山族原住民族，其人數相對甚少（3.7%-2.5%）。其第三類是，在臺灣總人口數中亦很少（1.3%-6.0%），但在政治及社會上均屬優勢族群之國家法上的「內地人」，亦即在臺灣屬殖民民族的「日本人」⁴。日治時期最早出現在臺灣斯土的現代法學，即是由這群來臺灣進行殖民統治的日本人所帶進來的。

在此因而須先簡述日治時期掌控臺灣政局的日本人，在來臺灣之前已擁有怎樣的法制及法學經驗。日本明治維新後不久，為廢除包括領事裁判權在內的不平等條約，並建構現代型政府組織及發展資本主義經濟，即著手編纂內容與西歐相同的現代化法典。日本先以法國為典範，再受到德國法影響，逐步進行刑法典、刑事訴訟法典、民法典和商法典、民事訴訟法典、憲法典的編纂，雖民商法典因發生論爭而遲至1898年、1899年施行，但在日本領有臺灣的1895年，以仿效近代歐陸法系國家之法律為內涵的日本「六法體系」（前述五種法典加上行政法合稱為「六法全書」），幾已確定⁵。因此在整個明治法律改革中，極少考量將日本各地的習慣納入國家法律中⁶，而毋寧希望以西歐法作為全國國民一致遵行的準繩，儘速將

4 參見姉齒松平，本島人ノミニ關スル親族法並相續法ノ大要，頁7、11（1938年）；陳紹馨，臺灣的人口變遷與社會變遷，頁96-97（1979年）。

5 參見山中永之佑等著，堯嘉寧等譯，新日本近代法論，頁50-58（2008年）。

6 屬於例外的是，由於在民法典論爭中有一派認為應考量舊慣，故在1896年制定的日本民法中規定了沒有具體內容的「入會權」。法院判決例也曾脫逸民法典上規定，而承認日本固有的「根底當」（最高限額抵押）。參見山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁251-253。

封建的日本改造成內部具有高度均質性的「國族國家」(nation-state)。若純從法律技術面而言，其實亦可如英國法律史所示，從日本固有的習慣發展出具有全國一致性的「普通法」(判例法)，但為顧及燃眉之急的外交上需求，抄襲西歐的法典，並透過歐陸法系之法學概念的操作，將成文法上規定解釋適用於個案，乃是最省事又省時的作法⁷。

隨著法典的整備，同樣來自西歐的法釋義學成為明治時代日本法學界主流。現代意義的法學對日本也是全新之物，依循從「法典繼受」到「學說繼受」的路徑，伴隨西歐型法典的制定，近代西歐的法學被全面地引進明治時代日本，且成為一門用以解釋國家法律之意涵的實用之學，例如民法學即以德國的概念法學為根據，而加以體系化。法學教育之走向官僚養成制度，更使法學窄化為「官僚法學」。由於帝國大學教授幾乎獨占了國家官僚考試的內容，這些教授們所醉心或者說所壟斷的西歐法學理論，制約了當時日本法學的內涵，使得法學與現實社會或傳統中下階層的文化脫節。例如，作為完成德國概念法學之一員的鳩山秀夫，其著作之所以受歡迎，即因其「很擅長書寫可以立刻被引用為審判理由的名言佳句」⁸。

然而在日本帝國內以作為特定的政治共同體／政治單元之所謂「殖民地」的身分登場的臺灣⁹，卻意外地出現了採取「尊重舊慣」

7 亦參見 Dan Fenno Henderson, *Law and Political Modernization in Japan*, in *POLITICAL DEVELOPMENT IN MODERN JAPAN* 387, 432-33 (Robert E. Ward ed., 1968).

8 參見山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁378-380、386；福島正夫，岡松參太郎博士の台湾旧慣調査と、華北農村慣行調査における末弘嚴太郎博士，收於：戒能通厚編，福島正夫著作集（第六卷）——比較法，頁390（1995年）。

9 「殖民地」的概念源自西方文明，就如西班牙和葡萄牙在中南美洲的殖民地，或英國和法國在北美洲的殖民地，其係一個政治單元，而在政治、經濟上從屬於殖民母國的控制，但亦有機會擺脫之，而成為在國際法上與母國平等的主權獨立國家。不過，日本帝國在法律制度上從不稱臺灣為「殖民地」，而是稱為「新附領土」或「外地」。

而非與日本內地一致的法律制度。日治之初遭臺灣人前仆後繼地武裝反抗，使明治政府領悟到臺灣猶存在著種族文化上與日本人有一道鴻溝的臺灣人，故宜先參考西方強權的殖民地統治經驗，來治理這塊法律上所稱的「新附領土」或「外地」。於是在殖民地臺灣，總督擁有臺灣地域的行政權與軍事權（但1919年後不再擁有軍事權）、概括的委任立法權（又稱「律令制定權」），以及司法行政監督權（但不含審判權）。並對於彰顯統治高權的政府組織及運作、刑事制裁等，堅持實施明治政府已普遍施行於日本全國的現代式制度，惟去除當中不利於威權統治的成分；對於屬私法領域的民商事事項，則暫時先原則上依被殖民者自身的習慣規範加以處理，以免其全面反抗，但統治上有必要時仍強行介入¹⁰。

因此，於至1922年12月31日為止的日治前期，在前述特殊的在臺憲政體制底下，殖民地臺灣的民商事法係採「複數法制」。簡言之，在臺日本人及中國人以外的外國人，依自1898年7月16日開始生效的日本民法典和隔年生效的商法典，若民商事事項僅涉及臺灣人及中國人則依「舊慣」；然關於土地的權利，則縱令涉及日本人或外國人，亦不依日本民法物權編，而依舊慣，只不過就土地權利亦不乏優先於舊慣的某些民事特別法（例如1905年的《臺灣土地登記規則》）。按上揭制定法中所稱「舊慣」之內涵，係由司法或行政機關於個案中為認定，故相當程度等於是類似「判例法」（case law）的方式，以制定法（律令）為直接法源，而全面地將臺灣人社會中的習慣，轉化為歐陸法系國家法上「習慣法」（成為間接法源）¹¹，這是明治政府於決定繼受西方法時在日本內地所不採取的模式。在臺灣殖民地還相當大的程度延續行政、司法不分的臺灣人「舊慣」，而於1904年正式地建立由地方行政機關（調停官）強力進

10 參見王泰升（註2），頁66-81、94-104；王泰升（註3），頁127-132。

11 從歐陸法系的法源論所衍生的「習慣法」概念，參見王泰升，論台灣社會上習慣的國家法化，臺大法學論叢，44卷1期，頁4-8（2015年）。

行民事爭訟調解，以及由地方行政機關（警察官）裁斷輕罪的犯罪即決等日本內地所無程序，並均沿用至日治結束¹²。

惟不管是為了來臺統治的日本官僚的方便，或配合已現代化的日本國家法制，甚或追求將臺灣人同化成日本國族一部分的政治目標，上揭「舊慣」都須依從屬於「全國國民一致」的前揭日本法學內涵予以詮釋，因而發展出本文所稱的「舊慣法學」。也因如此，自1898年起的8年間、奠定日本在臺灣統治基礎的兒玉源太郎總督與後藤新平民政長官，才會在1899年12月囑託京都帝國大學教授岡松參太郎主持臺灣舊慣調查事業¹³。蓋後藤新平認為對於日本人所不熟悉的臺灣舊慣，不能僅憑在臺一般官吏的觀察或蒐集，而必須經過專家的研究分析與整理，以讓所有日本人官員都能輕易地明瞭；且為此，實有成立特設機關的必要¹⁴。

二、以歐陸法概念轉譯臺灣固有法

（一）岡松參太郎的《臺灣私法》

日本政府為調查臺灣舊慣，即於1901年10月依勅令第169號特別設立了「臨時臺灣舊慣調查會」（以下簡稱「舊慣調查會」），並由曾至德國留學、時任京都帝國大學法學部教授的岡松參太郎主導¹⁵。如前所述，岡松參太郎於1899年即受後藤新平之邀來臺展開

12 以上的相關條文及其內容，參見王泰升（註3），頁213-216、277-282、291。

13 後藤新平批評過去的臺灣統治「無為無策」，欠缺「科學的殖民政策」，強調「生物學的殖民政策」；必須立基於生物學的基礎之上，熟知該土地的民俗、習慣，才得施行適當之政策。且其參考英國經營印度，以及日本本土法典編纂而達到國家統一效果的經驗，認為「法制確立」乃是經營臺灣的基礎。參見山根幸夫，臨時台灣旧慣調査会の成果，收於：論集——近代中国と日本，頁80（1976年）；鄭政誠，臺灣大調查：臨時臺灣舊慣調查會之研究，頁87（2005年）。

14 參見後藤新平，臺灣經營上舊慣制度の調査を必要とする意見，臺灣慣習記事，1卷5號，頁27-28（1901年）；後藤新平，臺灣經營上舊慣制度の調査を必要とする意見，臺灣慣習記事，1卷6號，頁33-35（1901年）。

15 舊慣調查會設立之初，根據調查會規則分為兩部，第一部負責法制之舊慣調

土地舊慣調查事宜（任職臨時臺灣土地調查局）。1900年其根據對臺北地區所為的土地習慣調查，編寫《臺灣舊慣制度調查一斑》，該書不但作為舊慣調查的範本而散發至全臺各單位以供參考，還出版英譯本，將之推廣至國際學界¹⁶。以此為基礎，舊慣調查會自1901年起，陸續以「臺灣私法」為名出版調查報告書，並於1910年出版總結性的第三回報告書，此即通常所稱的《臺灣私法》¹⁷，展現費時10年的舊慣研究成果。

「舊慣」雖如前所述乃是日治前期國家法上的用語，但制定法並未就此為立法上定義，故欲對舊慣進行整編的岡松參太郎必須先從法學觀點賦予特定意涵，其認為「舊慣」即是舊政府時代所施行之法律。詳言之，「舊慣」是指臺灣在舊的清朝政府統治時期，從現代法的觀點具有法律上意義的習慣；其不僅表現於不成文的習慣規範，亦被記載於如《大清律例》等官府成文規定上，惟清治臺灣漢人社會裡被普遍遵行、卻違反清朝官府成文規定的習慣，仍被承認為日治國家法上的「舊慣」。又，日治時期雖因制定法上表示「依舊慣」而可不依日本其他民事法律，但舊慣本身違反日治時期國家所認定的公共秩序、善良風俗，則仍將否定其在國家法上的效

查，由岡松參太郎擔任部長；第二部負責農工商經濟之舊慣調查，由愛久澤直哉擔任部長。1910年第二部廢止，改設第三部立法部門，部長亦由岡松兼任。參見山根幸夫（註13），頁84-86。

16 參見井出季和太，臺灣治績志，復刻版，頁415（1997年）；鄭政誠（註13），頁98-99。《臺灣舊慣制度調查一斑》的英譯本為：SANTARO OKAMATSU, PROVISIONAL REPORT ON INVESTIGATION OF LAW AND CUSTOMS IN THE ISLAND OF FORMOSA (1971)。

17 舊慣調查會之報告書共有三回。第一期調查是針對臺灣北部的調查，自1901年至1903年，於1903年出版第一回報告書；第二期調查是臺灣南部的調查，自1903年至1905年，於1906年至1907年出版第二回報告書；最後則是臺灣中部的調查，自1906年至1907年，並在上述所有調查結果的基礎上重新編輯，於1910年至1911年刊行第三回報告書。《臺灣私法》共計3卷（6冊），另有《臺灣私法附錄參考書》共計3卷（7冊）。參見岡松參太郎，敘言，收於：臨時臺灣舊慣調查會編，臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書——臺灣私法（第一卷上），敘言頁2-5（1910年）；山根幸夫（註13），頁89-90。

力¹⁸。據此，岡松參太郎所欲調查者即是臺灣漢人社會延續自清治時期的「固有法」，其於日治之初仍具有「活生生的法」(living law，或譯為「活法」)的性格。

這些臺灣漢人的固有法，其實是以近代歐陸法學概念轉譯後的產物。按舊慣調查事業的目的，誠如岡松參太郎所述，「一為查明臺灣舊慣之實際情形，以應目前行政及司法上之需要，提供設施資料為目的；二為遂行中國法制的根本性研究、完成學理性編述，以作為日後臺灣立法之基礎¹⁹。」而當時日本在臺灣施展行政、司法、立法作用時，係本於以近代歐陸法制及法概念為基調的整個帝國法律體制，故關於「舊慣」的知識必須與該帝國法律體制具有「相容性」。進而在行政及司法上進行「法適用」時，依邏輯上的三段論法，將以歐陸法律概念所表達之存在於「舊慣」中、具有普遍適用性的「規則」(rule)，適用於行政（例如土地調查）或司法（例如民事訴訟）上的個案事實，以得出該個案的法律判斷。或在立法上，將從「舊慣」中所發現的一般規範予以成文化／法典化，讓現代型的行政或司法機關得將其適用於個案。因此，《臺灣私法》的編排體例區分為不動產、人事、動產、商事及債權四編²⁰，雖與日本的歐陸式民、商法典有別，但兩者大同小異，均是本

18 岡松參太郎，臺灣現時の法律，臺灣慣習記事，3卷1號，頁7-9（1903年）；臨時臺灣舊慣調查會編，臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書——臺灣私法（第一卷上），頁48-49（1910年）。按日本的《法例》於1898年即因勅令之指定而在臺灣發生法律效力，依其第2條之規定，以「不違反公共秩序與善良風俗」作為前提，若「依法令規定所承認」或「關於於法令中未規定的事項」，「習慣」即「與法律有同一效力」，亦即成為可當做法源的習慣法。由於臺灣的律令（與法律具有同一效力）已規定「依舊慣」，故在臺灣地域存在著可作為法源的習慣法。於日治前期，日本民法典因未經勅令指定在臺灣生效，而在臺非屬法源。

19 岡松參太郎（註17），敘言頁1。

20 依屬於第三回調查報告書的《臺灣私法》，其編、章、節的目錄（係原文，其大量使用日文漢字，乃當時日本法律與法學的常態）如下：

第一編 不動產：第一章總論（略）、第二章不動產權：第一節業主權，第二節役權，第三節購權，第四節典權，第五節胎權、第三章不動產權ノ特別ナル

於德國的概念法學而為體系化的結果。且以作為歐陸法學核心的「權利」觀念進行類型化時，有意地配合日本民法上的分類基準²¹。

岡松參太郎所形塑的舊慣法學，兼有學術性與政治性。於《臺灣私法》剛出版不久的1912年，富有盛名的法學家穗積重遠曾稱讚該書為臺灣私法之大全，福田德三博士亦肯定此為具有高度學術性的作品，足供私法學、法制史學，乃至中國社會史或經濟史研究者參考²²。日本於日俄戰爭後在中國東北進行「滿洲舊慣調查」時，大體上是沿用岡松參太郎在臺灣所研發的舊慣法學²³；不過，日本於二次大戰期間在中國為「華北農村的法慣行調查」時，因並無在行政司法或立法方面準據法律上習慣的政策上要求，故主導者末弘嚴太郎博士改以法社會學的角度，探究人民的法意識或法社會生活實況。這也使得戰後福島正夫於1958年時，雖指出《臺灣私法》的

物體（略）、第四章不動產權ノ特別ナル主體（略）。

第二編 人事：第一章人（略）、第二章親族：第一節總說，第二節服制，第三節家，第四節親族會、第三章婚姻：第一節總說，第二節正式ノ婚姻，第三節變例ノ婚姻，第四節蓄妾、第四章親子：第一節總說，第二節實親子，第三節養親子，第四節養子ノ離縁、第五章託孤（略）、第六章相續：第一節宗祧承繼，第二節財產承繼，第三節遺言。

第三編 動產：第一章總說（略）、第二章物主權：第一節物主權ノ性質，第二節動產ノ種類，第三節物主權ノ得喪，第四節共同物主權、第三章當權（略）、第四章占有。

第四編 商事及債權：第一章商事總論（略）、第二章商人（略）、第三章商業使用人（略）、第四章債權總論：第一節債權ノ物體，第二節債權ノ效力，第三節債權ノ讓渡，第四節債權ノ消滅，第五節債權ノ擔保，第六節債權ノ原因、第五章債權各論（略，共計二十節）、第六章合股（略）、第七章匯票及憑單（略）、第八章海商（略）、第九章倒號（略）。

21 例如，《臺灣私法》就將舊慣上「贖」之關係，依借用目的之不同，區分為「贖佃」、「贖地基」、以及「贖地」，即很可能是受到日本歐陸式民法典上「永小作權」、「地上權」、以及「賃貸借」之分類影響。

22 參見山根幸夫（註13），頁92-93。

23 1906年6月，岡松參太郎擔任滿鐵理事並擔任調查部部長，故臺灣的舊慣調查經驗對於滿洲有一定的影響，滿洲舊慣調查報告書亦承認這點。滿鐵調查部的「調查事項細目條」，即與《臺灣私法》相近似，不過滿洲調查並無協助殖民地行政以及立法的政策上目的，不需要探究全部的法律上習慣，而僅是為了保持滿鐵此一特殊會社的利益而已。參見福島正夫（註8），頁408-409。

調查方針及綱目符合後藤新平的施政需要、使用比較法的方法、以現代法概念為規準進行分析整理、以文書而非口述為主要參考資料等之外，但批判岡松參太郎將西歐型法律概念，強行適用於屬傳統中國法系的習慣，並不妥當²⁴。事實上岡松參太郎當年即已意識到這個方法論上的問題，但其認為既然日本已以歐陸法建構法律制度，就不能不以歐陸法概念說明臺灣的制度與觀念，且就像德國人以羅馬法概念及理論來詮釋日耳曼固有法，也可以用淵源自羅馬法的歐陸法概念來詮釋臺灣的固有法²⁵。換言之，岡松參太郎固然是依從當時日本學界盛行的德國概念法學進行舊慣調查，但亦瞭解這是配合臺灣在司法、行政、立法上使用「舊慣」的殖民地統治政策所必需的。他甚至想藉著在臺灣成功地為舊慣民事立法（融合臺灣舊慣與歐陸法制，參見後述），凸顯日本民法典一味抄襲西歐法制之不智²⁶。

（二）《臺灣慣習記事》與《臺法月報》「慣習」專欄

須對「舊慣」內涵做出有權解釋的法院，基於業務上需要也有一群臺灣舊慣的研究者。於1900年，擔任覆審法院院長的鈴木宗言催生了由總督為會長的「臺灣慣習研究會」，其會員絕大多數為日本人官吏，其中又以司法官居多，並發行《臺灣慣習記事》²⁷。

24 參見福島正夫（註8），頁404-405；西英昭，『臺灣私法』の成立過程——テキストの層位学的分析を中心に，頁4（2009年）。

25 參見岡松參太郎，大租權の法律上の性質，臺灣慣習記事，1卷1號，頁5-8（1901年）；吳豪人，岡松參太郎論——殖民地法學者的近代性認識，收於：林山田教授退休祝賀論文編輯委員會編，戰鬥的法律人：林山田教授退休祝賀論文集，頁545（2004年）；王泰升（註2），頁316。

26 參見吳豪人（註25），頁546-547。認為應以在地的習慣為基礎，制定出在社會生活中具有實用性的法典的岡松參太郎，是帶著身為法學者的一份理想，而與臺灣殖民地政府合作，進行臺灣舊慣調查及立法，但終究因政治力的轉向而告落空。就此論點，參見王泰升，具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證，頁197、206（2010年）。

27 參見曾文亮，全新的「舊慣」：總督府法院對臺灣人家族習慣的改造（1898-1943），臺灣史研究，17卷1期，頁130-131（2010年）。關於會員人數及職業或

1907年8月，臺灣慣習研究會解散且《臺灣慣習記事》廢刊²⁸，但臺灣總督府法務部所支持的《法院月報》（自1911年1月號起改稱《臺法月報》，發行至1943年11月號），即在《臺灣慣習記事》廢刊後隔月的第1卷第4號（1907年9月）上開闢「慣習」（係日文漢字，相當於今日臺灣華文中的「習慣」）專欄，該專欄一直延續至第13卷（1919年）為止²⁹。

上述刊物或專欄為舊慣法學提供良好的發表園地。《臺灣慣習記事》中刊載各式有關臺灣舊慣的研究與論著，包括由各地判官或檢察官對臺灣地方士紳進行口述訪談的「有志慣習諮問會」的紀錄，亦有對臺灣各項風俗之考察。在法學論著方面，則以舊慣調查會的成員為主力，包括舊慣調查會第一部主任岡松參太郎、舊慣調查會事務囑託山本留藏、舊慣調查事務囑託的小林里平、舊慣調查會補助委員安藤靜、舊慣調查會囑託（後任檢察官）的上內恒三郎³⁰。其他司法官員，例如覆審法院院長鈴木宗言³¹，也偶見發表

種族上背景，參見臺灣慣習研究會，再び本會の博覽會出品に就て，臺灣慣習記事，3卷2號，頁88（1903年）；鈴木宗言，危急存亡，臺灣慣習記事，4卷7號，頁78-79（1904年）。

28 參見鈴木宗言，慣習研究會解散に就て一言す，臺灣慣習記事，7卷8號，頁4-5（1907年）。

29 參見王泰升，撥雲見日的台灣法律史研究，收於：台灣法律史的建立，2版，頁60、63-64（2006年）。

30 參見岡松參太郎（註25），頁4-14；岡松參太郎，大租權の法律上の性質，臺灣慣習記事，1卷3號，頁1-13（1901年）；岡松參太郎，親族相續，臺灣慣習記事，1卷4號，頁25-33（1901年）；岡松參太郎，親族相續，臺灣慣習記事，1卷8號，頁12-24（1901年）；岡松參太郎，親族相續，臺灣慣習記事，1卷9號，頁1-19（1901年）；岡松參太郎，親族相續，臺灣慣習記事，1卷10號，頁18-37（1901年）；山本留藏，臺灣に於て流質となるべき場合，臺灣慣習記事，1卷11號，頁16-31（1901年）；山本留藏，典より生ずる法律關係は果して之を條件付賣買と見るべきや，臺灣慣習記事，2卷8號，頁11-23（1902年）；山本留藏，典より生ずる法律關係は果して之を條件付賣買と見るべきや，臺灣慣習記事，2卷9號，頁6-15（1902年）；山本留藏，典主は債權の關係に於て原典價銀の辨濟請求權利を有するものに非らず，臺灣慣習記事，4卷9號，頁1-13（1904年）；小林里平，清國政府時代に於ける臺灣司法制度，臺灣慣習記事，2卷12號，頁12-28（1902年）；小林里平，清國政府時代に於ける臺灣司

論文。是以整體而言，充滿了岡松式的以歐陸法概念解釋臺灣舊慣。

《臺法月報》「慣習」欄，起初亦延續前述的研究者屬性及其研究取徑³²。不過隨著舊慣立法的草案出現，法學者或辯護士們都選擇在此刊物上發聲。例如就舊慣立法，即有舊慣調查委員兼京都帝國大學教授的石坂音四郎、判官藤井乾助、辯護士山田示元等發表看法³³。對於攸關企業組織及活動的「合股令」，包括瀧野種孝、野

法制度，臺灣慣習記事，3卷2號，頁10-25（1903年）；小林里平，清國政府時代に於ける臺灣司法制度，臺灣慣習記事，3卷3號，頁1-14（1903年）；小林里平，保甲制度，臺灣慣習記事，3卷5號，頁1-15（1903年）；小林里平，保甲制度，臺灣慣習記事，3卷6號，頁1-13（1903年）；小林里平，保甲制度，臺灣慣習記事，3卷7號，頁1-14（1903年）；小林里平，保甲制度，臺灣慣習記事，3卷8號，頁1-16（1903年）；小林里平，保甲制度，臺灣慣習記事，3卷9號，頁13-32（1903年）；小林里平，保甲制度，臺灣慣習記事，3卷11號，頁22-29（1903年）；安藤靜，北部臺灣に於ける共有に關する舊慣，臺灣慣習記事，4卷6號，頁19-29（1904年）；安藤靜，北部臺灣に於ける共有に關する舊慣，臺灣慣習記事，4卷7號，頁14-23（1904年）；安藤靜，臺灣に於ける共有舊慣，臺灣慣習記事，7卷7號，頁1-12（1907年）；安藤靜，臺灣に於ける共有舊慣，臺灣慣習記事，7卷8號，頁26-38（1907年）；安藤靜，北部臺灣に於ける業主權の限界に關する舊慣，臺灣慣習記事，4卷12號，頁11-19（1904年）；安藤靜，北部臺灣に於ける業主權の限界に關する舊慣，臺灣慣習記事，5卷1號，頁15-24（1905年）；上內恒三郎，支那法系の法制及慣習の認めたる財産制，臺灣慣習記事，6卷1號，頁1-7（1906年）；上內恒三郎，支那法系の法制及慣習の認めたる財産制，臺灣慣習記事，6卷2號，頁1-7（1906年）；上內恒三郎，支那法系の法制及慣習の認めたる財産制，臺灣慣習記事，6卷4號，頁1-9（1906年）。

31 參見鈴木宗言，臺灣の舊訴訟法，臺灣慣習記事，1卷2號，頁1-17（1901年）；鈴木宗言，臺灣の舊訴訟法，臺灣慣習記事，1卷3號，頁14-23（1901年）；鈴木宗言，臺灣の舊訴訟法，臺灣慣習記事，1卷4號，頁1-25（1901年）。

32 參見上內恒三郎，本島相續制度の大要，法院月報，2卷10號，頁67-76（1908年）；上內恒三郎，合股の舊慣，法院月報，3卷2號，頁47-56（1909年）；上內恒三郎，合股の舊慣，3卷6號，頁49-65（1909年）；上內恒三郎，合股の舊慣，3卷9號，頁60-68（1909年）；山本留藏，本島土地に關する權利の大要，法院月報，2卷10號，頁37-49（1908年）；小林里平，本島親族制度の大要，法院月報，2卷10號，頁49-54（1908年）；高田富藏，本島婚姻制度の大要，法院月報，2卷10號，頁54-60（1908年）；藤井乾助，本島養子制度の大要，法院月報，2卷10號，頁60-67（1908年）。

33 參見石坂音四郎，臺灣に於ける土人法制定の必要，法院月報，4卷1號，頁45-

津三次郎、長嶺茂、渡部正綱、山田示元等辯護士紛紛發表意見³⁴。雖說《臺法月報》至1919年為止所登載的內容並不以舊慣研究為限，也不時出現探究臺灣殖民地特有法制，或介紹日本內地或外國法制的文章³⁵，但大體上仍以具有一定的舊慣法學意義的論著居多。

如上所述，這些關於臺灣人習慣的法學知識，亦即舊慣法學的內涵，都是由日本人所建構的。此對於臺灣人而言，等於是來自「他族的觀察」，不免帶有日本人主觀的想像；然而這時期的臺灣人連作為「國語」的日語都不太懂，遑論由日語所表達的現代法學。且從事舊慣法學研究之人，多數屬日本在臺的殖民統治者，亦不免使得舊慣內涵朝著對日本殖民統治有利的方向詮釋。如後所述的舊慣相關作品，也有同樣的問題。

（三）《清國行政法》

舊慣法學不僅表現在上述的私法學上，也延伸至公法學，其具體成果即織田萬編著的《清國行政法》。岡松參太郎於《臺灣私法》曾謂，舊慣調查「不以闡明臺灣全島之舊慣制度為已足，追溯其根源，已是中國法制之一斑，期待明瞭南清一帶習慣之大體³⁶。」易

57（1910年）；石坂音四郎，臺灣に於ける土人法制定の必要，法院月報，4卷2號，頁25-35（1910年）；藤井乾助，臺灣の舊慣立法に就て，臺法月報，7卷6號，頁31-35（1913年）；山田示元，舊慣立法に就いて，臺法月報，9卷5號，頁31-43（1915年）。

34 參見瀧野種孝，合股令案に就て，臺法月報，5卷3號，頁37-41（1911年）；野津三次郎，合股令に對する私見，臺法月報，5卷4號，頁44-48（1911年）；野津三次郎，再び合股令案に就て，臺法月報，5卷6號，頁82-85（1911年）；長嶺茂，合股令修正意見，臺法月報，5卷4號，頁48-52（1911年）；渡部正綱，合股令案に就て，臺法月報，5卷5號，頁60-64（1911年）；山田示元，臺灣合股令案に付て，臺法月報，5卷6號，頁76-82（1911年）；山田示元，臺灣合股令案に就て（二），臺法月報，5卷7號，頁60-67（1911年）。

35 該刊物自1907至1919年的目錄，參見中島利郎、宋宜靜編，『台法月報』總目錄，頁23-225（1999年）。

36 岡松參太郎（註17），敘言頁1-2。

言之，若欲完整明瞭臺灣舊時／清治時期的法律制度，不能僅就私法方面進行調查，還需究明行政法規之沿革³⁷，故乃向後藤新平建議調查「清國行政法」，並推薦由同在京都帝國大學任教的織田萬擔綱。後藤新平向織田萬表示唯有「既通曉近世法理且能解讀漢文」的日本人，才可從事中國法制的調查，此乃「日本人的天職」³⁸。於是織田萬自1903年起擔任舊慣調查會囑託，且於1915年出版其主編共計6卷（7冊、索引1冊）的《清國行政法》³⁹；織田萬自己認為「本書編述係預設綱目，就所獲得之材料取捨，務以近世公法之理論為經緯」，亦即在編排與架構上「依現代科學的觀點，予以系統化」，故其調查背後的認識論基礎和方法論，與岡松參太郎並無二致⁴⁰。從該書的目錄⁴¹，可知其和《臺灣私法》同樣是以歐陸法

37 參見山根幸夫（註13），頁94。

38 參見織田萬，臨時臺灣舊慣調查會第一部報告書——清國行政法（第壹卷上），序頁1（1914年）；山根幸夫（註13），頁94-95；坂野正高，織田萬，收於：潮見俊隆、利谷信義編，日本の法学者，頁141（1975年）。日本學者對於中國法制之興趣，也被認為具有「開發」之用意。參見黃丞儀，臺灣近代行政法之生成：以「替現」與「揭露」的書寫策略為核心，1885-1901，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁158（2002年）。

39 協助編纂此書者尚有：狩野直喜、淺井虎夫、東川德治、加藤繁。出版時間分別為：第一卷，1905年5月；第二卷，1910年11月；第三卷，1910年12月；第四卷，1911年2月；第五卷，1911年6月；第六卷，1913年11月；改訂版第一卷上冊，1914年2月；改訂版第一卷下冊，1914年3月；索引，1915年3月。參見山根幸夫（註13），頁95-96。

40 參見織田萬，臨時臺灣舊慣調查會第一部報告書——清國行政法（第壹卷），序頁1（1905年）；該書於1914年改版時，在文字上調整為：「先蒐集分類參考書籍及其他資料，次依照近代法理，預先逐次擬定研究架構，以之為調查的開端」。參見織田萬（註38），序頁2；亦參見黃丞儀（註38），頁160-161。

41 參見山根幸夫，清國行政法解說，收於：山根幸夫編，清國行政法索引，解說頁11-12（1967年）；山根幸夫（註13），頁96-99。《清國行政法》的目錄（係原文）如下：

汎論（1914年改訂版）：第一編 清國行政法ノ淵源：第一章概論，第二章成文法，第三章不文法；第二編 行政組織：第一章概論，第二章皇室，第三章中央官廳，第四章地方官廳，第五章地方自治；第三編 官吏法：第一章概論，第二章文官，第三章武官，第四章官吏ノ分限，第五章官吏ノ權利，第六章官吏ノ義務，第七章官吏ノ責任。

各論：第一編 內務行政（略）；第二編 軍務行政（略）；第三編 司法行政（略）；第四編 財務行政。

系的法律概念展開論述。按《清國行政法》的編排方式，係依據織田萬1910年出版的《行政法講義》；而留學法國的織田萬在《行政法講義》一書中，卻採取德國法學的寫作風格⁴²。

一言以蔽之，織田萬乃是為了滿足殖民統治上的需求，而運用現代意義的法學建構關於傳統中國法的知識。當織田萬以所謂「近世法理」，亦即來自歐陸的法律概念編寫《清國行政法》時，不免會碰上某些清朝的行政制度，無從納入近代西方法律體系的概念中，此時其便自己創造分類填充，以符合其自詡的「系統化」或「科學化」，但織田萬之回頭抄錄清朝的原典，又被後人評論為《清國行政法》其實是以現代風格所書寫的「大清會典」與「會典事例」⁴³。就如同之前所論的岡松參太郎，織田萬之所以用歐陸法概念強行轉譯漢人傳統的官府制度，乃因日本帝國在殖民地立法上，不須與殖民母國一致，而可以考慮將這些被稱為舊慣的官府制度納入已採歐陸法概念的國家法制內，故倘若現代型國家無這項「舊慣溫存」政策，就沒必要沿用此方式創造法學知識。因此必須嚴肅地指出，若從應如實地「理解」傳統中國法的學術立場，使用原不存在於傳統中國／漢族文化的歐陸法概念來理解其內容，實有商榷餘地。然而，岡松參太郎與織田萬聯手，原是為建構殖民地法制，而刻意以歐陸法概念營造的傳統中國法知識，詎知於戰後仍被以探求真實為旨趣的學術界所延續，故此乃後代研究者不思當初學術脈絡而盲從所致。

（四）《臺灣蕃族慣習研究》

由於在臺灣的殖民地統治實務上，擬參酌（非必然依從）其固

42 參見坂野正高（註38），頁135；山根幸夫（註13），頁96；黃丞儀（註38），頁163。

43 參見坂野正高（註38），頁141。

有的習慣來統治高山族原住民族⁴⁴，日本帝國在完成對臺灣的漢人以及被漢化的平埔族人，亦即臺灣人的習慣調查後，轉而探究高山族原住民族的習慣。舊慣調查會在1909年因已完成對漢人舊慣的調查並出版《臺灣私法》，乃設立推動舊慣立法的第三部：立法部，同時在第一部下增設「蕃族科」。蕃族科其後分別出版了《臨時臺灣舊慣調查會第一部蕃族調查報告書》（1913年至1921年，共8冊）、《臨時臺灣舊慣調查會第一部蕃族慣習調查報告書》（1921年至1922年，共8冊），以及《臺灣蕃族慣習研究》（1921年，共8冊）⁴⁵。前二者調查原住民族的語言、風俗習慣、祭典儀式等⁴⁶，偏向人類學的研究方法；後者《臺灣蕃族慣習研究》則是岡松參太郎根據前二者的調查結果，以法學的方法所編纂完成。

岡松參太郎原本認為蕃族調查除了人類學的價值外，其習慣在法學研究上並無助益，故對蕃族調查事業不感興趣⁴⁷，這當然跟日本帝國在國家法上未規定一律依舊慣處理高山族原住民法律事務有一定的關聯性。在日本當時繼受西歐概念法學的氛圍底下，岡松參太郎對於高山族原住民族的習慣，並不視為是一種現代意義的法律規範⁴⁸。但由於其德國老師Josef Kohler的提醒及鼓勵，以及在法學研究上對於母系社會的關心，使岡松參太郎重新認識到高山族原住

44 日本帝國對於臺灣人係依現代法架構下的「律令」承諾其民商事項全然「依舊慣」，但對於高山族原住民卻不願受「依法統治」原則所拘束，故從未以律令明確表示高山族原住民的民商或刑事事項應如何處理，原則上是由蕃務警察參酌其習慣及一切統治上應考量的因素而為個案處分。就此議題，請參見王泰升，日治時期高山族原住民族的現代法治初體驗：以關於惡行的制裁為中心，臺大法學論叢，40卷1期，頁1-98（2011年）。

45 參見春山明哲，法學博士・岡松參太郎と台湾，收於：台灣近現代史研究会編，台灣近現代史研究II，第6號，復刻版，頁206、210-211（1993年）。

46 參見鄭政誠（註13），頁255。

47 參見岡松參太郎，敘言，收於：臺灣總督府蕃族調查會編，臺灣蕃族慣習研究（第壹卷），敘言頁2（1921年）；山根幸夫（註13），頁108。

48 參見福島正夫（註8），頁406。

民習慣的研究價值⁴⁹。雖然在行政司法立法上的實務需求並不那麼高，但基於既有經驗及當時學風，岡松參太郎仍使用歐陸法概念來說明「蕃族」的習慣內涵。特別可以從第一編「蕃族概況」的第六章「法制（總說、刑事慣習、民事慣習）」以及第三編的「親族、家族、家族制、婚姻制」中看到現代法概念的影子⁵⁰。

有關高山族原住民族的「舊慣」研究，雖有助於蕃務警察掌握被統治者的習俗，但在臺灣的殖民地法制上的必要性不高，故一直較偏向於人類學考察或是風俗的調查，而非法學層次的探討。在《臺灣慣習記事》及《臺法月報》「慣習」專欄內，真正稱得上對於高山族原住民族的法學討論，大概僅有1906年至1907年關於「生蕃人之國法上地位」的徵文比賽⁵¹；但其關切的重點是殖民地政府應如何進行統治，而非高山族原住民族應得到什麼樣的法律上保護，故也僅能產出有利於日本殖民者的現代法學知識。

49 參見吳豪人（註25），頁547；山根幸夫（註13），頁109。岡松參太郎將1900年所完成之初步的舊慣調查翻譯為英文而出版後，曾寄贈給Kohler教授，該教授於對此書發表書評時，即指出其欠缺關於原住民族的調查，於1908年兩人見面時，Kohler教授再向岡松參太郎提及此事。然而岡松參太郎當時一直致力於臺灣漢人習慣的調查及舊慣立法草案，直到1916年其在研究法律上妻之地位時，發現蕃族係採母系主義，而認為其習慣在法律史上是珍貴的素材。參見中生勝美，ドイツ比較法學派と台湾旧慣調査，收於：宮良高弘、森謙二編，歴史と民族における結婚と家族——江守五夫先生古稀記念論文集——，頁387-388（2000年）。

50 就《臺灣蕃族慣習研究》目錄，可參見鄭政誠（註13），頁267-268。

51 參見岡野才太郎，生蕃人の國法上の地位，臺灣慣習記事，6卷11號，頁1-13（1906年）；藤井乾助，生蕃人の國法上の地位，臺灣慣習記事，6卷12號，頁1-28（1906年）；安井勝次，生蕃人の國法上の地位，臺灣慣習記事，7卷1號，頁1-27（1907年）。日治後期，也僅有臺北帝國大學教授安平政吉，自1940年起在《臺法月報》發表一系列關於「高砂族犯罪與刑罰」的研究，從法學的角度分析高山族原住民族的刑罰，且不僅探究原住民族固有習慣，亦介紹當時行政機關所採行的統治制度。參見安平政吉，臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷2號，頁1-21（1940年）；安平政吉，臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷3號，頁4-29（1940年）；安平政吉，臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷4號，頁3-18（1940年）；安平政吉，臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷6號，頁1-24（1940年）；安平政吉，臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷7號，頁1-19（1940年）。此系列共有5篇。

三、舊慣法學沒落但為後代留下史料

自日治之初10餘年來舊慣法學的累積，乃是為1909年起至1914年完成的舊慣立法做準備。舊慣調查會第三部立法部自1909年著手自始即決定進行的立法工作，至1914年止，經召開5次「法案審查會」，完成《臺灣民事令》、《臺灣親族相續令》、《臺灣親族相續施行令》、《臺灣不動產登記令》、《臺灣競賣令》、《臺灣非訟事件手續令》、《臺灣人事訴訟手續令》、《臺灣祭祀公業令》，以及《臺灣合股令改正案》等9份律令草案⁵²。以「舊慣立法」為名所完成的這些臺灣民商事法典草案，僅在形式上以臺灣人的習慣為依據，從草案中各條文記明「參照」日本、德國、法國、瑞士、甚或英國，可知其經常仿效近代西方法的規定，且已承襲臺灣殖民地法院及特別民法所為之對臺灣人原有習慣刻意的改造，故在此所謂的「舊慣」絕非清治末期、甚至非日治當時臺灣人的習慣，而毋寧是已融入現代法之理念的民事法典⁵³。若上揭「舊慣立法」的草案正式成為國家制定法上的條文，則爾後臺灣民事法研究重點將是這些條文應如何被解釋適用的法解釋學，而不再是如前所述之應如何調查或在行政司法個案中適用習慣。換言之，法典化將可能是前述舊慣法學褪色的開始。

然而，最終仍是殖民地的政治走向，扼殺了舊慣法學的生機。當時日本內地有一種聲音認為，舊慣的法典化將使得舊慣難以打破，不利於臺灣的「文明化」，但如上所述，現代化的考量業已被納入上揭臺灣民、商法典草案中，所以其真正關切的乃是「同化」或者說「日本化」的問題。按倘若在臺灣殖民地施行上揭與日本內地不同的民商法典，等於宣告臺灣人與日本人在法律上的差異性被

52 參見王泰升（註2），頁323；春山明哲，台灣旧慣調査会と立法構想——岡松參太郎による調査と立案を中心に——，收於：台灣近現代史研究会編，台灣近現代史研究II，第6號，復刻版，頁105（1993年）。

53 其詳，參見王泰升（註26），頁176-194。

固定化且制度化，將不利於文化上及認同上將臺灣人轉變為日本人，亦即「終極統一」的國族國家建構工程。因此，日本內地政府始終不同意臺灣總督府於1914年提出的舊慣立法草案（律令案），待1919年日本帝國的殖民地統治政策確立為「內地延長」政策後，臺灣民商法制改革方向已朝向施行日本民商法典前進。1919年擔任臺灣高等法院院長的谷野格即曾指出，為加速臺灣人（本島人）與日本人（內地人）的同化，法律上的統一乃是有利的手段⁵⁴。1921年法三號的通過提供法制上內地延長的基礎，1922年的勅令第406號和第407號規定自1923年1月1日起，日本內地的民商法典施行於臺灣，只有僅涉及臺灣人的親屬繼承仍「依習慣」⁵⁵。於是，舊慣法學在臺灣已不再為政治正確，而僅在身分法領域得以一息尚存。

當時的法學期刊見證了這項改變。《臺法月報》於1920年尚有高等法院覆審部判官岩澤彰二郎、高等法院上告部判官後藤和佐二，以及臺北地方法院判官有水常次郎等人針對臺灣的「不動產物權」及「墾耕」做出一系列討論⁵⁶。然而從1923年1月1日日本民商

54 參見春山明哲（註52），頁106。

55 相關條文及其內容，參見王泰升（註3），頁130、282-284。同樣依日本《法例》第2條之規定，以「不違反公共秩序與善良風俗」作為前提，若「依法令規定所承認」，「習慣」即「與法律有同一效力」，故由於1922年勅令第407號的「承認」，習慣已與法律有同一效力，而成為臺灣人親屬繼承事項的法源，日本民法典親屬繼承兩編對該等事項不生效力。

56 參見岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，14卷5號，頁4-24（1920年）；岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，14卷6號，頁6-16（1920年）；岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，14卷10號，頁9-16（1920年）；岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，14卷11號，頁7-15（1920年）；岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，15卷2號，頁7-11（1921年）；岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，15卷3號，頁2-6（1921年）；岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，15卷4號，頁6-10（1921年）；岩澤彰二郎，臺灣に於ける不動產物權に付て，臺法月報，15卷5號，頁7-19（1921年）。此系列共有8篇；岩澤彰二郎，未登記墾耕と無登記墾耕，臺法月報，14卷7號，頁1-14（1920年）；岩澤彰二郎，未登記墾耕と無登記墾耕，臺法月報，14卷8號，頁6-16（1920年）；岩澤彰二郎，未登記墾耕と無登記墾耕，臺法月報，14卷9號，頁9-20（1920年）。此系列共有3篇；後藤和佐

法開始施行於臺灣之後，針對臺灣舊慣而進行法學上論述者，僅限於國家法上仍「依習慣」的親屬繼承事項。1923年1月號的《臺法月報》充滿了慶祝民商法施行於臺灣的祝賀文，但曾任職於舊慣調查會的小島由道卻發表了一篇〈關於親屬繼承之習慣〉的文章⁵⁷，彷彿要為舊慣調查事業留下最後一道身影。

然而，此時期舊慣法學的研究成果，卻為後述1990年代崛起的以臺灣為主體的法學研究，留下豐沛的學術資源。當以臺灣斯土斯民為考察對象而撰寫法律史時，前述針對19世紀末20世紀初，或者說「清末日初」臺灣漢人社會具有現代法意義的習慣所為之調查，經盡量從現代法概念予以還原之後，即可顯現臺灣清治晚期的民間習慣的內涵⁵⁸。同樣的，於21世紀初欲探究臺灣原住民族固有的法律傳統，也相當倚賴日治前期開啟的「蕃族」習慣調查⁵⁹。換言之，日本殖民當局原出於自利的動機而為此等調查，但在結果上有助於今天以臺灣主體的法學研究。

二，無登記贖耕と承贖者の權利，臺法月報，15卷5號，頁1-5（1921年）；後藤和佐二，無登記贖耕と承贖者の權利，臺法月報，15卷6號，頁3-6（1921年）；後藤和佐二，無登記贖耕と承贖者の權利，臺法月報，15卷7號，頁9-13（1921年）；後藤和佐二，無登記贖耕と承贖者の權利，臺法月報，15卷8號，頁10-14（1921年）。此系列共有4篇；有水常次郎，無登記贖耕の効力に就きて，臺法月報，14卷5號，頁25-31（1920年）。

⁵⁷ 小島由道，親族相續に關する慣習，臺法月報，17卷1號，頁95-111（1923年）；小島由道，親族相續に關する慣習，臺法月報，17卷3號，頁53-59（1923年）；小島由道，親族相續に關する慣習，臺法月報，17卷4號，頁57-65（1923年）；小島由道，親族相續に關する慣習，臺法月報，17卷6號，頁64-72（1923年）。此系列共有4篇。

⁵⁸ 筆者就《臺灣私法》使用歐陸法概念所記述的臺灣漢人習慣，改以當今非法學的日常語言來表達，描繪出清治時期臺灣漢人不成文的民間習慣，但仍保留直接透過史料修正這份由日本人學者所為他族記載的可能。參見王泰升（註3），頁77-95。

⁵⁹ 例如，中央研究院民族學研究所編譯，臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會——蕃族調查報告書，共計8冊（2007-2015年）。於今在運用這些調查報告時，仍須注意其經常以不存在於原住民族法律傳統的歐陸法概念來表述。參見蔡桓文，國家法與原住民族習慣規範之衝突與解決，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁27-28（2007年）。

貳、作為日本法學支流及臺灣人法學者的出現 (1923-1945)

一、兩地法制相近以致法學內涵相似

前述以近代歐陸法律為規範內涵的日本「六法體系」，約自1923年起已大量施行於臺灣。於日治後期，殖民地臺灣仍維持總督擁有行政、立法兩權之特殊的憲政體制，且日本內地的法律（指經日本帝國議會協贊、天皇裁可後公布的法規範）還是須經勅令的指定始施行於臺灣；然而除了有些性質上屬當然施行於臺灣的法律之外，諸如《有關民事之法律施行於臺灣之件》、《行政諸法臺灣施行令》、《海事諸法臺灣施行令》等包裹式以及其他個別式的勅令，業已將日本內地大多數的法律延長其效力至臺灣，且形式上基於委任立法而由總督所制定發布的律令，實質上通常是準照日本內地相關的法律而為規定⁶⁰。因此在臺灣地域的國家實證法內涵，其實跟在日本內地者已十分相近。按戰前日本法學原即以跟著實證法條走的法釋義學為主，當時幾乎均由日本人所構成的臺灣法學界當然也不例外，在殖民地臺灣的實證法條已「內地延長」的情形下，出於實用上的便利性，當然傾向於同步引進日本內地的法學研究成果，而形成堪稱為「內地延長法學」的學風。

在另一方面，為達成「內地延長」的政策目標，而以日本內地法律取代原本的殖民地律令，所引發之既有權利如何轉換成新法上權利，或新制在施行上的疑義等，即成為1920年代臺灣法學界的熱門議題。最鮮明的例子，莫過於《臺法月報》1923年1月以「民法商法施行紀念特大號」為標題，登載約30篇相關的文章⁶¹。其後許

⁶⁰ 已在另文詳論，請參見王泰升，日治時期台灣特別法域之形成與內涵——台、日的「一國兩制」，收於：台灣法律史的建立，2版，頁115-126（2006年）。

⁶¹ 參見臺法月報發行所編，臺法月報，17卷1號：民法商法施行紀念特大號，頁4-111（1923年）。

多在臺灣任職的司法官，也陸續發表這類論文⁶²。其中最著名、堪稱日治時期司法官僚法學代表人物的姉齒松平判官，即是從探究1920年代這項法制上轉換的相關議題開始⁶³，逐步建立其「以臺灣法制研究為志業」的學術聲譽⁶⁴。

二、以日本內地法律為法學教育核心的臺北帝大政學科

法學教育機構乃生產法學知識的重鎮，殖民地臺灣於1928年始有第一所法學教育機構。按日本政府自治臺初期即積極培養臺灣人學習現代醫學，卻一直未培養臺灣人修習現代法學，蓋其不想讓臺灣人憑藉法學知識來反抗日本殖民者所擁有的國權⁶⁵。惟臺灣人向有培養子弟唸書、甚或當官的傳統，故日本治臺約20年後的1910年

62 例如參見渡邊里樹，民法第六百二條の期間を超えたる購耕契約の民法施行後に於ける效力，臺法月報，20卷11號，頁6-19（1926年）；伴野喜四郎，除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷1號，頁2-9（1929年）；伴野喜四郎，除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷2號，頁2-17（1929年）；伴野喜四郎，除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷3號，頁2-17（1929年）；伴野喜四郎，除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷4號，頁14-21（1929年）；伴野喜四郎，除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷5號，頁2-9（1929年）。此系列共有5篇。

63 時任臺灣總督府高等法院判官的姉齒松平，曾針對在法制轉換中具舉足輕重地位的1922年勅令第407號「有關施行於臺灣的法律之特例」的條文詳加檢討，或較一般性先談關於臺灣土地之物權的設定沿革，最後論及日本民法施行後其法律關係的演變，或先介紹「舊慣」上的合股關係，但強調自1923年起，施行日本民法商法之後，須改依「會社」（即今之「公司」）或「組合」（即今之「合夥」）之相關法律處理。參見姉齒松平，臺灣特例大正十一年勅令第四百七號第八條論，臺法月報，18卷8號，頁53-62（1924年）；姉齒松平，大正十一年勅令第四百七號第十六條に關する疑問，臺法月報，20卷6號，頁6-24（1926年）；姉齒松平，祭祀公業並臺灣ニ於ケル特殊法律ノ研究，改訂版，頁219-274、495-496（1938年）（以下簡稱：姉齒松平，祭祀公業）。

64 就姉齒松平個人的學術定位，筆者已以另文討論之，參見王泰升（註26），頁221-242。

65 參見王泰升，台大法學教育與台灣社會（1928-2000），收於：台灣法的世紀變革，頁111（2005年）。

代後期，已有一些年輕的臺灣人，或出身望族、或受望族的栽培，遠赴日本內地接受高等教育，其首選固然是醫科，但有助於通過國家考試而成為官僚的法科則居次⁶⁶。這些在殖民母國接觸具有個人主義、自由主義思維的現代法學的臺灣青年，將可能對在臺灣殖民地的專制集權政府心生不滿，少數前往中國就讀者還可能受中國國族主義影響，相較之下臺灣總督寧願順著「內地延長」口號而在臺設置帝國大學，以將臺灣學子留在其掌控下的臺灣，還可培植在臺日本人繼續擔任殖民地官僚⁶⁷。於1928年設置在臺北帝國大學內文政學部的政學科，在戰前日本「法政一家」傳統下，乃是以法律學為主、兼顧經濟學和政治學的法學教育機構，且偏重於培育政府或企業內的行政人才⁶⁸。不過此後，大多數的臺灣人學生仍偏好前往日本內地接受法科教育⁶⁹，此一方面使其得以將更原汁原味的日本法學帶回臺灣，另一方面則激發出後述的「臺灣人法學」。

66 參見吳文星，日治時期臺灣的社會領導階層，頁107（2008年）。

67 參見吳密察，從日本殖民地教育學制發展看台北帝國大學的設立，收於：台灣近代史研究，頁169（1991年）。

68 臺北帝大採取日本以講座制為核心的學制；具有教學與研究雙重功能的「講座」，係大學的基本單位，集若干講座為「學科」，若干學科為「學部」。大學即由大學院（相當於今日之「研究所」）與學部所組成。文政學部自1928年起，即設置文學科、史學科、哲學科以及政學科；其中又以政學科規模較大，設置有10個講座，其中屬於法律學領域者有7個，分別是憲法、行政法、法律哲學、民法民事訴訟法（一）、民法民事訴訟法（二）、刑法刑事訴訟法、商法等講座。另外尚有政治學政治史、經濟學（一）、經濟學（二）等3個非法學領域的講座。王泰升（註65），頁112-113。

69 臺北高等學校第1屆至第18屆畢業生中，有志於就讀大學內文政學部者，屬於臺灣人者有57人（40%）前往京都帝大，37人（26%）前往東京帝大，僅有35人（25%）留在臺灣進入臺北帝大，另有13人（9%）前往日本內地前揭兩校以外的大學。臺北高校畢業生中屬日本人者的情形，與屬臺灣人者差不多。參見徐聖凱，日治時期臺北高等學校與菁英養成，頁245表5-1-2（2012年）。劉恆姣在其研究中亦指出：光是從東京帝大一所學校畢業的臺灣人法政人才，即與臺北帝大所培育出的臺灣人法政人才，在人數上約略相當。參見劉恆姣，日治與國治政權交替前後台籍法律人之研究，收於：林山田教授退休祝賀論文編輯委員會編，戰鬥的法律人：林山田教授退休祝賀論文集，頁591-592（2004年）。

臺北帝大政學科雖位於臺灣，但與其他日本帝國大學同樣是以日本內地的法律及法學為教學研究核心。臺北帝大政學科的法學教師均來自日本內地，不曾有臺灣人教師能站上其講壇；且通常以戰前日本法學大家所撰教科書作為教材，在屬選修的各科「講讀」或「演習」課程裡，頗多以德文、英文、法文等原典為教材，或以日本法院判決例為討論素材。透過上述教學，所強調的是日本法制或現代法學的訓練，蓋其絕大多數的學生來自日本內地，且畢業後並非均留在臺灣，而是經常前往日本帝國各地及其勢力範圍（如滿洲國）就業。連在比例上居少數的臺灣人學生，亦有許多人前往臺灣以外的日本帝國勢力範圍，尋求更好的發展機會⁷⁰。也因此較為流行的學風，仍是對行政或司法上解釋適用最實用的法釋義學。

臺北帝大政學科與其說是臺灣殖民地的，還不如說是日本帝國的法學教育機構，其能生產、傳播多少與臺灣殖民地有關的法學知識都成問題，更遑論與臺灣人有關的法學知識。約自1920年代後，日本內地存在著重視對法院具體判決為解析、以及稍後強調以經驗科學方法檢視法社會現象的「末弘法學」⁷¹。從臺北帝大政學科在教學上相當注重法院判決例的討論而言，其似乎亦跟隨該學派。不過，作為末弘法學倡議者的末弘嚴太郎，於二次大戰期間曾經配合日本國家政策，為了理解中國民眾是在怎樣的法的慣行下為社會生活，而進行「華北農村慣行調查」⁷²。臺北帝大政學科教師們若欲依循末弘法學的研究取徑，追問法的慣行與人民社會生活之間的關

70 關於教學內容及學生的背景與就業，參見王泰升（註65），頁150-152、220-222、257-258。臺灣人在臺灣服公職者，經常無法一展長才，薪水還比從事同一工作的在臺日本人低，但如果其前往滿洲國或日本控制下的中國等地任職，此一不公的情境將可獲得相當大的改善。參見鄭麗玲，戰時體制時期臺北帝大的「學生生活調查」，臺灣風物，61卷1期，頁74-75註77（2011年）。

71 參見山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁382-383；潮見俊隆，末弘嚴太郎，收於：潮見俊隆、利谷信義編，日本の法学者，頁345-351、358-361（1975年）。

72 參見潮見俊隆（註71），頁358-359。

聯性，則在手邊即有現成的、由岡松參太郎等日本法學者就臺灣民眾所提出之具高度學術價值的舊慣法學論述。然而，竟無任何一位臺北帝大政學科的法學教師，曾本於末弘法學而承繼日治前期舊慣法學以闡釋法與習慣／社會之關係。按這些教師全係日本人，對不屬於其自身文化的臺灣人「舊慣」欠缺情感，亦難以體會一般的臺灣人或高山族原住民因固有的慣行與國家法律相衝突而生的困境，故縱令還有極少數人研究殖民地臺灣的「舊慣」，但其出發點也總是為了還殘存的司法或統治上需求（參見後述）。臺北帝大政學科之未能承繼具有臺灣在地特色的舊慣法學，使其錯失了據以發展出在日本帝國、東亞社會、甚或全球法學界具有獨特性研究的機會。此與同校醫學部不但延續日治初期關於臺灣具在地特性之疾病的研究，還有臺灣人教師杜聰明專研鴉片、蛇毒及漢醫學等臺灣本土議題並受國際學界肯定⁷³，有著相當大的差異。

三、日本法律及現代法學理論的研究為主、臺灣在地法律問題為輔

在前述國家法制及法學教育的雙重制約下，臺灣法學界的研究對象，大多數是與日本內地沒兩樣的日本法律及現代法學理論。當時在臺灣主要是由司法官僚所支持的《臺法月報》，刊載的法學論著大多係討論在日本內地所施行（且效力被延長或透過律令被援用於臺灣）的法典，以及各種現代法學理論。例如，在1920年代日本內地法律大舉施行於臺灣後，任職於高等法院覆審部的岩澤彰二郎判官即從民事訴訟法理論談「判決請求權」問題⁷⁴，同部的渡邊里

73 參見歐素瑛，傳承與創新——戰後初期臺灣大學的再出發（1945-1950），頁323-324（2006年）。

74 參見岩澤彰二郎，『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷5號，頁2-31（1924年）；岩澤彰二郎，『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷6號，頁12-35（1924年）；岩澤彰二郎，『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷7號，頁2-31（1924年）；岩澤彰

樹判官則就同時涉及民事實體與程序的法律議題發表意見⁷⁵，擔任高等法院檢察官、曾任舊慣調查會囑託的上內恒三郎亦連載有關刑事訴訟法上強制處分的論文⁷⁶。後來成為臺灣人親屬繼承習慣法專家（見後述）、時任高等法院覆審部判官的姉齒松平，在發表量上較多的是針對日本民法條文而發的論文，例如探討契約解除、不當得利等等⁷⁷。

臺灣因作為殖民地而生之不同於日本內地的特殊議題，在《臺法月報》上僅是附帶存在的。這些身為司法官僚的法學研究者，之所以探究這些臺灣社會特有的法律制度，也是因為國家的實證條文上仍承認其具有一定的法律規範上效力。日治後期《臺法月報》上已很少看到有關臺灣習慣的論著，且其中大部分是由姉齒松平所發表，其於1934年集結相關的文章出版《祭祀公業及在臺灣特殊法律之研究》一書⁷⁸，再於1938年出版《僅涉及本島人的親屬與繼承法

二郎，『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷8號，頁15-43（1924年）；岩澤彰二郎，『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷9號，頁2-41（1924年）。此系列共有5篇。

75 參見渡邊里樹，債權の競合は破産宣告の要件なりや，臺法月報，20卷2號，頁19-29（1926年）。

76 參見上內恒三郎，搜查上の強制處分手續，臺法月報，18卷3號，頁2-18（1924年）；上內恒三郎，搜查上の強制處分手續，臺法月報，18卷4號，頁2-10（1924年）；上內恒三郎，搜查上の強制處分手續，臺法月報，18卷5號，頁31-44（1924年）；上內恒三郎，搜查上の強制處分手續，臺法月報，18卷6號，頁35-43（1924年）。此系列共有4篇。

77 參見姉齒松平，契約解除に關する諸問題，臺法月報，17卷10號，頁28-35（1923年）；姉齒松平，契約解除に關する諸問題，臺法月報，17卷11號，頁20-28（1923年）；姉齒松平，契約解除に關する諸問題，臺法月報，17卷12號，頁38-48（1923年）；姉齒松平，契約解除に關する諸問題，臺法月報，18卷1號，頁42-48（1924年）；姉齒松平，契約解除に關する諸問題，臺法月報，18卷2號，頁32-43（1924年）。此系列共有5篇；姉齒松平，不當利得の要件に關して，臺法月報，18卷4號，頁22-37（1924年）；姉齒松平，不當利得の要件に關して，臺法月報，18卷5號，頁54-66（1924年）。此系列共有2篇；姉齒松平，不當利得の效果，臺法月報，18卷6號，頁44-50（1924年）。

78 姉齒松平所著《祭祀公業並臺灣ニ於ケル特殊法律ノ研究》的初版係1934年，參見姉齒松平，祭祀公業（註63），序頁3。

之大要》，該書的內容大體上涵蓋日本民法親屬繼承兩編的各個主題⁷⁹。從姉齒松平這兩本代表作的主题，剛好是臺灣殖民地民事立法上「依習慣」的臺灣人親屬繼承事項與祭祀公業，可知身為判官又好思敏學的他，乃是為了自己或同僚於辦案時，必須判斷臺灣人習慣應否被法院等國家機關承認為習慣法，而潛心研究臺灣人相關的習慣，且其見解經常為當時法院所採取。不過，姉齒松平盡可能地以日本民法上規定來理解、補充甚至改變臺灣人固有的親屬繼承習慣，俾能推動臺灣法律的（日本）內地化，其學術傾向與日治前期舊慣法學的主流實有一段距離⁸⁰。此外，屬於法學教師的安平政吉，曾於1940年間在《臺法月報》發表一系列有關臺灣高山族原住民族犯罪與刑罰的文章⁸¹，其研究動機可能亦來自殖民地法制上對高山族原住民族，有迥異於日本內地乃至在臺漢人的特殊對待。

在大學裡任教之法學研究者的研究成果，主要係發表於學校的機關刊物。於屬於全校性出版品的《臺北帝國大學紀念講演集》內，任職於文政學部法律學講座的教師所發表的論文，包括安平政吉的〈殺人的流行及其對策〉、後藤清的〈現代所有權論〉、中村哲的〈憲法與殖民地統治法的關係〉等3篇⁸²。尤要者，臺北帝大文政學部政學科自1934年至1945年出版了《政學科研究年報》共計9輯、內含56篇論文。該研究年報通常以篇名來區分論文的性質，若依各論文置於何篇名之下、以及作者所屬的講座別而為整理⁸³，其

79 該書內容包括：親屬範圍、家、結婚離婚、夫妻婚姻、養媳及養婿、親子關係、親權、監護、親屬會議、扶養義務、繼承人資格、戶主繼承、財產繼承、繼承之承認與拋棄、遺囑、特留分。

80 參見王泰升（註26），頁234-238。

81 參見註51，安平政吉，臺灣高砂族の犯罪と刑罰，共5篇。

82 其論文題目如下：安平政吉，〈殺人の流行と其の對策〉（第1輯）；後藤清，〈現代所有權論〉（第10輯）；中村哲，〈憲法と殖民地統治法との關係〉（第11輯）。參見國立中央圖書館臺灣分館編，國立中央圖書館臺灣分館日文臺灣資料目錄，2版，頁2-3（2000年）。

83 各個作者的「所屬講座」，參見陳昭如、傅家興，文政學部——政學科簡介，Academia——台北帝國大學研究通訊，創刊號，頁23-27（1996年）。

中由屬於法律學講座的教師所撰寫者共有22篇，各篇題目及作者如下表1所示，但另有5篇由屬於政治學講座教師所著、有關法政哲學或國際公法的論文並未列入。

表1 《政學科研究年報》內由屬法律學講座者所撰寫之論文一覽表（1934-1945）

輯數	篇名	論文題目（依原文）	作者
第一輯	法律篇	國家の理念と刑法	安平政吉
		私法法源としての慣習法と判例法	宮崎孝治郎
		法と語言（學說史の一斷面）	杉山茂顯
第三輯	法律政治篇	法現象進化の基底	宮崎孝治郎
		祭祀公業の基本問題	坂義彦
第四輯	法律政治篇	船舶「モルゲージ」について	中川正
第五輯	法律政治篇	債權法序論	菅原春雄
		債權關係の構成	菅原春雄
		契約と條約との關係に就ての二三の考察	宮崎孝治郎
		刑法に於ける人格主義の責任理論	安平政吉
		營造物權（Anstaltsgevalt）について——公法上の特別權力關係の一考察	園部敏
第六輯	法律政治篇	有價證券の觀念に就て	烏賀陽然良
		株式會社共同體論——ナチス株式法の基礎理論	中川正
		韓非子を讀む——刑治主義か德化主義か	鍾璧輝
第七輯	公法篇	フランスに於ける新自然法論	中井淳
		六三問題	中村哲
第八輯	私法篇	生態支那家族と其の族產制	宮崎孝治郎
		保證の特殊性と繼續的保證の概念	西村信雄
		轉換社債發行のためにする條件附資本増加	中川正
第九輯	公法政治篇	行政規則について	園部敏

		ゲルマンの國家觀念——國家觀念發達史（一）	中村哲
		刑法に於ける道義性の要求	植松正

資料來源：第一至七輯的目錄，引自陳昭如、傅家興，文政學部——政學科簡介，Academia——台北帝國大學研究通訊——，創刊號，頁69-71（1996年），並稍加修正。第八、九輯的目錄，由松平德仁先生依收藏於東京大學圖書館的該刊物而提供。

由上舉論著可知，臺北帝大政學科內法學研究者係著重於與現代法制相關的各種法學理論的介紹或探討。僅少數法學作品，例如安平政吉有關高山族原住民族犯罪與刑罰之文⁸⁴、坂義彥所撰〈祭祀公業的基本問題〉（見表1）⁸⁵、中村哲所撰〈憲法與植民地統治法的關係〉與〈六三問題〉（見表1）等，乃是針對殖民地臺灣特有的議題而為研究。園部敏於1943年在殖民地臺灣出版行政法教科書，其書名為《行政法概論——特別顧及在臺灣的行政法規——》⁸⁶，恰足以揭示日治晚期整個臺灣的法學研究方向，亦即以日本法律及相關的（德國等）法學理論為主，只附帶地交代臺灣殖民地猶存之少數異於日本內地的法制。又，臺北帝大政學科屬法律學講座之教師們在私法研究會、國法研究會、臺北比較法學會、法學讀書會、政學科研究會中所做報告的題目，亦顯現出同樣的趨向⁸⁷。雖然中村哲因上述研究業績而在戰後日本被認為是「殖民地法」的專

⁸⁴ 在臺北帝國大學農學科任教的增田福太郎，也曾依實地調查而記述高山族原住民族固有的法律規範，但其於戰後返回日本後始將此研究果集結成書。參見增田福太郎，未開社會における法の成立（1957年）。

⁸⁵ 此外，宮崎孝治曾到臺中、臺南、高雄為田野調查，可能是針對臺灣漢人關於婚姻的習慣，進行了解，但其未就此撰寫論文。參見陳昭如，初探台北帝大政學科的法學教育與法學研究，Academia——台北帝國大學研究通訊——，2號，頁29、35、67（1997年）。

⁸⁶ 園部敏，行政法概論——特に臺灣行政法規を顧慮して——，改訂版（1943年）。

⁸⁷ 參見陳昭如、傅家興（註83），頁64-68；陳昭如（註85），頁29。

家⁸⁸，但其所為的研究於日治晚期的臺灣法學界並非主流，其情況頗類似於在戰後臺灣被視為臺灣親屬繼承法專家的姉齒松平。

四、法學大眾化的肇始

也因作為日本法學的支流，故當時日本的法學大眾化浪潮亦相當程度湧向日治下臺灣的法律界。於1920年代，末弘嚴太郎對於一般民眾的「不知法律」感到十分憂心，故以學院內法學者的身分，藉著發行《現代法學全集》和《法律時報》，致力於民眾法學知識的啟蒙運動；再加上在末弘之前已有一些先驅者的努力，故形成了一種「法學大眾化」的氛圍⁸⁹。曾在日本內地接受法學教育的臺灣人對於臺灣一般民眾的「不知法律」恐怕感觸更深，蓋臺灣民眾還經常因「不知日文」而「不知法律」，甚難接近現代法學知識。如後所述1920年代《臺灣青年》、《臺灣民報》等刊物上之登載法政相關文章，已多少伴隨著推動法學大眾化的目的。

於1930年代的臺灣，曾出現一份以法學大眾化為主要訴求的雜誌，亦即《民眾法律》。這份《民眾法律》係由位於臺中的「民眾法律新報社」所刊行，其發行者為臺灣人。其中有日文（和文）版面及漢文版面，兩者同等被重視。最常登載的主題是與一般民眾日常法律生活有關係者，例如介紹什麼是「會社」（即今之公司）？「合名會社」（今之無限公司）與「合資會社」（今之兩合公司）有何差別⁹⁰？或直接以「刑罰之一般與在於家庭常易發生之犯罪之解說」做為題目⁹¹。且開闢「法律質問欄」，回答讀者經付費（每一問付一圓、訂戶半價）以通信所詢問的個別法律問題。常見的文

88 參見宮平真弥，中村哲先生の植民地法研究について，沖繩文化研究，31期，頁523-542（2004年）。

89 參見山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁383-384。

90 清輝生，會社の問題，民眾法律，2卷4號（和文），頁35-39（1933年）。

91 民眾法律新報社，刑罰之一般與在於家庭常易發生之犯罪之解說，民眾法律，2卷4號（漢文），頁7-9（1933年）。

章，還有提供司法書狀之範例者⁹²，介紹日常生活中常遇到的重要法律，例如《臺灣違警例》⁹³、《治安警察法》⁹⁴，以及概述基本的法學或法制概念，例如謂：「於刑法之語者，有分廣義與狹義之二項之意義。……」，或指出現行法律的制定，須在法案作成之後，「經帝國議會之協贊，仰天皇之裁可，……遂至公布」⁹⁵。值得注意的是，某些未施行於臺灣的日本內地法律亦在介紹之列，例如被認為與「裁判之國民化」有關的《陪審法》⁹⁶，該雜誌似乎有意以此彰顯其站在民眾這一邊的立場。不過，其似乎仍偏重商業考量，並未揭示可能引發日本統治當局打壓的臺灣人意識。

雖可確知有辯護士撰文或擔任顧問⁹⁷，但《民眾法律》整個編輯群及出版者的知識背景或社會階層等，乃至於訂閱者或讀者的人數或社會階層等運作實態仍不清楚⁹⁸。當時是否還有與其性質相類似的其他雜誌或套書，也有待進一步搜尋。是以日治臺灣有關法學大眾化的議題，猶待他日再深入探究。

92 民眾法律新報社，假差押申請，民眾法律，2卷4號（和文），頁39-50（1933年）。

93 民眾法律新報社，臺灣違警例，民眾法律，3卷8號（漢文），頁30-35（1934年）。

94 民眾法律新報社，治安警察法，民眾法律，3卷8號（漢文），頁38-40（1934年）。

95 民眾法律新報社，刑法之由來，民眾法律，2卷4號（漢文），頁12-13（1933年）。

96 永章生譯，陪審法與一般的常識，民眾法律，2卷4號（漢文），頁14-21（1933年）。

97 蘇樹發，法庭詭辯，民眾法律，1卷3號（和文），頁49-51（1937年）。該文作者名字上方已註明「辯護士、法學士」。該期《民眾法律》在版權頁的前一頁，列出10位「顧問辯護士」，其執業地點分別為臺北（1位）、新竹（1位）、臺中（5位）、嘉義（1位）、臺南（1位）、高雄（1位），其中3位臺灣人、7位日本人。不過該期係出版於1937年12月，卻又從「第一卷」開始起算，令人不解。

98 目前在國立臺灣圖書館（原中央圖書館臺灣分館）及國立臺灣大學總圖書館皆有收藏一部分《民眾法律》。

五、「臺灣人法學」的出現及初試啼聲的臺灣人法學者

約自1920年代起，某些前往日本內地受教育的臺灣法律人，已能突破日本殖民統治當局在法學知識上所設置的封鎖線，而本於臺灣人主體意識，運用來自西方的現代法學，提出有利於臺灣人群體的法律論述。就像當時許多亞、非殖民地菁英到了殖民母國受新思潮的洗禮後，即開始思考自身民族的處境與出路，在日本內地唸法科雖所接觸者是以日本為中心的法學知識，但卻因而更理解臺灣人或殖民地臺灣所遭受的差別待遇，故有一部分臺灣法律人將反日本殖民統治的因素，納入其法學論述的內涵中。

例如林呈祿早於1914年即至東京留學，之前在臺灣則擔任法院書記官，因此熟習源自近代西方個人主義、資本主義的現代法律制度的運作。其於1920年，在由臺灣人政治異議者所辦雜誌《臺灣青年》上，發表〈六三問題之運命〉⁹⁹，以精湛的法學素養看透日本在臺特殊的「六三體制」的政治意涵，從做為全體臺灣人（當時亦稱「臺灣民族」）之受託人的立場，深入分析此一問題，提出應採行的方案，使得整個臺灣人政治反對運動的訴求，從「廢除六三法」改為「設置臺灣議會」¹⁰⁰。關於六三問題，當時臺灣法學界由於與官方關係密切，對於臺灣憲政問題多傾向於支持既有的統治體制，包括日本憲法學者市村光惠、總督府判官姉齒松平等人；於日治晚期任教於臺北帝大的中村哲與園部敏，雖曾提出部分批判意見，但仍不主張對臺灣特殊體制做徹底的改造¹⁰¹。在這樣的氛圍底下，某些願意投身政治反對運動的臺灣法律人，成為日治中期以後

99 林呈祿（原署名「林慈舟」），六三問題之運命，臺灣青年，1卷5號（漢文之部），頁16-29（1920年）。

100 其詳，參見王泰升，「鬱卒」的第一代台灣法律人：林呈祿，收於：台灣法的世紀變革，頁79-81（2005年）。

101 其詳，參見王泰升，台灣日治時期憲法史初探，收於：台灣法律史的建立，2版，頁213-222（2006年）。

批判臺灣殖民地憲政體制的主力；例如1921年由林獻堂領銜連署的〈臺灣議會設置請願書〉，即是林呈祿主筆。

因此於1920年代初，當日本民法應否直接施行於臺灣成為一項法律議題時，身為第一代臺灣法律人的前述林呈祿與在臺灣擔任辯護士的鄭松筠，都曾從「臺灣人」及「應如何繼受近代西方法制」的視角，提出頗具法學深度的見解¹⁰²。兩人曾在《臺灣青年》發表過一系列的文章，如林呈祿的〈施行民法商法宜置除外例〉、〈將民法親族規定適用於台灣人之法案的疑義〉，鄭松筠的〈就民商法施行而言〉等¹⁰³，在一片由日本人官僚或學者所壟斷的法學論述中，努力地從被統治者角度發聲。然而這些聲音在臺灣，僅能靠有限的社會運動或少數報紙來傳播，並未被國家教育體系所採納，故影響力有限。按這群屬於政治異議者的臺灣人知識菁英，多未擔任公職或進入帝大的教育體系，包括林呈祿、鄭松筠、黃呈聰、蔡式穀、王敏川等人，雖在《臺灣青年》、《臺灣民報》均有大量關於憲政、法學的論著，但其文章連在法律實務色彩較重的《臺法月報》上都看不到，更遑論出現於其他學術性較重法學期刊。惟無論如何，在報社工作的林呈祿，乃至擔任辯護士的鄭松筠，雖在當時被排斥於臺灣法學界之外，但就其法學論述的深度而言，作為法學者已當之無愧，堪稱為最早出現的臺灣人法學者。

於1930年代後，極少數在臺灣本地接受法學教育的臺灣人，或許有機會留在法學教育機構內從事法學研究，但其發展都不順遂。例如，臺北帝大政學科畢業後留校從事學術研究的鍾壁輝，曾於1934年，在《臺法月報》為文探究臺灣人的離婚制度，雖批判固有

¹⁰² 其詳，參見王泰升（註2），頁123-124。

¹⁰³ 林呈祿（原署名「記者」），施行民法商法宜置除外例，臺灣青年，3卷4號（漢文之部），頁21-26（1921年）；林呈祿，民法親族規定を臺灣人に適用する法案の疑義，臺灣青年，3卷6號（和文之部），頁21-35（1922年）；鄭松筠（原署名「鄭雪嶺」），就民商法施行而言，臺灣青年，3卷4號（漢文之部），頁17-21（1921年）。

的「七出」但仍主張維持部分舊慣¹⁰⁴；再於1940年，在屬於學術機構刊物的《政學科研究年報》發表〈讀韓非子：刑治主義或德化主義〉（參見前揭表1）。但鍾壁輝在臺北帝大政學科內並未被接納為法學教師，其於1932年畢業（第二屆）後先擔任副手，但一直到1940年，當同屆畢業生山下康雄已返校任講師之時，才升任助手，然再經兩年後即離職，進入報社工作。此外，屬臺灣人的第四屆畢業生王燮村（王野高光）、第五屆畢業生林德旺、第六屆畢業生陳加溪、第七屆畢業生張松標，均於畢業後擔任副手，卻都始終未能擔任助手。按臺北帝大政學科共培育了40位臺灣人畢業生，卻沒有養成任何一位講師級以上的大學教師¹⁰⁵。何以相當多臺灣人畢業生循留校任教的管道都未能成為授課教師，日本人畢業生走留校任教之途者少卻都能如願成為教師，其間是否有族群上的歧視，啟人疑竇¹⁰⁶。

相對的，某些到日本內地習法的臺灣人，卻有機會前往成為日本帝國勢力圈一部分的滿洲國擔任教職，名正言順地成為法學者。例如1933年畢業於九州帝國大學的林鳳麟¹⁰⁷，曾任教於滿洲國長春（時稱「新京」）法政大學，且參與滿洲國民法親屬與繼承兩編的草擬¹⁰⁸，應是身分法方面的專家。當時前往滿洲國發展且在長春法政

¹⁰⁴ 參見陳昭如，離婚的權利史——臺灣女性離婚權的建立及其意義，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁151（1997年）。

¹⁰⁵ 王泰升（註65），頁177；陳昭如（註85），頁34-35、45；鄭麗玲（註70），頁76-77。臺北帝大設有「副手」制度，為職員以外的名額，為使學生於大學畢業後繼續在校研究而制定此制度。見松本巍著，蒯通林譯，臺北帝國大學沿革史，頁18（1960年）。

¹⁰⁶ 按臺北帝大政學科內法學教師的最高學歷大多是法學士，且不少是畢業自東京帝國大學法學部。假設臺北帝大政學科的臺灣人畢業生因不夠優秀或太過年輕，而無法留校擔任教職，則自1920年代起已有不少臺灣青年就讀於東京帝大或京都帝大的法科，當中難道皆無具有返鄉任教之志者？能夠在對臺灣人不利的臺灣初級、中級教育中與日本人學生並駕齊驅，再脫穎而出進入東大或京大者，其資質能謂不優秀嗎？但至1945年為止竟沒有一位臺灣人法科畢業生能進入臺北帝大政學科任教。

¹⁰⁷ 曾文亮、王泰升，被併吞的滋味：戰後初期臺灣在地法律人才的處境與遭遇，臺灣史研究，14卷2期，頁149（2007年）。

¹⁰⁸ 司法院司法行政廳編，台灣法界耆宿口述歷史（第一輯），頁116（2004年）。

大學任教的臺灣人，還有講授國際私法的黃演淮及另一位出身臺南的王朝坪¹⁰⁹，惟於今僅知黃演淮畢業自同志社大學，王朝坪畢業自早稻田大學¹¹⁰，尚無從獲悉這兩位的法學研究業績。

此外，到日本內地唸法科的臺灣人，也有可能在回臺灣後，以法律實務界人士的身分成為學院外的法學者。最顯著之例即是，曾在東京帝國大學受業於日本的法制史大家中田薰的戴炎輝，於返回臺灣後雖擔任辯護士，但於日治晚期致力於關於臺灣（與中國）的村庄、街庄地方制度以及家族祖先祭祀公業等研究¹¹¹，且曾在《臺法月報》上發表過關於養子法、招婿、合會等臺灣人習慣的文章¹¹²。這些作品之被日治臺灣的法學期刊接受，多少還是因當時國家的實證法上臺灣人身分事項依習慣法處理，且戴炎輝有時即直接

109 司法院司法行政廳編（註108），頁116-117。

110 曾文亮、王泰升（註107），頁149-150。

111 參見王泰升、堯嘉寧、陳韻如，戴炎輝的「鄉村臺灣」研究與淡新檔案——在地「法律與社會」研究取徑的斷裂、傳承和對話，法制史研究，5期，頁264-267（2004年）。

112 參見戴炎輝，近世支那臺灣の養子法，臺法月報，31卷7號，頁49-63（1937年）；戴炎輝，近世支那臺灣の養子法，臺法月報，31卷8號，頁67-77（1937年）；戴炎輝，近世支那臺灣の養子法，臺法月報，31卷9號，頁15-25（1937年）；戴炎輝，近世支那臺灣の養子法，臺法月報，31卷10號，頁35-39（1937年）；戴炎輝，近世支那臺灣の養子法，臺法月報，31卷11號，頁17-21（1937年）。此系列共有5篇；戴炎輝，招婿婚に就て，臺法月報，32卷3號，頁21-27（1938年）；戴炎輝，招婿婚に就て，臺法月報，32卷4號，頁22-30（1938年）；戴炎輝，招婿婚に就て，臺法月報，32卷5號，頁30-37（1938年）；戴炎輝，招婿婚に就て，臺法月報，32卷6號，頁36-43（1938年）。此系列共有4篇；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷3號，頁33-41（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷4號，頁28-38（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷5號，頁33-45（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷6號，頁31-43（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷7號，頁23-28（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷8號，頁36-41（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷9號，頁26-34（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷10號，頁49-51（1939年）；戴炎輝，臺灣舊慣上の合會（賴母子講），臺法月報，33卷11號，頁37-40（1939年）。此系列共有9篇。

以臺灣總督府法院的判決例作為研究素材¹¹³。

從事法學研究的臺灣人，是否將其族群背景反映在所建構的法學知識上，是一個令人感興趣、但卻也是不易回答的問題。例如，根據歐陸法系的法學概念，應如何說明臺灣漢人固有的祭祀公業的本質？雖當時包括姉齒松平在內的多數法界人士支持國家實證法上既有之「習慣上法人」的定位，但身為臺灣人的戴炎輝卻主張「總有說」，亦即祭祀公業性質上屬於德國法上的「總有」。然而，身為日本人及學院內法學者的坂義彥，也同樣主張「總有說」。若戴炎輝之主張「總有說」是純然出於保障臺灣人／臺灣民族之動機？何以在族群上非屬臺灣人的坂義彥亦採同說¹¹⁴？或許上述總有說的主張，只不過反映當時法學知識之受到德國法學宰制爾，並沒有太多族群經驗或認同等因素涉入其中？這也可解釋為什麼前述那群對抗總督府的臺灣人法學知識菁英，與許多在臺灣的日本人司法官僚一樣，對祭祀公業傾向於持負面見解¹¹⁵。

於日治晚期，較明顯展現臺灣人意識且由政治異議者所形塑的臺灣人法學，隨著1930年代日本逐步進入戰爭狀態¹¹⁶，連很有限的發聲管道都漸次消失。例如，由林呈祿主編的《臺灣民報》，1932

113 戴炎輝教授於日治時期所發表的重要論文之一：〈臺灣的家族制度與祖先祭祀團體〉，即是以殖民地法院的判決例作為分析的材料。參見田井輝雄（戴炎輝），臺灣の家族制度と祖先祭祀團體，收於：金關丈夫編，台灣文化論叢（第二輯），頁181-264（1945年）。

114 參見曾文亮，台灣法律史上的祭祀公業，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁80-82（1999年）。

115 吳豪人教授認為這群對抗總督府的臺灣法律人，擬以對於現代性的擁護，來批判在言說上亦支持現代性的日本帝國，故對祭祀公業這種舊有的「想像共同體」沒有興趣，而是想追尋屬於現代的民族自決潮流下，以「臺灣民族」認同為基礎的「國族國家」這種新的「想像共同體」。相關的論述，參見吳豪人，「台灣法史」の可能性：法社会的・法思想史的試論，京都大学大学院法学研究科博士論文，頁69-116（1999年）。

116 戰後有日本學者將1931年九一八事變起至1945年第二次世界大戰結束，稱為「十五年戰爭」。參見鶴見俊輔著，邱振瑞譯，戰爭時期日本精神史（1931-1945），頁78（2008年）。

年起成為日報而改稱《臺灣新民報》，並自詡為臺灣人的喉舌；然而在嗣後的皇民化運動中，其漢文版自1937年6月1日起被取消，1941年被迫改稱具有「大東亞戰爭」意涵的《興南日報》，更於1944年被命令與其他報紙合併而停刊¹¹⁷。趁勢而起的，就是下述法西斯化的法學。

六、以跟隨日本帝國的「法西斯化法學」作結

1936年軍部大臣現役武官制的復活以及大本營的設立，乃戰前日本在法制上法西斯化的起點，其後形成了準戰時法體制，期使法律為戰爭而預作準備，以致法律倒成為壓制國民基本人權的工具¹¹⁸。日本1938年《國家總動員法》的通過，確立了「法西斯法制」。按《國家總動員法》是一項以完成準戰時、戰時國防為目標的廣泛授權的法律，將人的、物的資源全委由行政權管統、運用；其內容之充滿大量的空白授權規範，正顯示出政府與軍部掌握全部的權限，不受議會限制，因此1932年起至1945年戰爭結束，被戰後日本學者認為是日本法制的「崩壞期」，其最大的特徵是，法規範喪失了抑制政治權力的效果。法的崩壞，同時意味著法學的崩壞¹¹⁹。此時的日本法學亦被迫走向法西斯化，以個人自由、人權為第一要務之具有現代性的法學論述更趨於疲弱¹²⁰。

日治時期臺灣法學作為日本法學之支流，實在難以自外於這樣的大趨勢。連司法官僚出身的法學者姉齒松平，對於軍部勢力擴張到法界，以及法西斯法化的趨勢，都展現出無比的嫌惡¹²¹。惟法制

117 參見王泰升（註100），頁96-97。

118 參見渡邊洋三，日本ファシズム法体制・総論，收於：東京大学社会科学研究所編，ファシズム期の国家と社会（4）戦時日本の法体制，頁30-31（1979年）；山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁24。

119 參見渡邊洋三（註118），頁4、16-17。

120 參見山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁388。

121 參見吳豪人，植民地の法学者たち——「近代」パライソの落とし子，收於：酒井哲哉編，「帝国」日本の学知（第1巻）——「帝国」編成の系譜，

的改變，仍影響及臺灣法學界的論述內容。《臺法月報》自1930年起，時任臺北地院檢察官長、總跟隨著各時代政治風向的上內恒三郎即發表一系列有關國體之文章，如〈論我國的國體〉¹²²、〈國體與國民的責任〉¹²³。在臺北帝國大學農學科任教的增田福太郎，身為戰前日本國粹主義者寬克彥的學生，亦發表具有皇國法學思想的〈天岩戸的精神與帝國憲法（法理小稿・五）——寬博士的教示——〉¹²⁴、〈所謂天皇機關說之內在的批判（法理小稿・六）——正木教授的業績——〉¹²⁵、〈作為皇學的憲法學（法理小稿・七）——憲法學方法論批判——〉¹²⁶。

頁134-136（2006年）。

122 上內恒三郎，我が國體に就て，臺法月報，24卷1號，頁2-10（1930年）；上內恒三郎，我が國體に就て，臺法月報，24卷2號，頁2-10（1930年）；上內恒三郎，我が國體に就て，臺法月報，24卷4號，頁2-13（1930年）；上內恒三郎，我が國體に就て，臺法月報，24卷5號，頁2-7（1930年）；上內恒三郎，我が國體に就て，臺法月報，24卷6號，頁2-8（1930年）。此系列共有5篇。

123 上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，29卷10號，頁1-11（1935年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，29卷11號，頁13-21（1935年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，29卷12號，頁3-9（1935年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，30卷2號，頁1-9（1936年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，30卷3號，頁33-36（1936年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，30卷4號，頁9-12（1936年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，30卷5號，頁5-13（1936年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，30卷6號，頁1-10（1936年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，30卷9號，頁1-9（1936年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，30卷10號，頁1-9（1936年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，31卷2號，頁1-8（1937年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，31卷3號，頁1-10（1937年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，31卷5號，頁1-5（1937年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，31卷6號，頁1-7（1937年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，31卷8號，頁1-7（1937年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，31卷9號，頁1-5（1937年）；上內恒三郎，國體と國民の責任，臺法月報，31卷10號，頁1-9（1937年）。此系列共有17篇。

124 增田福太郎，天岩戸の精神と帝國憲法（法理小稿・五）——寬博士の示教——，臺法月報，32卷11號，頁1-10（1938年）。

125 增田福太郎，所謂天皇機關說の內在的批判（法理小稿・六）——正木教授の業績——，臺法月報，32卷12號，頁6-13（1938年）。

126 增田福太郎，皇學としての憲法學（法理小稿・七）——憲法學方法論批判

隨著戰爭的緊繃以及《國家總動員法》下的經濟管制體制擴大，日本帝國統治下的臺灣於1940年代也有關於戰爭法的討論。例如，於1933年曾高舉現代法治主義，而批評日本作為立憲法治國在臺灣竟未施行行政訴訟法有失體面的辯護士飯岡隆¹²⁷，於1942年即發表了〈關於戰時工業所有權的法令〉等論文¹²⁸。然而這些文章大多只就法條為釋義，極少有挑戰法西斯體制的論述，所呈現的法學知識上的特色，即是「重國家權力、輕人民權利」。為政治服務之性格原已相當濃厚的殖民地臺灣法學，此刻只剩下不具有自我主體意識的殖民性，而失去了自日治初期起原本不斷提升中的現代性。換言之，日治時期的臺灣只能在殖民主義，亦即以日本帝國之最高利益為依歸的框架或侷限下，擁有具現代性的法學，故可稱為「殖民現代性法學」。

日治時期之以削弱現代性的法西斯化作結，恰好在臺灣歷史進程上，銜接了比日本殖民政權更缺少現代性的國民黨政權¹²⁹。另一波現代意義法學的發展，也將須從此一低檔，再一步一步往上爬升，不過那一段故事已屬於以下將論述的戰後法學史的範疇了。

——，臺法月報，33卷2號，頁1-10（1939年）。

127 參見飯岡隆，行政裁判法を臺灣に實施す可し，臺法月報，27卷6號，頁4-5（1933年）。

128 飯岡隆，戰時下の工業所有權に關する法令，臺法月報，36卷2號，頁31-43（1942年）；飯岡隆，戰時下の工業所有權に關する法令，臺法月報，36卷3號，頁12-28（1942年）；飯岡隆，戰時下の工業所有權に關する法令，臺法月報，36卷4號，頁1-9（1942年）；飯岡隆，戰時下の工業所有權に關する法令，臺法月報，36卷5號，頁33-38（1942年）；飯岡隆，戰時下の工業所有權に關する法令，臺法月報，36卷6號，頁6-14（1942年）；飯岡隆，戰時下の工業所有權に關する法令，臺法月報，36卷7號，頁5-10（1942年）。此系列共有6篇。

129 民國時代中國訓政體制相較於日治臺灣憲政體制，在現代性上更加遜色，參見王泰升（註3），頁134-136；在司法的現代化程度，日治臺灣亦勝過民國時代中國，其詳，請參見王泰升，清末及民國時代中國與西式法院的初次接觸——以法院制度及其設置為中心，中研院法學期刊，1期，頁105-162（2007年）。

參、戰後初期兩源匯合為今之臺灣法學奠基 (1945-1949)

一、戰前中國的法制及法學發展經驗

從締結《馬關條約》的1895年起，至1911年建立中華民國，直到1945年為止在中國所發生的種種，與同一時間係處於日本殖民統治下的臺灣本無甚關聯¹³⁰，但這段臺灣未參與的「歷史記憶」，卻於戰後橫向移植至臺灣斯地。按以「中華民國」為國號的國家組織體，於二次大戰結束兩個多月後的1945年10月25日，以戰勝的同盟國身分軍事接收原由日本統治的臺灣¹³¹，並現實上將中華民國法律體制施行於臺灣（包括國際法上效力等詳情待後述）。從政治事實而言，原在中國創建的中華民國此一國家組織體（可稱「在中國的中華民國」，1911-1949），從1949年年底起，已幾乎將作為國家實質的土地與人民，減縮至臺灣（含澎湖）以及原屬中國福建省的金門及馬祖，而成為「在臺灣的中華民國」（1949年迄今）。然而中華民國法體制／法秩序仍在規範上宣稱：其自1945年起持續施行於臺灣，且於今其施行地域依舊包括中國大陸（稱「大陸地區」），並據此而於歷史教育上強調「中華民國史」，漠視不在中華民國統治下的日治臺灣（1895-1945）¹³²。

130 1895年至1945年間臺海兩岸人民，因分屬兩國，且往來很有限，故並未共享歷史經驗。就算有極少數前往中國的臺灣人（臺灣籍民）、來臺灣的中國人（華僑），彼等在中國、在臺灣的法律上地位，亦與當地人不同。參見王泰升、阿部由里香、吳俊瑩，台灣人的國籍初體驗：日治台灣與中國跨界人的流動及其法律生活，頁61-222（2015年）。

131 從1945年10月25日在臺灣所舉辦的「受降典禮」上，同時懸掛著中國、美國、英國、蘇聯等四國的國旗，可知性質上乃是同盟國，而非僅是中國，接受日本投降。參見王泰升、薛化元、黃世杰編著，追尋臺灣法律的足跡：事件百選與法律史研究，增訂3版，頁171（2016年）。

132 對於涵蓋今稱為臺灣之土地（臺澎金馬）與人民的歷史，亦即臺灣史而言，重要的斷代時間是，開始改由稱為中華民國的國家組織體所統治、施行中華民國法體制／法秩序的1945年（金馬例外地不適用這項始點），該年迄今可稱

其實作為特定國家組織體的中華民國，與作為特定地域社會／生活共同體的臺灣，原本分處於兩條不同的歷史發展軸線，直到1945年這兩條歷史發展軸線才猝然交會，甚至從1949年起兩條線竟然合而為一。因此為了理解1945年以後臺灣共同體的發展，有必要探究形塑出中華民國法體制的清末、民國時代（1911-1949）中國的歷史。按不但從1945至1988年作為臺灣政治強人的蔣中正與蔣經國及其重要幹部，所抱持的就是來自民國時代中國的法政經驗及歷史文化認同，且戰後成為臺灣人民一部分的外省族群也擁有這段歷史經驗，故其應被納入「多源」併存的臺灣史當中¹³³。本文既然欲

為「戰後時期」或「中華民國時期」，其至2000年亦可稱為表示「國民黨一黨執政」的「國治時期」（相對於此，2000年之後迄今可稱「政黨輪替時期」）。然而，對於稱為中華民國的國家組織體的歷史，亦即中華民國史而言，重要的斷代時間是，該國家組織體的領土與人民事實上已發生鉅大改變的1949年，據此即可分為「在中國的中華民國」（1911-1949）與「在臺灣的中華民國」（1949年迄今）。不過中華民國法體制／法秩序本身的認定，或者說是其法律上的宣稱，僅認為1949年在國家統治權可行使的地理範圍上有變動，從此只及於臺灣，而不及於其稱為「大陸地區」的中國大陸（單純當作地理名詞）。事實上中國大陸自1949年起，已由另一個稱為中華人民共和國的國家組織體有效統治迄今，且業已為國際社會認定其就是世人稱為「中國」的國家；按稱為中華民國的國家組織體於1971年之前雖尚在聯合國擁有代表「中國」的席位，但其後此席位改由中華人民共和國擁有。總之，本文係立足於政治事實而為立論與稱呼，並不受制於中華民國現行法律之規定或規範上宣稱。而另一個中華人民共和國法體制／法秩序，則根本不承認有一個統治臺澎金馬、稱為中華民國的國家組織體存在，但本文同樣從政治事實出發，亦不接受中華人民共和國法體制該項規範上宣稱。在臺灣史上，1949年12月9日行政院開始在臺北辦公，即表示中華民國中央政府已遷移至臺灣，故此後在今之臺灣共同體（臺澎金馬）存在一個事實上的主權獨立國家；而臺灣自1945年10月25日起至1949年12月8日，則可相對地稱為「充作中國一省」時期，雖然此時臺灣在國際法上地位仍未定。

- ¹³³ 關於外來的中國法在臺灣社會的在地化，亦即探討臺灣法中的中國元素，參見王泰升（註26），頁46-52。中國從清末到民國時代的法律史，雖是臺灣史與中國史所重疊的部分，但向來似乎都不怎麼被重視。按臺灣或中國的法學界，或出於關心中國之繼受西方法而較常論及「清末民初」法制發展，但對於以訓政體制實施一黨專政的國民政府，在過去卻一直忽視其法制狀況及法學發展。蓋中國共產黨政府欲否定「前朝」以獲得統治正當性，故對國民政府時期法制及法學或視為禁忌或予以醜化，直到晚近才有較具學術性的研究。在臺灣的國民黨則於兩蔣時代雖號稱「行憲」，但實際上延續訓政時期的

論述「戰後」，亦即1945年二次大戰結束後臺灣的法學史，當然須先說明在這一年被植入、原非發生於臺灣的清末民國時代中國法制及法學經驗¹³⁴。

（一）源自清末的中國北洋政府時期西式法學（1902-1928）

在歷史悠久的傳統中國，並無於今所稱的法學。約在1840年鴉片戰爭、海禁大開之後，清朝中國才開始接觸來自西方的現代意義法律，但一開始係著眼於翻譯與介紹某些西方法學者的著作¹³⁵。當時仍著眼於以洋法治洋人，故較關切國際公法領域，如1860年代由美國傳教士丁韞良翻譯《萬國公法》，且尚不重視在西方作為一種具有體系性學問的法學。直至清末庚子事變後，為展開新政而擬立憲，且1902、1903年議定「一俟查悉中國律例情形及其審斷辦法及一切相關事宜皆臻妥善，英國即允棄其治外法權」之後，清朝才有全面繼受西方法制的強烈動機¹³⁶。而為了執行那些西方式的法制，勢必須同時引進以該項法制為討論及適用之對象、淵源自西方歷史的現代意義的法學。

以黨治國、黨國不分，故有點掩耳盜鈴地不願那段明文規定可一黨專制的訓政時期法律史再被曝光而引發聯想；民主化之後的臺灣，史學界忙於補修數十年來長期被打壓的臺灣史，尤其是日治時期部分，故較難兼顧這段與中國重疊的歷史。本文因而比起日治時期之討論日本統治者法律經驗，較為詳細地探究中國從清末到民國時代的法制及法學發展。

¹³⁴ 從這個視角而言，清末民國時代中國法乃是臺灣法律史的一部分。筆者曾分別就清末民國時代中國的西式法院、訓政時期中國黨治經驗，進行研究並發表論文，如後所引註者。

¹³⁵ 參見蔡樞衡，中國法理自覺的發展，頁59（2005年）。（按：本書為增訂重刊本，原版為1947年作者自刊。）

¹³⁶ 1902年7月，張之洞與英國代表會談簽訂之《中英商約》第12條。其後《中美商約》、《中日商約》等，亦作出相同規定。參見王建朗，中國廢除不平等條約的歷程，頁12-13（2000年）；劉恆姣，從知識繼受與學科定位論百年來台灣法學教育之變遷，國立臺灣大學法律學研究所博士論文，頁77-78註42（2005年）。

前揭清朝的法制改革，幾乎可說就是引進日本的西方式法律。同樣受西方勢力威脅的日本，於1868年明治維新後即開始積極翻譯西方諸國法典、制定西方式法律¹³⁷。清末修訂法律的重臣張之洞、劉坤一、袁世凱等多以日本法學之風土人情相近、同文同種等「資取較易」之理由，偏重借鏡日本法律，同以歐陸式成文法典為範本，主其事的沈家本亦聘請松岡義正、志田鈺太郎、岡田朝太郎、小河滋次郎等日本籍為主的外國法律專家為顧問，故許多日本法律專家都參與了中國晚清之新法制定¹³⁸。清末中國因此把日本當做吸收西方法學的中繼站，以改換（漢字）讀音並加以解說的方式，將日本用漢字所創造出來的法律用語，大量吸納進本國的法制及法學內¹³⁹，並奠定後來民國時代中國在法學語言上的基礎，藉以發展中國的現代意義法學¹⁴⁰。

清末中國法學內涵之受日本影響，亦與當時法政人才的培育和任用有關。中國於晚清派遣學生出國學習法政，雖有遠赴歐美者¹⁴¹，但以前往日本者居多數。1903年張之洞擬訂的《獎勵游學畢業生章程》，對留學歸國者授予官銜（後來改為須經考核），以資鼓勵。因地利之便，出國留學者以前往日本者為多，而留日學生又以

137 詳細討論可參考山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁50-58。

138 參見程燎原，清末法政人的世界，頁198（2003年）；劉恆姣（註136），頁78；李貴連，近代中國法律的變革與日本影響，收於：近代中國法制與法學，頁79-80（2002年）。

139 中國清末主導法律改制工作的沈家本即承認：「今日法律之名詞，其學說之最新者，大抵出于西方而譯自東國」。沈家本，釋貸借，收於：沈家本撰，鄧經元、駢宇騫點校，歷代刑法考：附寄簞文存（四），頁2153（1985年）。

140 參見李貴連，中國近現代法學的百年歷程（1840年-1949年），收於：蘇力、賀衛方編，20世紀的中國：學術與社會·法學卷，頁221、245-246（2001年）。

141 清朝中國於1870年代由福建船政學堂首次派員赴歐留學，即有專習外交、法律和政治者；1907年《貴胄游學章程》，係規定貴胄遊學英美德三國，學習科目為法政或陸軍。1870年代清朝政府開始派出幼童留美，至少有1人習律；1909年起，以庚子賠款派遣學生赴美留學，其中亦不乏學習法政者。參見程燎原（註138），頁27-36；李定一，中美早期外交史，頁597-598註39（1978年）。

專攻法政科為大宗¹⁴²。日本方面也特別針對中國留學生設立一年期的法政速成科，如日本的法政大學即由日本民法權威梅謙次郎來主導¹⁴³，期期爆滿，為20世紀初期的中國培育出眾多法律人才。且於1905年「學仕合一」的科舉廢除後，除了前述赴國外留學生可授予官銜外，國內的法政學堂畢業生也依學校給予不同的官職獎勵¹⁴⁴。當時除了正規的大學教育，如北洋大學、京師大學堂等設有法科之外，沈家本、伍廷芳主張應仿效日本變法之初設速成司法學校，令官紳每日入校數時以專習歐美司法行政之學的先例，在京師設一法律學堂¹⁴⁵。於是從1904年至1909年，各省先後籌建法政專門學校就有22所，光是京師法律學堂，總計畢業生就接近千人，一時稱盛¹⁴⁶，蓋法科已取代科舉而成為入仕的最佳途徑。由於新式法制是由日本法律專家協助草擬的，故研讀充滿著漢字甚或已被翻譯成華文的日本法學著作，就成為有意邁向仕途者欲瞭解新式／西式法制內涵的重要方式。而日本在日俄戰爭中打敗俄國，更使得許多人相信日本的「立憲」措施確實有強國的效用¹⁴⁷。

綜上所述，不論是為了富國強兵、恢復司法主權（廢除領事裁判權），或是單純想要從政為官，清末中國都僅是將法學視為一種

142 根據1905年至1911年之統計，在日本專攻法政科者所占比率高達65%。參見浦伊蓮（Lilian Pudles）著，許苗傑譯，二十世紀初中國留日學生的法政教育，收於：《法國漢學》叢書編輯委員會編，法國漢學（第八輯）教育史專號，頁253、258-259（2003年）。

143 參見浦伊蓮（Lilian Pudles）著，許苗傑譯（註142），頁262-265。因清朝政府後來不贊同速成辦法，法政大學法政速成科僅從1904年至1908年開辦了5期。

144 1905年伍廷芳、沈家本等人奏請：「應將學律各員於畢業後，請簡派大臣詳加考驗，分別等差。其列優等者交部帶領引見。」關於法政學堂官職獎勵的個別規定，參見程燎原（註138），頁156-163。

145 參見湯能松、張蘊華、王清雲、閻亞寧編著，探索的軌跡——中國法學教育發展史略，頁128（1995年）；程燎原（註138），頁16-17。

146 參見湯能松、張蘊華、王清雲、閻亞寧編著（註145），頁128-135。

147 參見李劍農，中國近百年政治史（上冊），頁232（1957年）。文中指出，日本的立憲政治，雖然還不曾得到真正的民權自由，但是先打敗中國、又打敗俄國，彷彿一紙憲法，便可抵百萬雄兵。

具有實用性的工具。其所扮演的角色幾乎與傳統上為了在官僚體系內引用律例辦事而發展的「律學」並無兩樣，雖兩者在內涵上實屬不同。亦因此現代意義的法學於中國剛萌芽之時，尚未將其單純地視為一項學問或學術領域來研究。

1911年10月10日中國爆發革命，建立中華民國軍政府，引進源自西方之現代型民主共和的國家體制，以及現代型法律與司法體系，再於1912年1月1日在南京建立中華民國臨時政府，清朝皇帝退位¹⁴⁸。惟中華民國在北洋政府時期（1912-1928）主政者大多是前清遺臣¹⁴⁹，且民國初立之際，國家組織與法制均尚未完備，故經常即援用前清之制度¹⁵⁰。在北洋政府10餘年執政期間，大多數的西式法典仍處於草案階段，不過也不乏屬於修正版的法典草案被提出，此因法學教育已較前清時更為發達。按當時法政學堂的畢業生，在擔任公職上仍享有一定優惠待遇，故使得有志為官者心嚮往之，法政學堂的數目也持續增多¹⁵¹，有助於現代法學知識的傳播。

148 其詳，參見展恒舉，中國近代法制史，頁111-116、118（1973年）。從中華民國軍政府司法部的佈告第1號起頭即言：「竊自明季失綱，漢族凌夷，滿清乘勢，僭在中夏」，可知此一建國行動實帶有漢族發動種族革命的性質。佈告原文參見展恒舉（同註），頁112-113。

149 「北洋政府」一詞並非法制上名稱，在本文係用以總括自中華民國第一任總統袁世凱將首都設置於北京後，由不同人執政之在北京的中華民國政府。「北洋」之名源自清末袁世凱組建的「新建陸軍」，一般稱之為「北洋新軍」；由於實質上控制在北京的中華民國政府者，均出身北洋軍閥，故統稱為「北洋政府」。在中國史上，1912年4月到1928年6月這段期間，可稱為「北洋政府」統治時期。

150 最明顯的是，清朝新政改革後之民刑各法律草案及法院編制法等，除刑律中有關帝室、內亂罪等有悖民國國體的規定不能適用外，其餘均暫時繼續有效。參見國史館中華民國史法律志編纂委員會編，中華民國史法律志（初稿），頁57（1994年）。其根據為1912年3月10日袁世凱的《臨時大總統令》咨請參議院議決，頒布「從前施行之法律及新刑律，除與民國國體抵觸各條應失效力外，餘均暫行援用」之令。參見司法行政部民法研究修正委員會編，中華民國民法制定史料彙編（下冊），頁1（1976年）。

151 北洋政府於1912年11月將清末法政學堂更名為專門學校，且飭令有名無實之學校停止辦理，以整頓過於浮濫的法政學校，但直到1919年才使得私校浮濫等狀況逐漸緩和。參見葉龍彥，清末民初之法政學堂（1905-1919），中國文化

就在民初中國尚欠缺完整的新式／西式法典的情形下¹⁵²，法學界形成了獨尊西方法／比較法的學風。按當時的法學研究幾乎是以服務法律實務工作為目標，而法律實務工作者原應是適用本國的法律，奈何本國法上經常欠缺所需要的相關的法律規定；在必須找到相關的法律來作為判斷依據的情況下，最便捷的方法就是將法制上繼受母國，亦即西歐諸國或日本的法律，當作是本國法律來適用。例如，當時竟曾以「精通外國語言」，特別是歐陸語言，作為國立大學或專門學校法科畢業生，能否免試擔任以適用本國法為職責的司法官的要件之一¹⁵³。民國時代中國法學之以西方法／比較法作為新式立法或司法的典範，或者說以之作為法律或法學論證上的根據，可謂係源自此一歷史情境。

然而，扮演著向中國傳遞「西方法」之角色者，最主要的國家還是同在東亞的日本；可以說北洋政府時代的中國法學，仍籠罩在日本法學底下。按當時中國已出現許多介紹及討論日本民法、刑法、商法、訴訟法的書籍，但這些書籍的刊行，並不意味著法學上的討論在中國業已蓬勃興盛，蓋其只不過是為了迎合準備參加法官考試者之需要而已¹⁵⁴。不過在眾多翻譯書籍中，不乏高水準的著

學院史學研究所博士論文，頁187-189、210（1974年）。

152 如民事實體法方面，並未直接施行清末已完稿但尚未施行的近代西方式民法典，而是由大理院在司法案件中以「條理」（即今所稱「法理」）為名，有限度地引進近代西方式民法理念。北洋政府時代的民事法的內容，參見楊鴻烈，中國法律發達史，臺1版，頁1057、1167-1242（1967年）。

153 《法院編制法》以專章規定「推事及檢察官之任用」，欲擔任司法官者，原則上須經專業考試及格。且仿效當時的日本，採兩試制，即第一試考法學專業知識，通過者分發為學習司法官，之後再以第二試考驗學習成績，及格者即具有司法官資格。但是，如有1. 國立大學或專門學校本科修法律3年畢業，成績卓著且精通外國語言、2. 在外國大學修法律之學3年以上畢業，成績卓著且留學日本者須精通歐洲一國語言、3. 曾在國立大學或專門學校教授司法官考試主要科目任職5年以上，且精通外國語言等任一種情形，再經司法官再試典試委員過半同意，即可免試擔任司法官。參見王泰升（註129），頁134-135。

154 參見孫慧敏，從東京、北京到上海：日系法學教育與中國律師的養成（1902-1914），法制史研究，3期，頁168（2002年）。

作。最典型的代表就是民法學，其中號稱明治法學三博士之一，日本民法大家梅謙次郎（前述日本法政大學校長）所著的《民法要義》，包含總則、物權、債權、繼承、親屬五部，從1910年起，由著名學者孟森等人執筆翻譯，1913年全部出版，一直到1920年代，仍不斷重版；又，代表1920年代日本法理學界重要研究成就，穗積陳重所撰寫的《法律進化論》，也通過翻譯介紹到中國來¹⁵⁵。在本國的法制跟法學尚未健全的情況下，北洋政府統治下的中國乃是透過日文法學著作的翻譯來理解、建立現代法學。

不過，北洋政府時期中國法學教育已有相當大的進步，並形成著名的「北朝陽、南東吳」。朝陽大學創立於1912年，其淵源可追溯到清末的北京法學會，於民國創建後該法學會的汪有齡糾合同仁，在北京集資創辦朝陽大學¹⁵⁶。朝陽大學以「創設專門法科大學，養成法律專門人才」為創校宗旨¹⁵⁷，該校學生考上司法官比例甚高，時常超過錄取人數的三分之一，其他司法人員也大量出身朝陽，故素有「無朝（陽）不成（法）院」、「無朝不開庭」之美譽¹⁵⁸。基本上朝陽大學採取歐陸法系的法律教育方式，注重法典的學習和理論的研究，並曾聘請岡田朝太郎、巽來次郎、岩谷孫藏等日本教授來任教，中國教師則有留學英、美、日、德等國之學者¹⁵⁹。朝陽大學並自1917年起，將歷年學生所整理的各科教授的口授講義匯集並加以出版《朝陽大學法律科講義》¹⁶⁰，成為當時司法考試的重要資

155 參見李貴連（註140），頁288-289。

156 參見李貴連，20世紀初期的中國法學（續），收於：近代中國法制與法學，頁218（2002年）。

157 參見邱志紅，朝陽大學法律教育初探——兼論民國時期北京律師的養成，史林，2008年第2期，頁48（2008年）。

158 由於朝陽大學辦學認真、司法官考試錄取率高，從北洋政府一直到國民政府時代，都曾多次獲教育部、司法部之褒獎。參見邱志紅（註157），頁49；劉恆奴（註136），頁117註187。

159 參見邱志紅（註157），頁49-50。

160 李祖蔭、王選、王懋麟、徐家相校勘，朝陽大學法律科講義：法學通論——法院編制法，6版，初版序頁1、再版序頁1-2、五版序頁1、六版序頁1（1927

料，總計有29種，足堪代表1910年代中國法學知識的內涵¹⁶¹。該校並於1923年創辦《法學評論》雜誌，介紹司法界的動態以及中外學術研究成果，成為北洋時期的法學權威刊物。

在南方的東吳大學法科，為民初中國另一個法學重鎮。東吳大學係1900年由美國基督教監理會在蘇州創立，是中國史上第一所民辦大學¹⁶²，並於1915年在上海成立東吳大學法科（1927年更名為法學院）。由美國教會創辦且身處施行華洋混合法庭的上海，使得東吳大學法學院的教學方式朝向英美法系法律人的訓練，採取美國的個案研究法，教材則以英美法及中國法為主，要求學生定期去中國、英、美以及混合法庭學習；一般也認為該校以培養執業律師著稱，迥異於前述的朝陽大學¹⁶³。東吳法科最初所聘請的外國教師多為美國籍律師或法官，而中國教師如王寵惠、吳經熊等人也都是當時中國法界名人¹⁶⁴。東吳法學院並於1922年至1937年間，出版了《法學季刊》，走獨特之中西合璧路線¹⁶⁵，分成華文的《法學季刊》與英文的*The China Law Review*兩部分。

總之，中國在民初法制尚未完備的狀況之下，學習法政之人或在朝擔任司法官或在野擔任律師，仍吸引相當多知識分子投入。儘管其目的某程度是實用取向，但以北朝陽南東吳為代表的法政教育，也刺激了中國法學的發展。同時，許多在歐美或在中國接受西

年)。

161 包括法學通論、法院編制法、憲法、比較憲法、行政法、民法總則、債權總論、債權各論、民法物權、民法親屬編（兩種）、民法繼承編、刑法總則、刑法分則、商人通例、商行為編、公司條例、票據法、海船法、民事訴訟法、強制執行法、破產法、平時國際公法、戰時國際公法、國際私法、監獄學、中國法制史、羅馬法等。參見李祖蔭、王選、王懋麟、徐家相校勘（註160），例言頁1；王泰升（註129），頁113註7。

162 東吳大學網站，<http://www.scu.edu.tw>（最後瀏覽日：2016年9月30日）。

163 參見邱志紅（註157），頁48；湯能松、張蘊華、王清雲、閻亞寧編著（註145），頁245-246。

164 參見李貴連（註156），頁219。

165 劉恆奴（註136），頁160。

式法政教育者，例如張君勱、王世杰、錢瑞升、吳經熊、楊鴻烈等，於1910年代後期、1920年代已漸次在當時中國的法政論壇上嶄露頭角，並使得中國法學面貌為之一變，故具有純粹學術意義的中國在地的新式／西式法學，可謂係濫觴於此¹⁶⁶。

（二）戰前中國的法釋義學與「黨國法學」（1928-1945）

由國民黨所創建的「國民政府」，係於1928年形式上統一中國，取代北洋政府而成為中華民國政府¹⁶⁷。惟該國民政府於約20年後之1948年5月20日，將其職權移交給行憲後的總統¹⁶⁸，即在中華民國法制上消失了，合先說明。國民黨人在取得中國政權後，將先前北洋政府時代既有的法典草案，經部分修改後頒行全國。從1928年起，國民政府陸續公布施行《中華民國刑法》、《民法》、《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》、《公司法》等等自清末即起草的新式法典，完成了俗稱的「六法體系」。

166 張君勱於1906年赴日本早稻田大學攻讀政治經濟，返回中國後再於1913年赴德國柏林大學專攻政治學，而於1915年回中國擔任上海《時事新報》總編，1917年起在北京大學教書。參見薛化元，民主憲政與民族主義的辯證發展——張君勱思想研究，頁22-28（1993年）。王世杰1920年於巴黎大學取得博士學位，1927年起活躍於國民政府。錢瑞升1924年自哈佛大學返國，任教於清華。吳經熊畢業於美國密西根大學，亦於1924年回中國任教於東吳。楊鴻烈1927年起任教於南開大學，後又任教於復旦大學、法科大學等。有論者稱王世杰、楊鴻烈、錢瑞升、吳經熊、張君勱等人為中國第二代法學家，而將清末的沈家本、伍廷芳、梁啟超等人稱為中國第一代法學家。參見許章潤，書生事業：無限江山——關於近世中國五代法學家及其志業的一個學術史研究，收於：許章潤編，清華法學·第四輯：二十世紀漢語文明法學與法學家研究專號，頁42-43（2004年）。

167 在中國史上稱為「國民政府」者達5個之多，亦即：1. 廣東國民政府（1925-1926）、2. 武漢國民政府（1926-1927）、3. 南京國民政府（1927-1937，1945-1948）、4. 重慶國民政府（1937-1945）、5. 汪精衛南京國民政府（1940-1945），在此所論述的是，當時普遍地被承認為「中華民國政府」的前揭3. 與4. 所稱國民政府。從國際法上政府繼承而言，中華民國國民政府於1928年繼承了原為國際所承認的中華民國北京（北洋）政府。

168 依國民政府制定的《訓政結束程序法》，國民政府主席及軍事委員會原有職權，於1948年5月20日依新憲法產生之總統就職後，移轉至該總統，國民政府底下五院之職權，亦分別移轉至依新憲法產生之五院。

由於國民政府所頒行的上述法典，基本上係繼受近代西方，特別是歐陸的法制，故歷經北洋政府時代之自日本和西歐引進的西方式、現代法學，仍在中國持續發展。就在各種法典一出爐後的1930年代和1940年代，上海一地即已出版了眾多立足於中華民國法律，而論述一般法律概念、或憲法、行政法等公法概念之法學書籍¹⁶⁹，不再如清末民初般僅以翻譯日本等外國法律為主。當時的上海也出版了一些法學叢書。例如：（1）於1936年上海法學編譯社長吳經熊曾主編「現行法律釋義叢書」，由上海會文堂新記書局出版，共20種。該叢書的撰寫者，包括如吳經熊、史尚寬、洪文瀾、黃右昌、王效文、余承修等等中國的法學者，故已相當完整地蒐羅1930年代中國法律條文以及學界或實務界的法律見解。（2）於1938年上海法學編譯社編有「法學叢書」，由上海會文堂新記書局出版，共計40種，具體呈現1930年代中國對法律學所認知的內涵及其程度。（3）於1935年王雲五、徐百齊曾主編「實用法律叢書」，由上海商務印書館出版，共計20種，以對於當時中國現行法律條文的釋義為主，學說及立法例從略，其同樣記錄了1930年代中國的法律條文及實務見解¹⁷⁰。

¹⁶⁹ 關於一般法律概念的論著，除既有的前述朝陽大學法律科講義以外，尚有：
1. 歐陽谿，法學通論，6版（1937年）。該書初版的出版年月不詳，但可推論其存在於1920及1930年代。
2. 樓桐孫，法學通論，臺2版（1953年）。此書初版為1940年。關於公法的論述有：
1. 張知本，憲法論（1933年）。
2. 阮毅成，中華民國訓政時期約法（1935年）。
3. 吳經熊、金鳴盛，中華民國訓政時期約法釋義（1936年）。
4. 錢端升等，民國政制史，增訂2版（1946年）。惟此書初版日期待查。
5. 王世杰、錢端升，比較憲法，增訂8版（1947年）。惟此書初版及歷次修訂之日期待查。
6. 范揚，行政法總論，7版（1948年）。此書初版為1935年。
7. 趙琛，行政法總論，新1版（1946年）。但此書係後述上海法學編譯社所編「法學叢書」之一，故在1938年時業已出版。

¹⁷⁰ 上述在上海所出版的民國時代中國法學論著，美國西雅圖華盛頓大學法學院圖書館均有收藏。「現行法律釋義叢書」包括了關於約法、民法總則、民法債權通則、民法債權分則、民法物權、民法親屬、民法繼承、土地法、公司法、票據法、海商法、保險法、刑法總則、刑法分則、民事訴訟法、刑事訴訟法、破產法、強制執行法、法院組織法、訴願法等法律的「釋義」。「法學叢書」所涵蓋之學科，除上述「現行法律釋義叢書」已出現者外，還包括法

不過，當時的中國尚處於嘗試建立自身法學的階段。例如刑法學，就被認為是「移植刑法學」，亦即對於歐陸、日本的刑法學說不加分析批判，盲目地全盤移植¹⁷¹。於1940年代後期已有中國的法學者指出，當時中國的法學貧困，有三種怪物：只重視學位的「形式主義」、只重視留學海外的「超形式主義」、只重視將外語能力視為可像一把刀般割取外國法以為本國之用，而不探究外國法生成因素或配套條件的「刀的外語觀」¹⁷²。然而與此併存是，法律實務工作者在法學界具有相當重的份量，例如刑事訴訟法的大家夏勤、陳瑾昆等人，皆擔任過推事、庭長，後來也在各大學擔任教職¹⁷³，傳世的重要著作多屬於通論、教科書性質，對於刑事訴訟法的體系建構有相當的貢獻。以上現象正顯示中國自清末以來，視法學為「實用」之學的傳統觀念仍然留存，故為了實務上須解釋適用抄襲自外國的本國法律條文，而迫不及待地引進外國的法釋義學。

民國時代中國的法學著作，屬於專論式專書或個人論文集者甚少。若觀察1911年至1949年的中國法學著作書目，可發現書籍總數高達4千多件，領域也十分廣泛；不過屬於法規彙編者為數頗多，而學術著作雖占有相當數量，但絕大多數都是通論性質、法規釋

學通論、憲法論、刑法比較學、羅馬法、商事法概論、勞工法論、行政法總論（趙琛（註169））、行政法各論、國際公法論、國際私法論、國際私法本論、法律哲學、法律哲學研究、刑事政策學、法律思想史、中國法制史、犯罪心理學、犯罪搜查學、民事證據論、犯罪學、監獄學、社會法律學、政治學原理、經濟學原理。

171 參見李貴連（註140），頁305。

172 參見蔡樞衡（註135），頁94-97。根據蔡樞衡的說法，所謂外語能力就是學問，只對於以外語為目的的人方是真理，這是顯而易見之事。所以比較開明一點的人，不唱「唯外語觀」，只認為外語對於法學人士是一把刀，這可名之為「刀的外語觀」。然而，假使認為學外語的過程，只是一個剽竊他人成熟園果田禾的過程，那麼外語可以算是刀；假使認為學習外語的過程，是在把握它的成果，並且考察成果發生成熟的經過和一切有關的條件或事物，以作為自己培植之借鑑，那麼外語只是到達特定園地去參觀的路線中的一座橋樑，決不是一把刀。

173 參見陳瑞華，二十世紀的中國刑事訴訟法學，收於：李貴連編，二十世紀的中國法學，頁96-105（1998年）。

義，或是介紹外國法制¹⁷⁴。不過，作為一個繼受外國法制的國家，這好比自外國進口一部機器，有必要先用本國語文寫出操作手冊，讓使用此機器的作業員看得懂、能順利運作¹⁷⁵。因此一開始難免過於重視外國法制以及法條的釋義，不經歷此一過程恐怕也難以建立起自己的法學，或許可用這樣的同情性理解來看待此時期中國法學的發展吧。

然而，國民政府時期的中國，同時步向偏離西方自由民主原則的訓政體制。1928年起國民黨開始實施「訓政體制」，以進行「黨治」。所謂「訓政」，簡單說就是由領導革命的「黨」來「訓導」人民何謂民主¹⁷⁶。迨1931年《中華民國訓政時期約法》公布施行，已明文承認國民黨在國家體制內具有指導監督政府的地位，將「黨治」原則國家法化¹⁷⁷。惟「黨治」原則與西方憲政主義認為法律之執行須超越行政考量而揭櫫的司法獨立原則，有其相矛盾之處。按在中華民國初立時所制定的《臨時約法》係採取美國式的三權分立，並以「法院」作為有關司法權專章的章名，明定「法官獨立審判」，其後北洋政府不論在袁世凱或是其他軍閥主導之下，形式上仍保留西方之三權分立制底下由法院行使審判權的規定¹⁷⁸。但國民政府主政後，依五權憲法概念設置了司法院，且認為司法權是五種治權之一，應受到由國民大會所行使的「中央統治權」所監督控制；而該中央統治權於訓政時期依《中華民國訓政時期約法》之規

174 民國時期的法學出版物，可參考北京圖書館編，民國時期總書目（1911-1949）：法律（1990年）。

175 這個比喻的進一步詮釋，參見王泰升（註3），頁321。

176 參見王泰升，國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁109-111（2009年）。

177 根據《中華民國訓政時期約法》第30條：「訓政時期，由中國國民黨全國代表大會，代表國民大會，行使中央統治權。中國國民黨全國代表大會開會時，其職權由中國國民黨中央執行委員會行使之。」參見王泰升（註176），頁124-126。

178 參見王泰升（註129），頁123-124。

定，係由中國國民黨代表國民大會行使之¹⁷⁹。因此訓政時期約法內連表面上規定「司法獨立」都省了¹⁸⁰，倒是令擁有統一解釋法令權的國家司法機關，包括審判和檢察系統，都應向單一政黨負責，不同於西方憲政主義所強調的司法不應該受政黨干涉。

訓政時期中國的法學論述，因而改以「黨治」理念，詮釋司法權之運作。例如國民黨於1929年即決議：「司法官吏之任用，必須以深明本黨主義為標準」¹⁸¹，而當時頗富盛名的法學者王寵惠，於1929年亦在〈今後司法改良之方針〉一文中表示：「宜進司法官以黨化也。……（1）網羅黨員中之法政畢業人員，……以備任為法院重要職務，俾得領導僚屬，推行黨治。（2）訓練法政畢業人員，特別注意於黨意，備期嫻熟，以備任用。（3）全國法院一律遵照中央通令，實行研究黨意，使現任法官悉受黨意之陶鎔，以收黨化之速效」¹⁸²，在訓政體制底下當時中國一流的法學者都這樣說了，無怪乎時任國民政府司法院院長的居正於1935年曾「大義凜然」地表示：「在『以黨治國』一個大原則統治著的國家，『司法黨化』應該視作『家常便飯』」；且具體地解說所謂司法黨化，一是「司法幹部人員一律黨化」，一是「適用法律之際必須注意於黨義之運用」，亦即「把一切司法官都從那明瞭且篤行黨義的人民中選任出來。……並不是司法『黨人化』，乃是司法『黨義化』」¹⁸³。」在此政治大環境底下，法律實務見解自然向國民黨的意識型態及政黨利益傾斜。

179 相關的概念及其在訓政時期約法上的規定，參見王泰升（註3），頁134。

180 國民政府在1936年公布的所謂「五五憲草」，於第80條規定：「法官依法律獨立審判」，但其終究未正式施行。參見韓秀桃，司法獨立與近代中國，頁398-403（2003年）。國民黨人似乎認為，須進入憲政之後始願尊重司法獨立。

181 參見中國國民黨，關於司法制度之完成及其改良進步之規劃案——民國十八年六月十七日通過，收於：秦孝儀編，中國國民黨歷屆歷次中全會重要決議案彙編（一），頁131（1979年）。

182 王寵惠，今後司法改良之方針（一）（1929年3月3日），收於：張仁善編，王寵惠法學文集，頁285-286（2008年）。原載於：法律評論，6卷21號（1929年）。

183 參見居正，司法黨化問題，東方雜誌，32卷10號，頁6-7（1935年）。

在此所稱的「黨國法學」，於焉出現。當時中國的法學者幾乎都受過以西方法為內涵的現代法學教育，故面對有別於西方憲政主義的訓政體制時，有時即企圖援用西方法學理論來自圓其說，甚或穿鑿附會。例如上述的司法黨化，居正就引用1930年代德國的法學者Kelsen所提出之須靠司法（裁判）來實現法律之規範目的，以及引用當時美國的唯一論者所主張之法律乃是由法官所決定的規則等等，來論證不只是立法須依黨意，司法亦有加以黨化的必要，故司法官在具體辦案過程中必須時刻注意黨義之運用¹⁸⁴。

訓政體制與黨國法學實互為體用，也唯有反訓政、反黨治者方能跳脫黨國法學的泥沼。當時中國的法學者雖仍然沿用西方法的概念，但遇到本國法和西方法實在有所扞格時，亦可能認為此乃五權憲法之特殊概念，自然和西方不同。且訴諸「黨治精神」、「訓政體制」，好像就足以正當化將一切人民權利與政府權力全歸之於國民黨的作法。例如吳經熊曾表示：「訓政時期尚未脫離黨治，故一切訓政方針與政策，自當由中國國民黨的權力機關從中主持。¹⁸⁵」然而，由國民黨當權派所主導之訓政時期各項法制變革，為遷就現實上權力分配需求或妥協於政治鬥爭之結果者多，出於改良政府體制設計之目的者少。因此自1930年代起，國民黨內外即有要求結束訓政、黨治之主張者，成為一片黨國法學底下少數的不同聲音，例如胡適對於當時主政者之欠缺法治素養，即以「口口聲聲說『訓政』，而自己所作所為皆不足為訓」，嘲諷之¹⁸⁶。

184 居正因此要求法官做到：「（一）法律所未規定之處，應當運用黨義來補充他；（二）法律規定太抽象空洞而不能解決實際的具體問題時，應當拿黨義去充實他們的內容，在黨義所明定的界限上，裝置法律之具體型態；（三）法律已經僵化之處，應該拿黨義把他活用起來；（四）法律與實際社會生活明顯地表現矛盾而又沒有別的法律可據用時，可以根據一定之黨義而宣布該法律無效。」居正（註183），頁11-12、16。

185 吳經熊、金鳴盛（註169），頁119。

186 其詳，參見王泰升（註176），頁150-154、198-199。

1937年爆發中日戰爭，中國從此進入長達8年的戰爭體制，使黨國法學更加鞏固。日本學界認為，日本以1938年制定《國家總動員法》為指標，確立其法西斯法體制¹⁸⁷；同樣地中國自戰爭爆發後，亦實施眾多戰爭時期的法規，包括於1942年仿效日本前揭《國家總動員法》，而制定實質內容與之相似的中國的《國家總動員法》。戰時中國法制既是如此，原本即習於參考日本法學著作的當時中國法學界，也就亦步亦趨地朝向法西斯化發展。按1937年以後中國的法學論著，已出現大量關於戰時體制的各類叢書，如中國新社會編輯的「非常時期叢書」（1936年起）、中華文化建設協會的「抗戰小叢書」（1937年起）、正中書局的「戰時民眾訓練小叢書」（1938年起）、軍事委員會的「抗戰建國叢書」。作為戰爭法的特殊性格是，重刑、簡略、法規不經立法程序直接由國民政府施行公布等等¹⁸⁸，且為求戰爭的勝利，著重政府的效能，人民的權利必須有所犧牲；法學論著對此鮮少批判，反而是著重向人民宣導，該抗戰小叢書的發刊旨趣就明示：「灌輸抗戰的知識和技能，藉以引起抗戰情緒，充實抗戰實力」¹⁸⁹。且「黨治」原則也受到進一步的強化，身兼國民黨總裁、國防最高委員會委員長（黨）及軍事委員會委員長（國）的蔣中正，已成為戰爭時期黨政軍權力集中的唯一核心人物¹⁹⁰。當時即有論者指出，「一到戰時，就感覺到群龍無首。

187 參見山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁24。

188 參見張彝鼎，戰時法律概要，軍事委員會戰時工作幹部訓練團編，「抗戰建國叢書」，頁5-6（1938年）。當時的日本亦建構一個依據行政機關的命令來運作的經濟統制法體系。參考山中永之佑等著，堯嘉寧等譯（註5），頁26。

189 潘公展，本叢書發刊旨趣，收於：全國圖書館文獻縮微複製中心編，抗日戰爭時期中國國情史料匯編（13），復刻版，頁3-4（2006年）；原收於：陳端志，抗戰與民眾訓練，中國文化建設協會編，「抗戰小叢書」，旨趣頁1-2（1937年）。

190 1933年設置的「國防委員會」即有取代中央政治會議而成為決策核心之勢，1937年設立的「國防最高會議」決議將中央政治委員會之職權「暫時停止」，並由其「代行」，已儼然變成戰時統治機構。1938年國民黨臨時全國代表大會決議設立「總裁」，「代行」總理職權，其對於中央執行委員會的議決有最後

所以最高決策所自出之黨，決斷權自必出於一人。¹⁹¹」戰爭時期中國的法政體制就在既有一黨專政的基礎上，加強專政的色彩，形成法西斯化的黨國法學，導致戰前中國的法學發展更加無法擺脫當權者的掌控。

民國中國的政治現實，讓留學國外的法學者不易發揮所長。在國民政府主政時期，研究法學之人已從過去以留學日本為大宗，逐漸增加了前往美國及歐洲等地留學者；分赴不同國家留學，即各自帶回其留學國的典章制度及法學理論，形塑出多樣化且分歧的法學知識內涵¹⁹²。惟相較於中國的眾多人口，赴國外進修的法學者人數還是非常的少，且其在政治動盪不安，執政當局擬以其黨國意識型態一統思想的大環境下，回到中國後或無從一展長才，或不再堅持在國外所習得的法學理論。例如徐道鄰於1930年代初期在德國專攻憲法學且備受肯定¹⁹³，但其返國後對中國政治的失望¹⁹⁴，似乎使

決定權，並為中央常會之主席。換言之，恢復了國民黨在1925年孫文逝世後即取消的首領制，而由身為總裁的蔣中正獨斷。1939再以「國防最高委員會」取代國防最高會議，其設委員長一人，由國民黨總裁任之。1943年蔣中正再接任國民政府主席，其已集一切權力於一身。其詳，參見王泰升（註176），頁140-149。

¹⁹¹ 潘公展，戰時政治制度，頁31（1938年）。

¹⁹² 在西方法學界享有盛譽的美國哈佛大學法學院教授龐德（Roscoe Pound），受國民政府的邀請來為中國法律教育把脈時，曾於1947年提出：「像中國對於法官、法律教師及法學家的訓練那樣紛歧的情形是很特出的。這裡的立法者、法學家、法官、法律教師，有些受教於美國，有些在英國，有些在法國，有些在蘇格蘭，有些在德國，有很多經由日本間接受德國的傳統。不特如此，在國內受訓練的人，也並不本於一個傳統去研究法典。」龐德，中國法律教育改進方案，收於：張文伯編，龐德學述，頁170-171（1967年）。當時亦有中國的法學者指出，就中國法學的發展進程而言，於二次大戰結束時，大約是留日、留英美、留歐者的作風共處一堂，互相補益、也互相形剋。參見蔡樞衡（註135），頁93。

¹⁹³ 徐道鄰前往德國專攻憲法學，1931年獲得柏林大學的法學博士學位，其博士論文〈憲法變遷〉受到德國最大出版社之一Walter de Gruyter & Co.的青睞加以出版問世，許多同時代取得博士學位法學者，當時並未受此殊榮而得以出版論文，日後卻成為德國公法大家者也所在多有。1932年徐道鄰又在德國最重要的公法刊物《公法文摘》上，發表一篇重要的憲法學著作：〈形式主義與反形式主義的憲法概念〉，在當時人才輩出的德國法學界裡，獲得盛大的名聲。

其放棄造詣甚深卻與政治密不可分的憲法學，轉往中國古代法制史的領域發展。至於中國著名法學家、曾擔任海牙國際法庭法官的王寵惠，早年留學日本、美國，曾將德國民法譯為英文，且在耶魯大學留學時對孫文倡導的五權憲法已有所質疑¹⁹⁵。然王寵惠回國後，1928年出任國民政府創建司法院後的第一任院長，卻成為論述五權憲法要義的權威¹⁹⁶，且如前所述大談黨化司法，還參與採取五院制、權力集中於黨國之訓政時期約法的擬定。於1948年，當國民黨人為了擬擴張總統權力又礙於憲法才剛施行不宜修改而苦惱時，亦由王寵惠獻策以制定「臨時條款」的方式實質修憲¹⁹⁷，其接著出任行憲後司法院的第一任院長。王寵惠在其參與政治的過程中，到底能實踐多少自西方習得的自由主義憲政理念呢¹⁹⁸？

二、大幅移植民國中國小量繼承日治臺灣的法學經驗

不同於日本帝國之在臺灣採取殖民地式的特別法制，1945年起統治臺灣的國民黨政權視臺灣為「中國一省」，採行與中國內地無大差異的統治體制及法律。國民黨政權於1945年10月25日，係由「中國臺灣省行政長官兼警備總司令」陳儀，遵照戰勝的同盟國

參見陳新民，驚鴻一瞥的憲法學彗星——談徐道鄰的憲法學理論，收於：公法學劄記，修訂2版，頁213-214（1995年）。

¹⁹⁴ 徐道鄰返國後服務於軍、政機構欲報其父仇，但在當時中國政治傾軋，各方勢力激烈角力的時代，徐氏欲藉仕途報仇雪恨之事並不順遂。關於徐樹錚與徐道鄰父子之故事，參見王覺源，徐樹錚與徐道鄰父子，收於：近代中國人物漫譚，頁429-450（1989年）。

¹⁹⁵ 在某個為紀念王寵惠而舉辦的座談會上，依據與會者鄭彥棻的回憶，孫文於1920年及1921年的兩次演講中都曾提到，1904年其和王寵惠在紐約曾談到五權憲法，王寵惠很贊成，後來王寵惠到耶魯大學專攻法律，反疑惑起來，說這五權分立，各國的法律都沒有這樣辦法，恐怕不行。參見胡有瑞、劉本炎、盧申芳記錄，王寵惠先生百年誕辰口述歷史座談會紀實，收於：陳鵬仁編，百年憶述——先進先賢百年誕辰口述歷史合輯，頁194（1996年）。

¹⁹⁶ 參見劉寶東，法學家王寵惠：生平·著述·思想，收於：胡文俊編，王寵惠與中華民國，頁110（2006年）。

¹⁹⁷ 參見王家瑩，法學宗師——王寵惠的故事，頁53-56（1983年）。

¹⁹⁸ 參見劉寶東（註196），頁116-119。

「中國戰區最高統帥」兼「中華民國國民政府主席」蔣中正之命令，「接收臺灣、澎湖列島地區，日本陸海空軍及其輔助部隊之投降，併全權統一接收臺灣、澎湖列島之領土、人民、治權、軍政設施及資產。¹⁹⁹」此舉僅是依戰勝國的軍事接收而取得臺灣的統治權，關於國際法上臺灣主權之移轉尚有待戰後的國際條約處理²⁰⁰，但國民黨控制下的國民政府在中國國內法上已視臺灣為「一省」。由於國民黨認為臺灣經日本統治50年之後，縱令與中國內地有點差異，也不值得一顧，且可迅速抹去，故僅僅不設省主席，而設行政長官以綜理在臺行政事務並兼有在臺軍事權，但並無日治時期總督對臺灣地域的委任立法權（律令制定權）與司法行政監督權，臺灣在中國之內不具有特殊地位。國民黨在同樣的思維下，亦將當時中國（中華民國）法律立刻、全面地施行於臺灣，幾無針對臺灣社會的特殊情事而制定可排除中國內地之規定者，迥異於日本政權於治臺之初先一定程度接納臺灣舊慣²⁰¹。簡言之，國民黨政權無視於臺灣曾被另一個現代型國家有效統治半個世紀，一切法律措施幾乎都與中國內地各省一樣。這也使得在法學上，沒有必要針對臺灣特殊情事而發展出不同於中國內地的內涵。

外來的國民黨與前任政權一樣的是，政府高階管理階層幾乎都由「自己人」出任，而排斥臺灣在地人。相對於臺灣在地的福佬、客家、原住民族群因具「臺灣省籍」而稱為「本省人」，1945年戰

199 張瑞成編，光復臺灣之籌劃與受降接收，頁185-186、244-245（1990年）。

200 軍事接收某地不等於獲得該地的主權。例如戰後中國的遼寧、吉林、黑龍江三省由同盟國的蘇聯接收，越南北緯16度以北地區由中國戰區最高領帥蔣中正接收，此並不代表蘇聯獲得中國東三省、中國獲得越南北緯16度以北地區之主權。參見張瑞成編（註199），頁185-186。

201 日治後期採取了有別於前期舊慣溫存的「內地延長」主義，戰後初期來自中國的國民黨政權更大幅度地將中國內地的制度施行於臺灣，故可稱「內地延長的再延長」，只不過是從「日本內地」換成「中國內地」，但對臺灣而言都是另一個屬於國家核心地帶的「內地」。參見王泰升，臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」，頁47-76（2015年）。

後從中國內地各省來到臺灣者稱為「內地人」（此詞彙頗盛行於戰後初期的臺灣）或「外省人」。當時行政長官公署內一級單位正副首長18人中，僅有教育處副處長宋斐如1人為本省人，其餘皆外省人。行政長官公署直屬各機關16位主管中，僅僅較不重要的臺北保健館主任王耀東，以及天然瓦斯研究所所長陳尚文為本省人，其餘皆外省人。17個縣市首長中，亦只有臺北市長黃朝琴、新竹縣長劉啟光、高雄縣長謝東閔等3位本省人。且前面所提及的5位本省人中，除王耀東醫師外，皆戰前已至中國投靠重慶政府的所謂「半山」。即使算入親國民黨政權的半山，本省人在高階官員中仍屬鳳毛麟角，依行政長官公署改制為省政府之後的1947年9月為止的統計，最高階的簡任官之本省人與外省人比例為19：224²⁰²。從原受日本統治的本省人的觀點，這跟總督府時代差不了太多，不一樣的只有中國內地人取代以前的日本內地人²⁰³。

202 關於中上層官員，行政長官公署內各處股長以上總計316名官員中，也只有17名是本省人，所占比例約百分之五，其餘均外省人。至於中下層公務員固然以留任的本省人居多，但總數與日治時期略同甚至較少，反之外省人則急遽增加。1947年行政長官公署改制為省政府之後，雖省府委員15人中有7人、廳長4人中有1人（省府委員兼）、副廳長4人中有3人、處長3人中有1人，係屬本省人（11人中半山占6人），但是根據全臺公務員籍貫及職等之統計，即令改制後，薦任級以上的中上層公教人員，仍然「省籍」比例懸殊，且越往高層，本省人所佔比例越少。參見鄭梓，戰後臺灣的接收與重建——臺灣現代史研究論集，頁209-219（1994年）；湯熙勇，戰後初期臺灣省政府的成立以及人事佈局，收於：黃富三、古偉瀛、蔡采秀編，臺灣史研究一百年：回顧與研究，頁145（1997年）。原任高雄市長的連謀因貪污去職後，由本省人黃仲圖接任，其亦屬半山；此外，二二八事件發生時的高雄縣長，已非謝東閔，而是外省人黃達平。參見賴澤涵等，二二八事件研究報告，頁19、125、179註405（1994年）。

203 行政長官公署對於高階官員絕大多數是外省人，認為此導因於日本統治當局對臺灣人的歧視，使本省人欠缺擔任高官的資歷與能力。惟旅居中國重慶的臺灣人早已告知國民黨當局，在臺灣政府各部門工作的臺灣人，行政能力及經驗與日本人無異，只因種族關係而居下屬，故接管後應擢昇其為主管。且當時臺灣人受過中等教育的約有30萬人，受過大學專門學校教育的至少5萬人，故宜在臺灣舉辦特別的考選制度，准以日文作答，先選拔出有能力之人，再讓其學習中國語言。不過，視臺灣人說日語、寫日文為被「奴化」象徵的陳儀，斷然拒絕可以日文應試的建議，等於是透過語言的關係而歧視本

如同日治時期國家法制及法學係由日本人帶入，故其在法學界佔盡便宜，戰後的國家法制及法學既然是由外省人帶入，其至少在戰後初期的法學界也將擁有優勢。臺灣外省族群的人口數，因1949年中華民國中央政府遷臺而遽增，雖最終也不過僅佔臺灣總人口的13%-14%，但其在民國時代中國所經歷者或所抱持的文化觀念，卻成為戰後臺灣國定的歷史記憶乃至意識型態。在這樣力求與中國內地一致的中國化／去日本化政策下，本省人即難以縱向繼承之前日治下包括法學在內的法律經驗。

戰後臺灣法學教育機構的重整，具體而微的顯現出此一趨向。中華民國國民政府於同年11月15日接收臺北帝國大學，除將校名改為「國立臺灣大學」，並將原臺北帝大政學科改為法學院，分設法律、政治、經濟等三個學系。原本政學科的教師幾乎全為日本籍之男性，均遭遣返，無一留任；由於法學教師隨著國家的更替而全面換血，法學者的組成也進入另一個新的時代。按從中國內地來臺擔任臺大首任校長兼接收主任委員的羅宗洛，當時即揭示臺大「應中國化」，其「改造」方案為：文法學院「與思想文化有密切之關係，自應招聘國內〔按：指中國大陸〕優秀學者來臺講學，以圖宣揚祖國之文化。」故臺大雖於1945年12月中旬辦理招生，惟「文政學部須徹底改造，內地教授因交通困難暫時無法來臺，應暫緩招生」，以致尚未為法律學系招收新生²⁰⁴。不過當時雖無教師，卻有學生，原臺北帝大政學科的臺灣人學生亟待復學。這批學生乃主動為學校當局尋找適任教師，屬本省人且均畢業自東京帝大、原任辯護士的戴炎輝與原在日本內地擔任司法官的蔡章麟和洪遜欣，因而

省人，按日治下的臺灣人原本僅能以日語文學習現代知識。參見臺灣省行政長官公署民政處編，臺灣民政（第一輯），頁70（1946年）；鄭梓（註202），頁187-191、220。

204 參見曾士榮，從「台北帝大」到「台灣大學」，Academia——台北帝國大學研究通訊——，2號，頁4（1996年）；國立臺灣大學編，接收台北帝國大學報告書，頁18、21（出版年不詳）。

分別於1946年10月（戴炎輝）及1947年8月（蔡章麟和洪遜欣）受聘為臺大法律系教授。惟1946年12月就任臺大法律系系主任者，卻是來自中國大陸、屬外省人的洪應灶。1947年8月以及1948年，又加入了自中國大陸來臺的劉鴻漸（並擔任法學院院長）、安裕琨、孫嘉時、薩孟武（係政治系教授，新任的法學院院長）²⁰⁵。

相對於外省人被積極地延聘來臺任教，業經日本法學嚴格訓練、甚或曾從事教職的在地的本省人法學者卻未獲同等對待。按中國的法學者若至日本留學即被視為法學菁英，前述曾任臺大法學院院長的劉鴻漸與薩孟武，即均出身京都帝大法學士而在民國中國擔任法學教授，然而日治時期受過日本法學訓練且有教學經驗的臺灣在地法學菁英，戰後回到臺灣故鄉卻有截然不同的待遇。例如日治時期在滿洲國長春法政大學任教的林鳳麟、黃演淮、王朝坪，可能因其曾在日本帝國控制下的大學任教，而無緣在戰後臺灣獲得教職。日治時期似曾遭歧視、苦候教職終無所成的前述鍾壁輝等人，亦無法在日本人已離去的戰後「出頭天」²⁰⁶。只有如戴炎輝、蔡章麟與洪遜欣這樣在日治時期不曾任教的在地法律人，戰後較有機會進入大學法律系任教，特別是趁著尚欠缺來自中國大陸的師資之時，迅即獲取臺大教職並站穩位子。屬本省人且畢業自日本東北帝大的張燦堂，曾於1947年8月進入臺大法律系任教，惟不久即離職；另一位同屬本省人、亦於東京帝大畢業後曾在日本內地擔任司

205 戴炎輝：東京帝國大學法學士，日治時期在高雄擔任辯護士，戰後曾任高雄縣潮州郡郡守及高雄地方法院推事。蔡章麟：東京帝國大學法學士，日治時期擔任大阪地方法院庭長，戰後之初曾任臺灣省行政長官公署法制委員會委員及臺灣省政府法制室簡任參議。洪遜欣：東京帝國大學法學士，日治時期擔任廣島等地方法院法官，戰後之初曾任臺灣省行政長官公署法制委員編審。洪應灶：東吳大學法律系、美國印第安那州立大學法學博士。劉鴻漸：京都帝國大學法學士。安裕琨：柏林大學法學博士。孫嘉時：朝陽大學法學士。薩孟武：京都帝國大學法學士，其雖任教於臺大政治系（與法律系同屬法學院），但當時具有法政一家的傳統，且其曾發表許多從今之觀點屬於法學的論文。參見王泰升（註65），頁115-117、181-182。

206 鍾壁輝於戰後僅能在屏東縣立內埔中學擔任教師。陳昭如（註85），頁43。

法官的陳茂源，雖於1949年8月進入臺大法律系，但一直僅能講授非法律系的商法課程²⁰⁷。

本省人之所以不易在戰後法學教育機構內發揮所學，某程度與戰後整個政治大環境有關。日治時期所培育的臺灣在地法律人，由於戰後改行中華民國法且厲行中國化，而在戰後初期短短數年間即被壓縮至邊緣位置，最後被併吞於中國政府的人才框架內，成為一整個戰後被遺忘、被犧牲的法律人世代²⁰⁸。

相對的，屬外省族群的法學教師，因1949年中國政權易手的政治變局而在臺灣更加茁壯。就在中國大陸即將改由共產黨政府統治前夕，更多支持個人主義、資本主義法制的中國法界碩彥選擇渡臺，並於1949年或嗣後任教於臺大法律系。包括梅仲協、林彬、曾繁康、王伯琦、陳顧遠、林紀東等²⁰⁹。就在中國在1949年改由共產政權統治後，法制與法學全面改為社會主義式，許多留在中國大陸的中國法學者不但不能發揮法學專長，甚至面臨共產黨的鬥爭²¹⁰。因此前述民國時代中國所累積的法學傳統在中國大陸幾乎瓦解，但

207 參見王泰升（註65），頁166、182。在臺大法律系課程的歷年任課老師名單中，並未見陳茂源。

208 詳細的論述，參閱曾文亮、王泰升（註107），頁89-160。來自中國大陸的法律人才固然有法學素養精湛者，尤其不乏民國時代中國最頂尖的法學菁英，但也可能學養平平，僅因屬於當權者集團一員而獲教職。臺灣在地法律人才直接接受日本法學訓練，當然不能說全屬幹才，但因本省人的身分而遭埋沒者，恐亦不少。自幼習於日語的本省人法學菁英在使用戰後成為國語的華語上，不免有一定的障礙，但戴炎輝、蔡章麟與洪遜欣在獲教職機會後立刻能克服語言障礙，其他人難道就不能？

209 關於這些法學者到臺大法律系任教的時間及其學經歷，參見王泰升（註65），頁182、185-186。林紀東在訓政時期的中國，即已出版如《中國行政法總論》、《行政法提要》等書。參見林紀東教授追思紀念集編輯委員會編，高山仰止——林紀東教授追思紀念集，頁206（出版年不明）。

210 如留學哈佛大學法學院的楊兆龍，據說1948年「海牙國際比較法學研究所」列舉的50位全球法學家，楊兆龍與王寵惠皆榜上有名。然1957年6月，楊氏與其三名子女被打成「右派」，1963年被遣送青海勞教，1971年又再次遭到整肅，直至1975年才釋放出獄。參見許章潤（註166），頁52。

藉由國民黨政權以及中國法學者的渡臺而在臺灣存續下來，且如下所述與臺灣既有的法學經驗及人民相結合，開展出新的生命。

於戰後初期，即由兩批人共同組成臺灣「第一代法學者」。其一是較佔優勢之戰後從中國移居臺灣、屬於外省族群的法學者，例如前述任職於臺大法律系的法學教師。他們承載著民國時代中國法學內涵，亦即：（1）以日本法學為基礎而針對與日本法相近的中華民國法所為的法釋義；（2）經常自日本論著轉引源自西方的各種現代法學理論；以及（3）部分從歐美「直接進口」的外國法制及法學理論。其二則是勢單力薄之經歷日治臺灣、屬於本省人（福佬、客家）族群的法學者，除了前述戰後獲得教職者，還包括雖戰後無教職、但日治時期（自1920年代）即展現法學論述能力的前述林呈祿、鍾壁輝、林鳳麟等人²¹¹。他們承載著日治時期臺灣的法學內涵。若與前一批法學者相比較，這一批法學者對於前述（1）當中基於日本法學而對日本法所為的法釋義非常熟悉，並直接掌握前述（2）所指日文書寫的各種現代法學理論，且類似前述（3）的部分能透過語文能力引介外國法制及法學理論，例如蔡章麟德文造詣甚佳常藉以引介德國學說²¹²。

總之，戰後初期就在人才選拔上一定的遺憾下，匯合代表著民國時代中國和日治時期臺灣兩段經驗的法學菁英，而形成一個社群，此即第一代法學者，其法學內涵則是以沿襲戰前日本法學為主，並據以對中華民國法律條文進行釋義，偶爾梗概地論及外國法制。

211 雖然無教職者於戰後或為當道所排斥，或已難有發表法學論述的機會，但其確實具有法學論述能力，只能說其是一群沈默的法學者。

212 參見王泰升（註65），頁166-167。

三、戰後之初中國自由主義法學的乍現與消逝

臺灣在作為「中國一省」的情況下，其法制及法學發展自然是跟隨當時的中國而浮沈。在中國，1945年二次大戰民主國家對法西斯國家的勝利，更加堅定了中國自由主義者追求立憲政治的信心；而國民黨、共產黨兩大政黨以外的中間黨派，亦展現極高的政治參與熱忱，強烈要求實行民主憲政與法治²¹³。中國內部各黨派間的激烈較量，以及美國、蘇聯的外在壓力，使得國民黨同意於1946年召開由各黨派及社會賢達人士組成的「政治協商會議」，並提出了所謂的「政協憲草」，最後通過的《中華民國憲法》便是以政協憲草為基底²¹⁴。就在整個20世紀中，臺澎與中國大陸處於同一個政權統治下僅有的4年（1945-1949）²¹⁵，中國的自由民主憲政運動達到前所未有的高峰²¹⁶。作為其產物之一部具有自由憲政主義內涵的憲法典，竟讓數十年後、在不同時空下臺灣的法學者，得以援用其規定來落實臺灣的自由民主憲政，恐為當時任何參與中國制憲者所始料未及。

戰後初期的中國法學，因而展現了若干自由主義的色彩。例如

213 當時的民主同盟即認為，倘若政治是一人或一部分人專制獨裁，經濟是一人或一部分人的獨享獨占，便失去了民主意義；甚至宣稱：「在政治上實行英美式的議會民主制，在經濟上參照蘇聯的社會主義的公正平等原則。」參見石畢凡，近代中國自由主義憲政思潮研究，頁209、297（2004年）。

214 政協憲草由張君勱所草擬，雖然不符合國民黨的期待與要求，但是在當時國共情勢緊張的政治環境底下，最後國民黨仍妥協採用，並派王世杰、王寵惠、吳經熊等人加以修改後通過。五五憲草、政協憲草、1946年制定之憲法的內容與比較，可參考國史館中華民國史法律志編纂委員會編（註150），頁322-325。

215 在20世紀臺灣（臺澎）與中國之間的關係，簡要的講就是：1945年臺灣被中國納為一省，但在中國改由共產黨執政的1949年之後，臺灣不再是中國——中華人民共和國——的一省，而是由原在中國執政的國民黨，以原在中國施行的中華民國法制，在臺灣獨自運作一個國家。這項歷史因素導致1949年之後臺灣已成為事實上國家，但中國聲稱臺灣是其領土一部分。

216 然而，臺灣在這4年中，也發生了中國軍隊殘殺臺灣在地人的「二二八事件」。

當時關於憲法的討論，雖然仍有許多維持黨國法學的論調，但也可以聽到某些反對專制統治的聲音。當時的《大公報》即肯認1946年憲法草案之不採國民黨所喜歡的五五憲草版大權總統制，而規定行政院向立法院負責，使得政治責任在行政院，總統地位超然；並因此慨言憲法若不能讓政府向人民或人民代表負責，則所謂主權屬於國民全體只是一句空話²¹⁷。關於人民權利義務的部分，《大公報》則認為憲法草案內第24條人民基本人權的限制條款²¹⁸，並無必要性，反而將成為另訂法律限制人民自由權利的藉口；若仔細來看，妨礙他人自由是刑法範圍、緊急危難是戒嚴範圍、維持社會秩序則過於含混、增進公共利益應該是個案由地方議會辦理²¹⁹。上揭《大公報》的見解，應是對於自由民主憲政有一定的了解與認同後方能提出，可作為理解當時中國法學狀況的參考。此外，後來創辦《自由中國》雜誌的雷震，在其1950年代所發表的《制憲述要》中，開宗明義地說：「國民黨以外人士，……認為五五憲草名為五權憲法，實為一權憲法，不合於民主政治的基本要求。²²⁰」並指出戰後的憲法草案的精神則是「適合民主的，是發展個人人格和保護自由

217 關於政府責任的部分，《大公報》認為1936年的五五憲草規定出一個大權總統，得任免行政院長、發布緊急命令、對國民大會負責，但是國民大會龐大散漫又不常開會，難以行使中央統治權，換言之無法管理總統。而就算美國採取總統制，其總統職權也不是不受限制的，法律案必須由國會通過、閣員任命也必須取得國會同意、自身也可被國會彈劾。然而五五憲草所設計的總統，實際上不對任何人負責，因此1946年的憲法草案規定行政院向立法院負責，使得政治責任在行政院，而總統地位超然，故此項設計為《大公報》所肯認。再加上其他關於政府責任的論述，《大公報》最終的結論是：「民主國的政府應對人民或人民的代表機關負責，並在憲法上明白規定如何負責，否則『主權屬於國民全體』只是一句空話。」參見大公報，論憲草中的政府責任，中華法學雜誌，5卷9、10期（49、50號合刊：制憲專號），頁220-221（1947年）。

218 憲法草案第24條：「關於以上所列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由，避免緊急危難，維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」

219 大公報，評中華民國憲法草案修正案，中華法學雜誌，5卷9、10期（49、50號合刊：制憲專號），頁215（1947年）。

220 雷震，制憲述要，頁6（1957年）。

生活方式的。²²¹」見證了戰後之初中國曾出現一道自由主義民主的曙光。至此，中國的新式法典已大致齊備，部分法學者也能夠掌握近代西方法律中自由主義精神等等，似已具備發展出成熟的現代法學的契機²²²。

然而國共內戰的全面爆發，使得前述憲法規範本身的自由憲政性格僅是名目上存在耳。《中華民國憲法》於1947年12月25日生效之前，國民政府於同年7月5日就發布訓令宣告全國總動員，繼續沿用二次大戰時期的總動員法制，該憲法生效後約5個月的1948年5月10日國民政府即公布《動員戡亂臨時條款》，允許總統可不依憲法所規定之程序而為緊急處分，同年12月10日中國大部分地區（含金馬）開始戒嚴，自隔年的1949年5月20日起臺澎亦進入戒嚴狀況，距離上次臺灣省因1947年發生二二八事件而為戒嚴才不過2年而已²²³。於是，1947年施行的這部憲法所蘊含的自由民主人權的精神已遭破壞，情況倒退至日治末的戰爭時期。最後國民黨戰敗而離開中國而到臺灣來，曇花一現的自由主義法學在中國戛然而止，國民黨控制下的法學界再次抱持過去戰時的法西斯化黨國法學。

總之，由於戰後統治臺灣的中華民國此一國家組織體，在1945-1949這4年經歷了憲法的制定、法制施行地域的重大變更，故法學內涵上也隨著有劇烈的變動與轉型，影響了其後在臺灣的法學發展。按戰後中國所制定的新憲法內含西方自由民主憲政主義的因子，使得中國的法學有向西方自由民主國家取經的趨勢，但1949年

221 雷震（註220），頁14。

222 1946年至1947年來中國擔任司法行政部顧問的龐德（Roscoe Pound）即認為：「要企求一個現代化的司法制度，不是徒向外國模倣或借鏡所能為力，而是要本經驗與理性去獲致，……並求其如何適用於今日中國，……。沒有人能比你們做得更好。」龐德，改進中國法律的初步意見，收於：張文伯編，龐德學述，頁149（1967年）。

223 參見薛化元、陳翠蓮、吳靄魯、李福鐘、楊秀菁，戰後臺灣人權史，頁99、103（2003年）；展恒舉（註148），頁163-164；王泰升（註3），頁217-219。

中國共產黨獲得中國的執政權，使西方個人主義、資本主義法學在中國無法持續發展。同年遷移至臺灣（臺澎金馬）的中華民國，卻因而有機會在經日本半世紀的統治，而具有實施現代意義法律之較佳條件的臺灣²²⁴，如後所述重新從戰時法體制再出發，遠眺猶在燈火闌珊處的自由民主。這正是臺灣第一代法學者，所身處的時代大環境。

肆、動員戡亂戒嚴法制下的承襲與新創（1949-1987）

一、法學者之世代概念及其根據

就在戰後初期形成第一代法學者之後經過約20年，於1960年代中期之後，臺灣出現了許多先在國內各法學教育機構內承襲民國中國與戰前日本的法學後，再前往歐美日本學習當代西方法學理論及法制的臺灣第二代法學者。例如，歸國後任教於臺大法律系的蔡墩銘、楊日然、翁岳生等等，以及任教於臺大以外的法律系者²²⁵，而

²²⁴ 其詳，參見王泰升（註2），頁407-412。

²²⁵ 例如在臺灣第一所法學教育機構的臺大法律學系，第二代法學者約始自1965年留學歸國的蔡墩銘、1966年留學歸國的楊日然、翁岳生等，還有許多教授均屬第二代法學者。其詳，請參見王泰升（註65），190-198。而作為臺灣第二所法學教育機構之1952年設置的臺灣省立行政專科學校司法行政科（於1955年改為臺灣省立法商學院法律系，之後再改為國立中興大學法商學院法律學系，亦即今之國立臺北大學法律學系），由於有來自民國時代中國的法學者何孝元（其曾於1954年受聘於臺大法律系）等在該處任教，故受教於何孝元教授等、之後赴外國深造再返國任教者，亦屬第二代法學者，其亦將教導出第三代法學者。同樣的情形也可能發生於1954年在臺灣「復校」（但從師資及圖書設備而言係屬「新設」，以下同）的東吳大學法律學系、1961年由「復校」後的國立政治大學所設置的法律學系、1963年在臺灣「復校」的輔仁大學法律學系，以及1966年中國文化學院（即今之中國文化大學）所設置的法律學系。惟1957年設置的軍法學校（之後的政戰學校法律學系，今之國防大學法律學系）以訓練軍法官為主，似未培育出法學者。至於1980年才設置的東海大學法律學系，以及其後紛紛設置的許多法學教育機構，都因創校時已幾乎

與前述第一代法學者共同引領臺灣法學的發展。再經過約20年，於1987年解嚴前夕的**1980年代中期**，為數更多受教於第二代法學者後，再出國或在臺灣取得博士學位的臺灣**第三代法學者**，亦開始初試啼聲。以下將參考這些不同世代法學者的社會背景及學術傾向，一般性描繪出臺灣法學內涵的發展歷程。

宜先說明的是，各個世代的法學者雖各有其因緣際會而生的特色，但前一世代的法學特色仍可能為後一世代所延續，不同世代特色的同時存在或交互融合，形塑了後述各個**時期**的整體法學內涵。又，在此藉以舉例說明之不同世代個別的法學者，以曾任職於國立臺灣大學法律系者居多。這一方面是因臺大法律系是臺灣唯一自戰後之初即已存在的法學教育機構，故其教師群及所持學說適於用來探究戰後之初**迄今**的法學發展。另一個更實際的理由是，於今已有解析臺大法律系教師群學經歷等背景之公開出版品足資引用²²⁶，不然在強調保障個人隱私的今天，研究者很難完整而有系統地取得其他法律系教師的學經歷等個人資料。亦因了解到資料上有偏重臺大教師之侷限性²²⁷，本文以較為概括的年代及接受法學教育的情況，來劃分法學者世代。某一世代所涵蓋的學者為數甚多，無法一一列出大名，若有提及姓名者也僅為**例示**，藉以某程度具象化特定世代的法學者爾，非限於這幾位。

再者，為配合前述分類所定義的第二代法學者，某些在1950年代及1960年代前期已從事法學研究者，被歸入**第一代法學者**當中，

無本文所稱臺灣第一代法學者任教，而不能再循此模式認定第二代法學者。亦參見王泰升，*台灣法學教育的發展與省思：一個法律社會史的分析*，臺北大學法學論叢，68期，頁10-12、19-20（2008年）。

226 此書即王泰升，*國立臺灣大學法律學院院史（1928-2000）：臺大法學教育的回顧*（2002年）。因為在參考資料上相當倚賴由筆者所進行的這項研究，本文於註釋中不免常引用到自己的舊作。

227 筆者在引用臺大法律系的實證資料來討論整個臺灣的法學教育時，亦提及臺大法律系的歷史意義及其情形之不足以代表全臺灣，並參考其他各校法律系的出版品或網站上資料。參見王泰升（註225），頁12-13。

且其可再細分為二類。其一，於民國時代中國完成法學教育且曾赴海外留學，但係在中華民國政府遷臺後才進入臺灣法學界，而為法學研究者。例如韓忠謨、何孝元等²²⁸。其二，曾於日治時期臺灣或民國時代中國受過高等教育，但於戰後初期的臺灣完成法學教育，因學業成績優異而留校任教，故得以從事法學研究者，例如陳棋炎、馬漢寶等，或再至國外留學者，例如劉甲一、彭明敏、劉慶瑞²²⁹。前一類承襲民國時代中國法學經驗，加上個人的海外習法經驗，後一類則夾雜日治臺灣與民國中國的歷史經驗，以及在歐美日等國的習法經驗。

二、起初欠缺可參考的華文法學文獻

若沒有完善的圖書館，法學是難以建立在深厚的學術基礎之上²³⁰。如前所述，於戰後初期、1950年代，乃至1960年代前期，臺灣法學界主要是由來自中國、熟悉中華民國法制的外省族群法學者或法律實務家所組成。然而，由於臺灣與中國在政治上的分離與對峙，民國時代中國既有的法學論著流傳至臺灣者不多。中國於1930年代和1940年代在上海所出版的大量法律著作，包含眾多與中華民國法律有關的法釋義學作品或法學教科書，大多數未被攜至臺灣。換言之，蘊含著民國時代中國法學的圖書館並未一起遷來臺灣，故相當程度造成華文法學知識傳遞上的困難。按作為戰後臺灣最早的法律教育機構的臺大法律系學生，於1950年代前期根本沒有華文法學教科書可用，教師多需自編講義。惟曾受日本教育的本省人族群學生，倒是得以借閱臺大圖書館內豐富的舊藏日文法律書籍，作為

228 參見王泰升（註65），頁184、186-187。

229 參見王泰升（註65），頁163-164、172、182、188。二次大戰結束時，劉甲一在臺北帝大文政學部政學科肄業，彭明敏在東京帝大法學部肄業，故其事實上皆曾受過戰前日本高等教育。

230 1947年龐德（Roscoe Pound）曾針對中國的法學教育表示：「法是一種教學傳統，而其傳統的最大儲藏所便是圖書館。一個法律學校如果沒有一個適當的法律圖書館是殘缺不全的。」見龐德（註192），頁190。

補充教材²³¹。不過總的來講，因臺灣戰後教育體系排斥日文，故除了戰後初期本省人族群學生因曾受過日本教育而熟悉日文者外，臺灣的法律系學生也難以閱讀日文法律舊藏並從中獲得學識，以致原存於臺灣的日文法學知識的傳遞，亦相當程度受到阻礙。是以1945年至1949年的政治大變動，使得戰後臺灣的法學，與其所由來的民國中國和日治臺灣這「兩源」，皆呈現斷裂的現象。

屬於第一代法學者的臺大法律系教師們，只能靠課堂上的講演來傳達知識，以刻鋼版後油墨印出的方式編寫講義，經數年後講稿才被出版成教科書，且經常僅能關注於法條意涵的闡釋²³²。其實民國時代中國法學本來就直接受日本、間接受德國影響，故不論出身民國中國或日治臺灣，均習於法條註釋學風，且有許多法學教師將教科書的撰寫視為一種天職²³³，故法釋義學一直是臺灣法學的重要傳統；況且在此一階段的註釋學風，也含有讓中華民國法制能順利在臺灣運作的意義。正因為戰後臺灣的法學，幾乎是從學校裡的撰寫講義開始起步，方能讓戰後在臺灣受教育的第二代法學者，擁有一個更寬廣的發揮空間。

在承襲民國時代中國視法條釋義為法學核心的學風底下，法律實務工作者在法學論述上亦占有一席之地。由於在臺灣的中華民國法院，繼續沿用中國於北洋政府、國民政府時期的判決例或解釋例，故從事法律實務的司法官等，倒成為對如何解釋中華民國法條擁有最多資訊的一群。在那欠缺華文法學教科書的年代，實務界出身者紛紛提筆振書，寫出廣受學子歡迎之有關民事、刑事的實體法

231 根據蔡墩銘教授的訪談，提及：「外省族群同學相較之下，就沒甚麼中文的書籍可看。」王泰升（註65），頁153註102。曾任最高法院院長的林明德，亦因日治時期已唸至初中階段具相當的日文能力，故就讀臺大法律系時得以看日文書籍來擷取學問，參見司法院司法行政廳編，台灣法界耆宿口述歷史（第二輯），頁196（2006年）。

232 參見王泰升（註65），頁153。

233 參見蘇永欽，法律作為一種學問，月旦法學雜誌，98期，頁179（2003年）。

與程序法的教科書。其若係於民國時代中國受法學教育者，則可歸入第一代法學者，例如陳樸生之著有《刑法總論》、《刑法各論》、《刑事訴訟法實務》等²³⁴、褚劍鴻之著有《刑事訴訟法論》等²³⁵、姚瑞光之著有《民事訴訟法論》等²³⁶。人數上更多的是，在臺灣接受（第一代法學者所傳授的）法學教育後即進入法律實務界者，故可歸入第二代法學者，例如合著《民事訴訟法論》的王甲乙、楊建華、鄭健才²³⁷、著有《民法債編總論》的孫森焱²³⁸、著有《民法物權論》的謝在全等等²³⁹。當中不少屬本省人族群者曾受過日本教育，故可運用日文法學文獻來建構其論述²⁴⁰，形成戰後臺灣在留學日本之外的另一種接受日本法學的方式。

234 參見陳樸生，刑法總論（1966年）；陳樸生，刑法各論（1954年）；陳樸生，刑事訴訟法實務（1956年）。

235 參見褚劍鴻，刑事訴訟法論（1954年）。

236 參見姚瑞光，民事訴訟法論（1964年）。

237 參見王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法論（1960年）。

238 參見孫森焱，民法債編總論，增訂8版（1988年）。

239 參見謝在全，民法物權論（1989年）。

240 非走學術路線而自臺大法律系畢業後即擔任司法官的陳瑞堂大法官，在中學時代曾在日本受教育6年，其自述：「我的日文能力，在大學時期可以說無用武之地，……哪有空去研讀日文的法律書籍。可是當了法官以後，有時就不得不參考。日文書籍對我而言，真正有用的是在擔任大法官時期。我當時幾乎每一件案例都會找日本的相關論著判例或法令來研究，因為在台灣要找中文相關資料是很難的，可是在日本在各種領域都有相關的著作或參考資料……」司法院司法行政廳編（註108），頁198-199。日治時期受過小學教育而在臺大法律系畢業後擔任司法官的孫森焱大法官，在談到其所撰寫的《民法債編總論》時，曾表示：「在研究方法上我參考了許多日文文獻，我發現就是在大陸時期發行的民法著作，與當時日本的學說也有相當吻合之處，如此情形，可以直接研究日文著作，即可與國內學說銜接，對我輩而言，是為歷史的巧合。」司法院司法行政廳編，台灣法界耆宿口述歷史（第三輯），頁198（2007年）。同樣日治時期受過小學教育而在臺大法律系畢業後擔任司法官、後來擔任最高行政法院庭長的黃綠星法官，亦提及「初到行政法院，是一個完全陌生的領域，當時有關行政法及行政訴訟法的中文教科書、參考書很少，我則依賴日文書籍，大量吸收有關行政法、行政訴訟法理論及學說，對審判業務幫助很大。同時期的王甲乙院長、陳瑞堂、陳計男、曾華松、林明德、陳石獅等行政法院庭長、法官，大致上也參考日本的學說及判例。此後，陸續有留學德國的公法學者返國，引介很多德國新的理論，大法官的解釋也常引用德國公法方面的理論，行政法院之判決逐漸傾向德國法制。」具

三、戰前學說與戰後自由學風的相遇與交鋒

即令是具有民國時代中國法學經驗的法學者，其學說也都或多或少存在著日本因素。在公法學方面，來自民國時代中國的憲法學者薩孟武、林紀東，皆於戰前留學日本。林紀東的《中國行政法總論》、《中華民國憲法釋論》中引用的外國學說大部分出自日本，包括美濃部達吉、野村淳治、牧野英一、尾高朝雄、杉村章三郎、清宮四郎等人的論著²⁴¹。同樣背景的刑法學者韓忠謨，雖然留學美國耶魯大學，但其著作《法學緒論》、《刑法原理》²⁴²，也大量引用日本學說，亦有提及尾高朝雄、牧野英一等人的論著，並討論戰前日本的法院判決例。因此戰後的1950年代至1960年代，臺灣的公法學大多停留在戰前歐陸或日本的學說。值得注意的是，戰前日本學說當中有著濃厚國家主義、強調國權至上的法學論述，雖在日本已因戰後的民主化而式微，在臺灣卻因符合當時國民黨所施行之強調國家威權統治的「動員戡亂戒嚴法制」的需求，反而有較佳的生存空間而成為學界主流，如薩孟武之較具自由主義色彩者僅鳳毛麟角²⁴³。至於同年代，較不具政治色彩的民法學，亦因眾多由民國時

體描繪出戰後臺灣許多屬本省人族裔之司法官，因當時欠缺華文文獻、自己卻具有日文能力，而經常閱讀日本法學論著，直到以留德為主流的第二代及第三代法學者以華文引介德國學說後，才撼動日本學界的影響力。司法院司法行政廳編，台灣法界耆宿口述歷史（第四輯），頁190（2008年）。

241 參見林紀東，中國行政法總論，臺1版，頁235-284（1952年）；林紀東，中華民國憲法釋論（1960年）。

242 參見韓忠謨，法學緒論（1962年）；韓忠謨，刑法原理（1955年）。

243 戰前日本亦有如美濃部達吉等所持之具有自由主義傾向的學說，但此較未受到處於動員戡亂戒嚴法制的臺灣法學界所重視。當時的臺灣法學界也非全然立場上皆偏惠政府，例如薩孟武於1958年即公開表示：「國家制定一種法律，並不是單單拘束人民，而且同時亦拘束行政機關，行政機關若謂有了出版法，便可自由行動，真是幼稚極了。」見薩孟武，由出版法談到委任命令及自由裁量，自由中國，19卷2期，頁12（1958年）。不過，對照大法官於1964年司法院釋字第105號解釋，就臺灣省保安司令部的查禁書刊，肯認出版法所訂定期停止發行及撤銷登記為合憲，似乎薩孟武的見解並非當時臺灣法學界的主流。亦參見王泰升（註3），頁175。像薩孟武這般在具自由主義色彩的雜誌上發表多篇論著的法學者，在當時實不多見。例如參見薩孟武，論立法權

代中國或日治時期臺灣所培育的第一代法學者，均相當仰賴日本的法學論著，而使得日本自戰前延續至戰後的民法學說，仍引領著戰後臺灣的民法理論²⁴⁴。

不過，許多在戰後臺灣接受第一代法學者教導後再出國唸書的第二代法學者，已對上述的法學發展趨勢，注入了新的元素。蓋戰後進入臺灣法學教育機構就讀者，原本即沉浸於戰前日本和民國時代中國既有的歐陸式法條註釋學風，許多學生因此選擇前往歐陸或同樣崇尚歐陸法的日本深造，特別是德國有提供獎學金之誘因，使得留學德國的人數所占比例最高。同時期前往美國留學者也相當多，但姑且不論留在美國者眾，其返臺後經常是進入法律實務界而非法學界²⁴⁵。於是，這批約自1960年代中後期陸續返臺任教的第二代法學者，帶回歐陸與日本等法學知識「原產國」的新思潮，並時常以其留學國的立法例及判例學說，批判本國立法或法律實務界見解。因此1970年代和1980年代，雖然延續既有的講演式教學方法，並且繼續撰寫教科書，但在內涵上已有別於往昔。許多第二代法學者係將歐美及日本的立法例及學說判例等視為「法學理論」，而在課堂上或論著裡，據以展開法學論述或法律論證，有些學者乾脆將法學知識上更具系統性的國外（如德國）教科書整個改寫成華文，以供臺灣的莘莘學子閱讀。另一方面，也是為了闡述在國外所學的

的運用，自由中國，2卷12期，頁5-8（1950年）；薩孟武，論修改憲法與解釋憲法，自由中國，7卷2期，頁4-7（1952年）。

244 關於民法學的部分，參見陳自強，臺灣民法與日本債權法之現代化，頁343（2011年）。

245 以創建於1970年12月的台灣法學會（當時稱「中國比較法學會」）為例，其於1970年代的會員中具有博士學位者，人數上以留德者最多，其次為留美，再其次為留日，還有少數留學英、法等歐洲國家；1980年代新入會會員中具博士學位者，留美者17人、留德者14人，留日者5人，但是17位留美者中只有5人是在學界服務。參見王泰升、曾文亮，台灣法學會四十年史：自由民主法治的推手，頁31、55、102（2011年）。前往美國留學的法律系學生，不乏因政治思想為國民黨政府所不喜而無法返臺者，例如參與臺獨運動的國際法學者陳隆志。

法學理論，而開始解析、且經常傾向於批判臺灣本地的法院判決等司法實務見解，不再僅止於闡釋條文之文義²⁴⁶。這一群無意於仕途、純粹在學院內研究法學之人，與前述出身法律實務界的法學者，在研究態度及結論上有時不免有別。

沿襲日治臺灣習法風氣而占大多數係本省人的第二代法學者²⁴⁷，經常從國外帶回戰後德國傾向自由民主的法學內涵。惟這些學說在1960年代後期、1970年代，猶受到兩股力量的夾擊。其一是如前所述原有沿襲戰前德、日理論的舊學說，其二則是在「以訓政經驗行憲」的政治氛圍之下，國民黨意識形態（孫文學說與蔣中正言論）被認為優越於西方的自由民主主義。例如於1978年10月，作為國家教育機關的教育部，竟與屬於特定政黨文宣組織的國民黨中央文化工作會及中央青年工作會，合辦「大學院校哲學／法律學教學研討會」，召集各大學院校擔任哲學、法律學、國父思想之專任教師與會²⁴⁸。雖所訂的主題是：「如何鞏固民主政治的法律基礎」，但會場上不少跟隨國民黨來臺的第一代法學者，言必稱三民主義，歌頌的是不同於近代西方天賦人權與自然法思想的孫文「革命人權論」，以及帝制中國傳統上的「法律與道德合一論」²⁴⁹。該研討會亦將沿襲自訓政時期中國的「黨國法學」視為理所當然，故另一主題乃是「國父思想與哲學暨法律學的結合教學」。對此，哲學方面的引言人即倡言：「在『三民主義學術化』、『學術三民主義化』的前提下，把根本原理之學的哲學與國父思想結合起來，實在是當前學術工作最重要課題之一。²⁵⁰」法學方面的引言人雖具體提問：「我國現行法律的條文與制度，百分之八九十都是來自西方各國……這些外國

246 參見王泰升（註65），頁154、157-158、252-253。

247 其詳，參見王泰升（註65），頁206-207、222-224。

248 參見教育部、文工會、青工會編，大學院校哲學及法律學教學研討會資料彙編，頁1（1978年）。

249 參見教育部、文工會、青工會編（註248），頁50、55-60、64、126-127。

250 參見教育部、文工會、青工會編（註248），頁105。

的條文與制度，多有其所以產生的背景與原因……是不是同時都能與三民主義相結合？」但予以回應的某些留學日本、美國的第二代法學者，仍以較抽象的「理想」、「精神」上兩者一致，來避免批評三民主義，再以「實現這些理想的方法」可以「適度地加以修正」等話語，肯定繼受自西方的現代法；或者以不願直言的疑問句，表示現代法以個人主義／保障人權為基礎，三民主義卻可能是立足於全體主義／團體主義²⁵¹。可見於1970年代後期，就算法學者認同現代的／西方的自由民主價值，在威權統治下也只敢隱晦地主張。

四、戰後西方法學的繼受及學術發表形式和論壇

在臺灣的第二代法學者以及部分第一代法學者倡導下，以戰後歐陸和日本的法學理論來評釋法院判決，以歐美日本立法例作為法制典範的學風，確實已逐漸興盛。此時引進戰後歐陸法學的代表性學者，如王澤鑑教授對所謂債權行為、物權行為概念的辨正、請求權規範基礎理論的闡釋與運用；翁岳生教授經由自身論著以及指導博碩士論文，而有系統地將德國行政法理論介紹到臺灣來；以及許多教授以其在國外所學的法學理論、立法例或判決為依據，評釋臺灣的立法或司法實踐²⁵²。有論者指出，在民法學方面已因留學德國者遽增，以致引領臺灣民法理論者已不再是日本，而轉變為德國的法學²⁵³。從臺灣法學之發展而言，這般以歐陸法學理論或其法制，直接作為臺灣社會實際發生的問題應有怎樣之立法、或作為司法裁判或行政處分的法律上說理依據，也可算是將外來法在地化的方式之一，雖從今之立場該方式是否妥當不無可議。

251 參見教育部、文工會、青工會編（註248），頁110、114、116-117、119。以上討論，亦參見王泰升（註26），頁339-340。

252 亦參見蘇永欽，台灣的社會變遷與法律學的發展，收於：施茂林編，當代法學名家論文集——慶祝法學叢刊創刊四十週年，頁567-569（1996年）。

253 參見陳自強（註244），頁346-347。

上述學風可謂某程度忽略了歐陸（特別是德國）法釋義學與其社會現實的關聯性，而去脈絡地套用於臺灣的社會現實²⁵⁴；亦即臺灣法學界乃是以「創造性繼受」的方式，將歐陸法學吸納為在地的法學之一部分。這種學術傾向實有其時代性。按倘若不將外國法制及其法釋義等直接視為具有普世的「先進」性，而認為其係外國一定的社會現實下的產物，則將其導入臺灣時，即須與臺灣的社會現實做比較，從而面對「臺灣的社會現實是什麼」的質問。令人困窘的是，當時臺灣之處於國民黨威權統治下的現實，確與歐陸有所不同，但如此豈非承認臺灣不必採用歐陸法制及其法釋義？其實臺灣的社會實況，包括價值觀在內，是可予以改變的；若從現代法治理念出發，引導社會前進原本即是法律規範被期待的功能之一。然而法學者若明白表示需改變臺灣的政治現實，例如倡言應較強調個人自由而非國權的維護，即等於是正面挑戰施行威權統治的國民黨政權、直接觸犯執政者所稱「反政府」的禁忌。於是，為了避其鋒刃，乃採取將外國的法學理論、法規範、法釋義等全部「去脈絡」、直接定義為「先進」的策略，以隱藏自我主張的方式表示：「是先進的某國法這樣認為，而不是我個人這樣主張」²⁵⁵。就好比在帝制中國因不能批評當道而借古諷今時，也會說所批判的是「古」而不是「今」，但時人皆知其指桑罵槐。但一概將外國法「先

254 參見黃舒芃著，鍾芳樺譯，憲法中的釋義學與科際整合，收於：變遷社會中的法學方法，頁238-239（2009年）。

255 直到1980年代前期，於戒嚴與動員戡亂法制下，欲直接批判政府仍然需冒著極大的風險。當時對國民黨威權統治持批判立場的台灣法學會，乃藉由舉辦國際研討會，透過外國的立法例判決或學說，來質疑本國的法體制，例如以「政黨政治」、「言論自由」等涉及國家組織與人民基本權利等重大議題，作為研討會主題，以對執政當局提出批判。國民黨當局對此恐亦了然於心，故派人與舉辦研討會者有所溝通，但由於受邀來訪者都是國際上受敬重的學者，國民黨政府在顧及國際形象的情形下，不敢阻擾這些活動。可見訴諸外國法，乃至尊崇外國學者，都是那個不自由的年代裡，藉以批判本國法的重要方式之一。而從台灣法學會之舉辦這類學術性活動，仍不免讓部分會員心生疑慮，甚至淡出法學會，即可嗅出當年政治肅殺的氣氛。參見王泰升、曾文亮（註245），頁114-116。

進化」，而自居「落伍」，很可能將陷入思想文化上「自我殖民」的困境。前述民國時代中國的法學界，曾被批評為存在著隨意用刀切割一塊外國法即使用於本國的所謂「刀的外語觀」，但在承襲國民黨訓政／黨治經驗的戰後臺灣，具有自由民主法治信仰的法學者若不「明知故犯」，又如何推動在地法制的改變呢？除非如專攻國際法的陳隆志，以流亡海外換得不被威權統治當局所逮捕入獄²⁵⁶。

此外，在歐陸法學已成為臺灣法學一部分的大環境下，也有某些臺灣學者以從歐陸法學出發、**超越**歐陸法學，來自我期許，而作為其構思原創性的來源之一，即為臺灣社會的法律經驗。例如，留學日本的邱聯恭教授，欲針對臺灣民事訴訟程序實踐上的弊端，透過對於繼受自德日的民事訴訟法學說的批判，重新界定臺灣法上各種訴訟審理原則的內涵；就像臺灣新民事訴訟法有關判決基礎事實之提出、蒐集係由法院協同當事人為之的規定，已跟向來沿用日本通說而認為提出或蒐集應屬當事人權能及責任的「辯論主義」的意涵有所不同²⁵⁷。這是另一種以「為在地社會重新打造」的想法，來實踐在地化。

在此同時，將判決評釋及介紹外國法制的**單篇論文**發表於屬於「同仁刊物」的法學期刊上，逐漸成為法學研究的表現形式。按自1960年代後期起，越來越多法學者認為應在撰寫教科書之外，針對各個法律議題，進行較深入探究之單篇論文的寫作。有許多未從事國家行政或司法職務、純屬學者的第一代、第二代法學者，更勇於以單篇論文評釋、**批判**臺灣法院所為的判決。各法學教育機構亦陸

256 可謂屬於第二代法學者的陳隆志，在美國加入反國民黨的政治團體，並在美國法學期刊上發表其不同於國民黨當局的法律見解。See Lung-chu Chen & W. M. Reisman, *Who Owns Taiwan: A Search for International Title*, 81 YALE L.J. 599, 599 (1972).

257 參見邱聯恭，程序保障論之新開展——評析其在我國之獨特性，收於：程序選擇權論，頁7（2000年）；邱聯恭，處分權主義、辯論主義之新容貌及機能演變，收於：程序選擇權論，頁99-109（2000年）。

續開辦法學期刊，以鼓吹撰寫單篇學術論文²⁵⁸，如中興大學法律系於1966年開辦《中興法學》（後來隨著學校名稱的更動而易名為《臺北大學法學論叢》），政大法律系於1969年開辦《政大法學評論》，臺大法律系於1971年開辦《臺大法學論叢》，東吳法律系於1976年開辦《東吳法律學報》。不過當時的法學期刊，並無今之雙向匿名審稿制度。法學者將其分別發表於各期刊的論文彙整後出版《論文集》，亦逐漸成為教科書以外另一種重要的學術發表方式，例如「臺大法學叢書」自始即以此為特色。

前揭法學期刊，即以1960年代中期之後歸國的年輕教授為主要作者，其和上一代一樣重視比較法研究，但在資料的完整性與論證的精密程度上，則有顯著的進展，也有較高的批判性²⁵⁹。特別是1980年代中期之後，許多第三代法學者紛紛留學歸國，進一步打破過去以教科書為主的趨勢，刊載於法學期刊的文章也逐漸專門化，學術水準日益提升²⁶⁰。這些期刊上的論文，不斷地推動臺灣法學再精進，例如《臺大法學論叢》發刊迄今40年來所刊登的論文，對於臺灣民法學說、實務與立法發展具有一定的影響力²⁶¹，而其奠基者即第二代法學者。

另一方面，法學相關的學術團體相繼成立。1970年出現了以「法學之比較研究及法治之宏揚」，作為學會成立宗旨之「中國比較法學會」。該會創立後在當時威權統治的大環境底下，選擇了遠離政治、親近學術的自我保護之道，故戮力於舉辦各式各樣的學術活

258 例如，關於臺大法律系發行《臺大法學論叢》之旨趣，見王泰升（註65），頁251。當時尚有由官方（司法行政部）所辦的《法學叢刊》、《軍法專刊》，及由私人所辦的《法令月刊》、《刑事法雜誌》、《憲政思潮》等法學期刊。

259 參見蘇永欽（註252），頁568。

260 參見葉俊榮，法律學門成就評估與發展，科學發展月刊，27卷6期，頁608（1999年）。

261 參見詹森林，《臺大法學論叢》與臺灣民法學說、實務及立法之發展，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1595-1624（2011年）。

動，以推動臺灣法學的進步；但進入1980年代之後，該學會已較前積極地引進西方當代自由民主法治理念²⁶²。亦在此同時，各個法學領域的研究者，也紛紛成立其自己的法學專業團體。例如民事訴訟法研究會即於1980年初成立，固定每三個月舉辦研討會一次，由臺灣各大學研究、講授民事訴訟法之學者及實務家，輪流分別提出研究論文並進行共同討論，以促進民事訴訟法學理論與實務之銜接，使得「臺灣的民事訴訟法學」得以逐漸發展萌芽，甚至引領後來在1990年代晚期展開的修法活動²⁶³。

臺灣的法學發展至此，經過戰後40餘年、三個世代法學者的努力，已經逐漸具備規模。但是在威權統治的背景之下，學術仍然受到某程度的箝制，真正能夠自由地發展，須待1987年的解嚴而一舉衝破戰時或非常法制的束縛，才能展現嶄新氣象。

伍、自由民主法制下多元與在地化的法學（1987年迄今）

一、與歐美當代自由民主法學理論同步發展

在自由民主的價值已成為臺灣法學界基調後，出現了第四代法學者。1980年代後期的政治自由化、民主化，使得第二代及第三代法學者當中本於自由民主主義所提出的法學論述，於1990年代後引領了臺灣法學走向。再經約15年，於進入2000年代後，受教於第三代再出國或於國內獲得博士學位的第四代法學者登場，其大多秉持自由民主的法理念，以更多元的研究視角及學科訓練，與第二代、

262 關於該學會創立迄今40年來的發展歷程，參見王泰升、曾文亮（註245），頁11-238。

263 參見邱聯恭，民事訴訟法學之回顧與展望，收於：施茂林編，當代法學名家論文集——慶祝法學叢刊創刊四十週年，頁151-193（1996年）。

尤其是第三代的自由派法學者共同形塑當代臺灣法學。且在百花齊放的1990年代及2000年代，法釋義學不再一枝獨秀，臺灣法學界逐漸重視法釋義以外的法學研究途徑，臺灣在地性的研究亦獲得更多的關注；同時法學評比的基準趨向以學術本身，而不再如過去之僅以立法、司法、行政上的實務需求為導向。就此，將詳述如下。

以1987年解嚴為法制上分水嶺，臺灣在1980年代後期逐漸走向政治與經濟的自由化和民主化，此一風潮亦從法學界逐漸散布到法律實務界。法學界從外國引進的法學理論能為法律實務界所接納，其中一個重要因素是，從事司法違憲審查的大法官經常是由具有留學經驗的學者出任，最著名的例子即是擔任大法官的時間超過30年、在臺大法律系任教、精通德、日兩國行政法學的翁岳生教授²⁶⁴。整體而言，根據統計，第四屆以前（1985年以前）的大法官會議，最常引用的外國法判例是日本，第五屆（1985-1994）則是美國，從第六屆開始（1994年起）改為德國，此與大法官的留學國背景高度相關²⁶⁵。雖然1990年代迄今，留學美國或英國且返臺後進入法學界者已較之前為多，並發揮一定的影響力，但仍以留學德國者在人數上居冠，留日者則不多²⁶⁶。自1990年代初期開始，典型的德國法概念，如法治國家、比例原則、法律保留、基本權的客觀面向乃至於制度性保障等等，經由法學者不斷的引介與開展，而為臺

264 參見葉俊榮編，法治的開拓與傳承：翁岳生教授的公法世界，頁16-20、183（2009年）。

265 參見張文貞，人權保障與憲法解釋：對司法院大法官釋憲的期許，台灣法學雜誌，127期，頁98（2009年）。

266 以1990年代台灣法學會新加入的博士會員為例，當中留德者有23人，略多於留美的22人；惟留美者已大多數係在學界工作，有別於1980年代之大多從事法律實務；留日者僅11人，但亦絕大多數在學界任教；接著，還有留英者4人；倒是臺灣本土培育的博士雖有13人，卻只有6位在學界工作。再就2001-2010年台灣法學會新加入博士會員的學術背景及職業為觀察，可發現其整體狀況與1990年代相似，法學者仍以具留學經驗者為主流，留學國亦以德、美為主，德國居首，美國次之，日本再次之，在其後為留英者。參見王泰升、曾文亮（註245），頁147、194。

灣的憲法解釋機關所肯認²⁶⁷，並對這個時期臺灣法之邁向自由民主，貢獻良多²⁶⁸。大體而言，從1980年代後期的解嚴開始，自歐美引進之傾向自由民主的法學理論已成為法學界主流，並進而影響司法實務界的裁判，亦即整個國家實證法的內涵；相對的，承襲自民國時代中國與日治時期臺灣的戰前日本學說，則已漸次褪色。

第三代法學者係大約於1980年代中期出道，時間上與前述的臺灣民主化的起始相當，故在一部分第二代學者的帶領下，積極投身於正常國家法律體制之重建²⁶⁹。或許受到政治與社會轉型、既有法律規範體系鬆動的影響，以第三代為主的法學者由於參與修法立法的討論，並意識到法政策形成的複雜性，而對過去自限於法規範注釋的作法有所反省，甚或開始強化立法論上探究，展現出由法學者主導重要法案之立法或修法的「學者立法」氣勢²⁷⁰。在學者的推動下，臺灣晚近完成了許多重大的立法上工程，包括《民法》自1990年代晚期起的債編修正，直到2010年年初物權編的通過為止，每一編都有所增修；《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》、《刑法》等的修正，均不僅單條、小規模的修正，而是大幅度的改變，行政法制也在1990年代趨向完備，包括《行政程序法》的制定、《行政訴訟法》的全面翻新等等。

267 參見黃舒芃著，鍾芳樺譯（註254），頁228-229。亦參見黃綠星法官之經驗談，司法院司法行政廳編（註240），頁190（2008年）。

268 關於1990年代獨立運作且向自由民主理念靠攏的司法機關，參見王泰升，自由民主憲政在臺灣的實現：一個歷史的巧合，臺灣史研究，11卷1期，頁206-209（2004年）。

269 參見葉俊榮（註260），頁608。再以台灣法學會為例，1987年正逢臺灣解除戒嚴，故其年會研討會的主題便訂為「我國非常態法制之檢討」，並在這個主題下區分為憲法、刑事法、財經法三方面。1989年則因解嚴後臺灣的特殊法制只剩《動員戡亂時期臨時條款》，故年會主題即訂為「動員戡亂體制研討會」，分成動員戡亂與法治、動員戡亂與人權以及動員戡亂與選舉等三個面向進行討論。按該會1987年理事長為林文雄教授，1989年理事長為林山田教授，這兩位均屬於第二代法學者，而由不少當時剛學成歸國不久的第三代法學者擔任報告人。參見王泰升、曾文亮（註245），頁112-113、252-253。

270 參見蘇永欽（註252），頁574；葉俊榮（註260），頁608。

這般透過外國法學知識來改造本國法制，對於臺灣因應自1990年代迄今、從自由化與民主化，到去管制後的再管制，再到全球化底下經貿體制的調整，所需要的法制建設，都做出重大貢獻。惟法學者是否過度執意於引進外國所謂「先進」的法制，而慣性地忽略臺灣在地的現實條件，恐怕亦有再省思的必要。此外，也有部分第三代或第四代的法學者，不再以司法實務作為唯一的對話夥伴，且嘗試發表非從法律角度探討社會問題的文章²⁷¹。況且對第四代法學者而言，在大批的第三代法學者幾乎打造了一個相當「完備」的臺灣法制之後，已沒有太大的學術空間可繼續執著於透過外國法學知識來改造本國法制，其充沛的研究能量因而轉向於較具批判性的法學省思，或更具在地關懷的法實證研究。總之，本於過去數十年的基礎，以面臨臺灣重大轉型期為契機，臺灣的法學者將其學自當代歐美與日本的法學知識，傳遞至臺灣的法律制度及實務運作，且在研究取徑與關懷方向上也有所改變了。

二、多元的法學研究取徑以追求臺灣人民福祉

更加多元，即是所改變的特色之一。一方面，傳承自歐陸的法釋義學，因司法實務上的需求而繼續發展。眾多先在臺灣接受法學訓練後再出國拓展視野的法學者，除延續既有的歐陸法釋義學傳統外，也逐漸地改為針對臺灣社會在地的法律爭議，進行法釋義的爭辯。也有法學者純就法律概念本身為辯詰，例如認為因過去一味仰賴日本學說以致發生「誤解」，而擬以「澄清」法律概念應有之意涵的方式，提出法釋義上的主張²⁷²。另一方面，傳承自美國的法律

271 參見蘇永欽（註252），頁574。

272 例如，陳自強教授指出臺灣法學界某些有關民法釋義學的見解，可能只是不加深思地接受日本的學說，並未意識到臺灣在繼受日本學說時的「界線」。其認為，為了明瞭各法律規範的「底蘊」，在適用外國學說時，應本於各該法律規範的繼受來源，故在適用日本學說時，尚須考量日本法的繼受來源，是否與臺灣法的繼受來源有所衝突。在此觀點下，當法律規定純屬德國法的繼受時，「直接消化吸收德國的法律文獻，並加以一定程度之內化，應為正道」。

經濟分析或政策導向思考等研究取徑，不斷被引進；且隨著1990年代以後前往美國攻讀法學博士學位的臺灣法律人的增多（相較於過去之以至德國攻讀博士學位為主流），美國法學對臺灣法學界的影響力將與日俱增。其結果，似乎隱然呈現因留學國——尤其是德國或美國——之不同而導致的「法學典範」之爭²⁷³。惟自1990年代起，於在地認同、自主意識等逐漸昂揚的臺灣法學界，出現了不少法學者毅然走出以往偏向純然繼受外來學說之較「安全」、較不涉入在地爭議的道路，而開始廣泛且深入地評析本地的具體個案判決或解釋，以及將這些法規範內容與臺灣在地的歷史文化或政治經濟社會條件一併觀察，不再讓留學國的法制與學說束縛其法學思維²⁷⁴。

於1990年代後期，留美學者葉俊榮即指出，法學的課題必須對整體社會進行規範性思考，故法學界已開始積極展開與其他學門的對話。首先，法學經由與規範對象相關的學門來補強規範領域的可行性，如資訊法、工程法等規範與科技領域的配合，心理學、社會學與少年福利法的結合。其次，經由其他學門研究議題與方法的引進，法學也得以重新定位與詮釋傳統的規範與概念，例如透過心理學影響刑法學上行為的理解；政治學上對政治行為的描述影響了憲法學者與行政法學者的思考；經濟學上的效率與交易成本的概念，也影響法規範的詮釋。第三，法學亦藉由其他學科的知識，進一步來反思法規範本身的問題，包括規範的意義、正當性來源、法與道德的關係、法與權力機制的關係，乃至於法規範的哲學基礎等²⁷⁵。

參見陳自強（註244），頁172-176、339-340、345-346。不過，為何對本國法律概念淵源的「知其底蘊」，便足以導出應適用外國學說的結論，可能還需要進一步的說明。

273 參見張嘉尹，憲法之「科際整合」研究的意義與可能性——一個方法論的反思，世新法學，3卷2號，頁5（2010年）。

274 其例可參見王泰升（註65），頁253-254。

275 葉俊榮（註260），頁609-610。

換言之，法學已不能僅是針對條文的再生產，而必須正視其他學科之發展並與之相結合。於1990年代至2000年代前期的10餘年間，招收非法律系畢業生而施以法學訓練，或招收法律系畢業生而施以法律以外其他學科之訓練，以求「科際整合」為科技法律、或以具有「科際整合」能力為目標的研究所或大學部，如雨後春筍般出現，一時蔚為風潮²⁷⁶。有論者批評：臺灣法學界在談「科際整合」時，似乎沒有考慮或輕忽了法釋義學的基礎或重要性²⁷⁷。依筆者之見，法釋義學應該是被整合，而非被排除；但長期以來有意或無意被忽視的法經驗事實，也應被導入關於法制定或法適用的論證當中，以補充或強化論證本身所欲達成之說服人們接受該利益衡量或價值判斷之為妥當²⁷⁸。

晚近以來，法經驗事實的研究取徑已受到相當程度的重視。在臺灣，留學美國的法學者的確較常進行法經驗事實的研究，不過留德的刑法學者林山田早在1977年就曾為文介紹德國學界的「法事實研究」²⁷⁹，故雖留德的法學者較傾向於發揮其在法釋義方面的長處，但亦有進行法事實之研究者。有鑑於前述多元或科際整合的法學研究取徑之獲得重視，國科會於2006年委託臺大法律學院開設以服務學術研究為主的「臺灣法實證研究資料庫」，期能藉由資料的便利性，鼓勵法學者從事法經驗事實研究。與其他學門的交流不僅豐富了法學者的思考，無形中也改變了法學者所使用的語言及語體。例如逐漸放棄法學界多年慣用的淺白文言體，改用社會科學論述通用的白話體，以示與社會科學溝通交流²⁸⁰。中央研究院法律學

276 其詳情，參見王泰升（註225），頁21-23。

277 參見黃舒梵著，鍾芳樺譯（註254），頁236-237。

278 參見王泰升（註26），頁30-34、37。類似的見解，參見張嘉尹（註273），頁16-21、41-42。

279 參見林山田，法事實研究——一個亟待加強的法學研究，法學叢刊，88期（22卷4期），頁48-54（1977年）。

280 參見蘇永欽（註252），頁574。

研究所作為臺灣新興的法學研究重鎮，最近即大力推動過去較少有學術累積的法實證研究，亦有相當亮眼的學術表現²⁸¹。

上述法學研究走向，在在都使得法學研究不能再僅就法規範面進行釋義上的操作，而須考量該等法釋義將被適用的社會，亦即臺灣社會的經驗事實。其結果，以中華民國此一國家組織體的法制及其施行後社會實況為研究對象，實質上就等於是針對臺灣社會所為的法學研究；按在國內固然仍稱「中華民國法」，但到了國際就改稱為「臺灣法」了²⁸²。自1990年代起，國家法律不再禁止人民主張臺灣應成為一個主權獨立國家²⁸³。超過半個世紀在臺灣的共同生活經驗更使得臺灣的法學者，不論屬於承接民國中國歷史經驗的外省族群或承接日治臺灣歷史經驗的本省人族群，都有可能接受以當今的臺灣為主體，來檢視、批判、修改70餘年前自民國時代中國移入的中華民國法制。自1990年代以降，除了戰後一直主宰臺灣法學界之以民國時代中國連接在臺灣的中華民國的「中華民國法律史」外，還逐漸浮現以今之臺灣社會為主體來追溯歷史的「臺灣法律史」²⁸⁴。作為臺灣最大的法學專業團體的台灣法學會，在1990年代的學術活動的特色就是在地化，例如1999年李登輝總統提出「兩國

281 例如參見張永健編，2011司法制度實證研究（2013年）。

282 參見Tay-sheng Wang, *Chapter 4: Taiwan, in ASIAN LEGAL SYSTEMS: LAW, SOCIETY AND PLURALISM IN EAST ASIA* 124, 124-61 (Poh-Ling Tan ed., 1997); CHANG-FA LO, *THE LEGAL CULTURE AND SYSTEM OF TAIWAN* 3-4 (2006); JIUNN-RONG YEH, *THE CONSTITUTION OF TAIWAN: A CONTEXTUAL ANALYSIS* 1-3 (2016); 後藤武秀，*台湾法の歴史と思想*，頁5-7（2009年）；高見澤磨、鈴木賢，*中国にとって法とは何か——統治の道具から市民の権利へ*，頁64-65（2010年）。臺灣的民法學者在日本發表論文時，也將「中華民國民法」定位為「臺灣民法」，參見陳自強（註244），頁342。

283 於中華民國法制底下，直到1992年《刑法》第100條修正後，臺灣應為一個國家的「臺獨」言論，始不再觸犯刑法，故相較於臺灣應為中國一部分的「統一」論調，在立足點上居於劣勢，但在臺灣當今有關「國族認同」的言論市場上，已有後來居上之勢。

284 參見台灣法學會編，*台灣法制一百年論文集*，頁1-684（1996年）；王泰升，*台灣主體性的法律史研究*，收於：*台灣法律史的建立*，2版，頁36-39（2006年）。

論」後，台灣法學會於隔年2月即舉辦「台灣國家定位學術研討會」以展現臺灣主體性的思考²⁸⁵。於1999年4月，臺灣法學界也出現一份以「本土性」、「學術性」為旨的法學期刊，並發行至今²⁸⁶。

以「因多源而多元」為特色的臺灣法學，在法學研究典範多元並存中的共識，乃是應維護臺灣人民的利益。在此係指屬於臺灣共同體一員的法學者，在臺灣學術界就臺灣的議題所提出的法學論述。臺灣的法學者如果在國際學界，就非屬臺灣的法律議題發表論述，例如在德國學界論某一德國法上議題，可能即無涉於臺灣人民的利益。若回顧臺灣的歷史，1920年代以殖民地政治共同體而存在時，即出現以臺灣為主體、運用現代法學而建構的臺灣人法學。於今，事實上作為國家共同體而存在，自然而然會產生以臺灣社會的議題為主要關懷、以臺灣人民集體的感受及利益為優先考量的法學論述紛紛出現，但在價值多元底下，各方對「集體利益」的看法不盡相同。這種臺灣人民取向的法學論述態度，日治時期即曾以「臺灣人法學」的面貌出現，而在不受戰前的日本、或戰後的國民黨等外來政權壓制之後²⁸⁷，獲得公開闡述的機會，不過於今舊有學說的

285 參見王泰升、曾文亮（註245），頁159-160、163。

286 1999年4月創刊的《台灣本土法學雜誌》，就其屬性定位與編輯策略，提出了「本土性」、「學術性」、「實用性」與「服務性」四者。並就前兩者為進一步闡釋，而表示其是「一份以本國實定法為出發點，以台灣邁向法治社會過程中所可能產生之問題作為研究範圍之刊物，我們不排除外國立法趨勢與法制演變動態之觀察研究報導，但這些觀察研究報導仍將以有助於本國實定法之發展進步作為終極目的」。也是「一份提供法界思考、討論問題以及流通、交換法律見解與相關資訊之刊物，其目的在累積法律實際制訂及適用之經驗與智慧，以提昇整體法學研究水準」。該雜誌於今雖將名稱改為《台灣法學雜誌》，但仍維持原有的發行宗旨。參見黃宗樂，台灣本土法學雜誌創辦緣起，台灣本土法學雜誌，創刊號，頁1-2（1999年）。田金益，閱讀「原創」的台灣法學，台灣法學雜誌，109期，頁1-3（2008年）。

287 在臺灣的中華民國自1990年代起，已由所有臺灣人民選出代議士組成議會，選出總統組成行政部門，國民黨是在這樣的體制下透過選舉而取得執政權，故性質上已是「本土政權」，雖然過去從民國時代中國所帶來的法制本身未被廢止，而僅做修改（如憲法增修條文）。

影響力猶存²⁸⁸。

放在整個人類的智識史來看，於19世紀西方勢力席捲東亞的世界局勢中，百餘年前來自近代西方的現代意義法學，在臺灣業已透過前述在地化過程而落地生根。

三、法學論著之經審查及多樣化

法學的學術評比基準，從1980年代後期至2000年代，隨著整個臺灣學術界的變遷而有所調整。近年來政府部門或學校當局，對於校、院、系，乃至於個別學者的研究成果評鑑，都漸次設計出評比基準，系所評鑑牽涉到各系所未來的招生及預算、個別學者的評量則影響教職之升遷。在上述評鑑中，期刊論文已成為學術界各領域皆相當重視的研究表現形態。臺灣法學界對於學術期刊，過去一直是走日本式的「同仁刊物」路線。但國科會（今之科技部）自2000年起設置「臺灣社會科學引文索引」（TSSCI）資料庫，收錄「國內出版的社會科學類『核心』期刊，亦即學術水準較高、影響力較大，且出刊過程較嚴謹的期刊」，避免僅以美國的SSCI期刊上的發表來判斷臺灣社會科學（含法律學）研究者之學術能力，按許多在臺灣獲得學術獎項的法學者係將其論文刊登於TSSCI而非SSCI的期刊²⁸⁹。此項TSSCI資料庫收錄期刊的評量標準，相當重視內稿比率（越低越好）、公開徵稿、雙向匿名審稿，以鼓勵法學期刊嚴格審查

288 於戰後臺灣，擁護中國國族主義的國民黨人長期掌控文教界，故與中國國族主義相左的學術論述，於今仍不易為眾多的一般民眾所知悉。例如在美國任教、推動臺灣獨立運動的陳隆志教授，主張國際法上臺灣主權已定，歸屬於臺灣人民，但迄今其論著仍僅以英文版在美國發行，而未能以當今臺灣通行的華文在臺出版。See LUNG-CHU CHEN, THE U.S.-TAIWAN-CHINA RELATIONSHIP IN INTERNATIONAL LAW AND POLICY 90-92 (2016).

289 參見管中閔、于若蓉，「臺灣社會科學引文索引」資料庫的建置概況，人文與社會科學簡訊，3卷2期，頁67（2000年）。迄今臺灣法學界中獲得國家的學術獎項者，仍以並無在SSCI資料庫內期刊發表論文者占多數。不過，臺灣的法學者若能在被收錄於SSCI資料庫之期刊上發表論文，當然會獲得相當不錯的學術評價。

論文並公共論壇化。國科會曾於1998年、2003年、2010年，分別進行過法律學門期刊之評比。以2010年的評比結果而論，由法學界自己評比為第一級和第二級的期刊，與TSSCI資料庫就法律學門所收錄的期刊大致相當，故TSSCI資料庫對法學期刊的評量基本上已為法學界所接受²⁹⁰。於今許多重要的法學期刊已從同仁刊物轉型為公共論壇式刊物，以爭取被TSSCI資料庫收錄；而眾多須經各方評鑑的法學者，亦致力於在TSSCI資料庫所收錄期刊上發表論文²⁹¹。

關於學術評鑑上特別強調經嚴格審查之論文，在法學界仍存有不同意見。例如有些法學者質疑那些TSSCI所收錄之法學期刊的論文審查公平性。按該等期刊採雙向匿名審稿，作者及審查人相互不知對方為誰，且期刊的編輯委員會對外部專業審查人（2至3人）所建議的同意刊登與否或修改後刊登，極為尊重。然而臺灣的法學界人數不多，審查人有時易於猜出作者為誰，實質上未必能做到雙向匿名審稿。尤要者，論文審查的重點不在於所達成的結論，而在於該文得出特定論點的論述過程及依據，但有可能某些審查人僅因不欣賞論文的論點即百般刁難，此時只能靠編輯委員會內委員的審慎判斷，以維護期刊作為公共論壇的中立性了。整體而言，雖難以保證全無冤屈之例，但論文審查制度之追求評鑑的客觀化仍值得肯定，尤有助於新進法學研究者得不受限於年資，端賴學術能力脫穎

290 參見黃昭元，2010年法律學門期刊評比報告，人文與社會科學簡訊，12卷1期，頁74、78（2010年）。

291 根據在2010年3月至2012年4月所執行的「建立適合人文社會學科學術發展之評鑑機制研究計畫」，學者在選擇以何種形式來呈現其研究成果時，除了考量知識傳播、累積、教學上的意圖之外，也深受評鑑體制規範的影響。又，依該計劃所蒐集之各校獎勵辦法關於期刊論文之規定，發表於SCI、SSCI期刊的平均獎勵約為5萬元左右，AHCI期刊平均約是4萬元，而TSSCI期刊論文的平均獎勵金約為2萬6千元。蘇國賢、呂妙芬、章英華、黃寬重，學術自主與控管之間，頁1、17（2013年）。臺灣的法學者在SCI、SSCI、AHCI期刊上發表論文非常困難，故絕大多數是透過發表於TSSCI期刊，而獲得獎勵金或在新聘、升等、頒獎等評鑑中獲得較高的評價。

而出，況且再怎麼有經驗或努力的研究者，在論述上總不免有盲點，藉由其他專家的提點將可提升論述品質。

在重視論文的同时，臺灣人文社會學界也意識到專書論著在學術發展上的重要性。在臺灣目前各大專院校暨研究機構人文社會科系的升等及獎勵制度下，學者投入專書論著的寫作，不但成本比發表期刊論文更高，其成果的不確定性（因專書論著的評審制度不易建立、標準相對模糊）也高於期刊論文²⁹²。然而專書論著對於許多人文社會科學學門而言，還是一種較能匯聚研究成果的思想表達及溝通媒介。依某項就論文中所引用參考文獻的出版形式所為實證調查顯示，法律學門的「專書」（含教科書）被引用率高達44%，「期刊」被引用率略遜而為41%，「文集」（指主編論文集專書或論文集專書中一章）被引用率也有15%，其加上前揭「專書」已占了約六成；且大體而言文獻出版年份較早者，屬於專書論著的機會越大，亦即期刊論文較易在發表後不久就被注意，但專書論著需經較長時間之後才展現影響力²⁹³。

由此可見法學知識的建構及傳遞，不能僅靠期刊論文，還須仰賴包括專書論著在內的發表形式。不過，始自第二代法學者的倡導，臺灣法學界相當盛行將個人歷年論文照原面貌收錄成一書，其在前揭研究中究竟被列為「專書」或「文集」並不清楚，許多臺灣的法學者則將這類「具有主題的論文集」認為係專書，復以教科書（詳見下述）也被算入前揭「專書」內，因此如同博士論文那般以數章來詮釋一個論點的「專論式」專書，在臺灣的法學界其實仍屬少見。然而，專論式專書可能是臺灣法學界在「承先」之餘，應力求「啟後」的一種重要寫作形式，以發揮專書之具有較長生命週期及較深影響力的特質。

292 參見蘇國賢、呂妙芬、章英華、黃寬重（註291），頁5、19、22。

293 參見蘇國賢、呂妙芬、章英華、黃寬重（註291），頁19、23-29。

在法學發展上以往曾扮演火車頭角色的教科書寫作，已不再一枝獨秀，但仍有許多法學者認為此係傳播其專業知識之必要的奠基工程。且已出現某些新形態的教科書寫作模式。例如人才濟濟的行政法學界，首先於1998年以集體合作方式，多位學者共同撰寫《行政法》出版²⁹⁴。2003年時亦有幾位同校的憲法學教授認為，臺灣憲政發展的素材已經累積足夠到做本土論述的時候了，乃參考美國法學院常見的教科書體例，以摘錄臺灣的案例及法學論著為主而編寫成上課用的教科書²⁹⁵。可見在1990年代和2000年代，不僅法學的研究取徑有所創新，研究成果的表達方式也呈現多樣化。

關於法學研究對社會的貢獻，第二代或第三代學院內的法學者，向來是以其學說見解能為政府部門所採納而自我肯定。此亦是促成1990年代「學者立法」的原因之一。但在學術界因留學國等種種因素而有多元的意見之後，究竟哪一種意見較可採，倘若政府部門可透過採納哪一學派，而給予國家資源、壯大該學派的學術影響力，則從學術研究探求真理、不受學術外其他因素干擾的本質而言，毋寧需要對此保有一定程度的警戒心。按個別法學者的參與政府部門立法活動，或進行各種形式的立法遊說，同樣是民主國家身為公民的權利，屬於政治活動的範疇，與學術專業能力是兩回事。獲得政治支持與否，和學說論述品質的良窳沒必然關係。況且，於今應跳脫向來那種僅僅將法學視為「具有實用性的工具」，甚至將

294 參見翁岳生編，行政法（上冊）（1998年）；翁岳生編，行政法（下冊）（1998年）。該書各章撰寫者如下：第一章：行政的概念與種類（翁岳生）；第二章：行政法的發生與發展（黃錦堂）；第三章：行政法的法源（陳清秀）；第四章：依法行政與法律的適用（陳清秀）；第五章：行政法律關係與特別權力關係（法治斌）；第六章：行政組織法之基本問題（黃錦堂）；第七章：公務員法（林明鏘、蔡茂寅）；第八章：公物法（李惠宗）；第九章：公物營造法、公企業法（蔡茂寅）；第十章：行政命令（葉俊榮）；第十一章：行政處分（許宗力）；第十二章：行政契約（林明鏘）；第十三章：行政計畫（董保城）；第十四章：行政罰（洪家殷）。

295 林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞，序，收於：憲法——權力分立，2版，頁III（2008年）。該書第1版於2003年問世。

「實用」侷限於制定或解釋適用法條的舊思維。按法學還須思考法律體系與各種社會現象或其他社會規範之間的關係，這些亦具有實踐上的意義。其實立法重社會上相衝突利益之調和、行政求特定政策目的之達成、司法則謀個案正義之實現，均與學術之發現客觀真實與道理、超越現實利益的考量有所不同。法學理論之具有說服力以及妥當性，應來自法學者的肯定，學術的桂冠須由學術界頒予。

四、法學研究活動的國際化

由於法律具有地域性，臺灣法學者當然較熟悉的現今存在於臺灣的國家法秩序（中華民國法制），但其進行法學研究的空間並不侷限於國內。從第一代開始，數個世代的臺灣法學者，均樂於前往美國、德國（西德）、日本等被認為法學「先進」的國家從事法學研究。此可謂是「出國留學」模式的另一種表現，也反映了臺灣法學界向來追隨歐美日本學說及法制的學風。不過晚近約20年來，臺灣法學者進而在美、日、德等國發表法學研究成果²⁹⁶。按第三代及第四代臺灣法學者中留學美國者人數已大增，其已相當積極地參與美國法學界的學術活動；在東亞法學交流的旗幟下，也有越來越多屬於各個世代、不問留學國背景的臺灣法學者，前往日本或韓國發表論文²⁹⁷；留德的第三或第四代法學者亦在更全球化的大環境中，較第二代法學者有機會在德國法學界發表論文，包括探究德國法本身的議題²⁹⁸。

296 關於臺灣法學者在美、日、德等國發表論文的情形，尚無實證調查可據，在此係根據筆者與美國、日本、德國學界的交流經驗，及自身所做的觀察而立論。

297 臺灣法學者之在日、韓學界的學術活動，並非第三代或第四代法學者的專利，作為第二代法學者之典型人物的翁岳生教授，於2010年仍本於其個人精湛學養及臺灣的法律實踐，於日本發表法學論文。參見翁岳生，司法院大法官解釋與台灣民主政治及法治主義之發展，台灣法學雜誌，178期，頁1-22（2011年）。此文依註釋中之說明，係應日本台灣學會之邀，於2010年5月29日在北海道大學為專題演講之書面稿。

298 例如可歸類為第四代法學者的黃舒芃教授，於赴德短期研究時在德國公法學

在「有來有往」的原則下，赴國外參加研討會的結果帶動了臺灣法學機構的舉辦國際學術研討會。自1990年代起，尤其是在2000年代，法學界相當頻繁地在臺灣舉辦國際學術研討會。例如台灣法學會在2000年代的學術活動，高達23%是屬於國際性活動，且通常係由該學會與臺灣其他法學教育或研究機構一起合辦，故實反映了此時法學界的整體氛圍；這些國際學術活動也不再是單向地引進外國的法律或理論，而是進行兩國或國際之間具有實質意義的比較研究²⁹⁹。又如臺大法律學院及政大法學院曾分別於2006年及2012年，舉辦兩次國際學者逾百人、併用華語、日語、韓語、英語的「東亞法哲學研討會」³⁰⁰。且臺大法律學院於2012年爭取到國際著名的「比較法學會」第一次到東亞地區舉辦年度學術研討會（使用英語），來自十餘國的法學者齊聚臺北³⁰¹。作為臺灣最高學術機構的中央研究院底下的法律學研究所，也經常以英語舉辦大型國際學術研討會。除前述多邊的國際研討會，還有臺灣與特定國家的法學者雙邊的國際研討會。例如由留德的臺灣學者與德國學者共同舉辦，使用德語的「德臺研討會」，自1999年起輪流在德國、臺灣舉辦，至2014年為止已辦六屆，且每屆論文均在德國出版，以展現臺灣公

界發表許多探究德國法本身的論文。筆者雖留學美國但也因赴德短期進修而與德國學者往來，故曾在德國期刊上發表以英文撰寫的論文：Tay-sheng Wang, *The Modernization of Civil Justice in Colonial Taiwan, 1895-1945*, 36 ZJAPANR / J.JAPAN.L. 95, 95-116 (2013).

299 參見王泰升、曾文亮（註245），頁206-207。

300 「東亞法哲學研討會」是東亞地區規模最大的法哲學學術研討會，1996年在日本舉行第一屆大會，由東京大學與同志社大學主辦，爾後每兩年舉辦一次。第二屆於1998年在韓國由延世大學和濟州大學主辦，第三屆於2000年在中國由南京師範大學主辦，第四屆於2002年在香港由香港大學和香港城市大學主辦，且臺灣學者首度參加，第五屆於2004年由北海道大學主辦，並確定由臺灣大學法律學院於2006年主辦第六屆。第七屆於2008年在中國由吉林大學主辦後，於2012年再由在臺灣的政治大學法學院主辦。

301 「The 2012 International Congress of Comparative Law With the Theme of "Codification"」，臺大法律學院、Taiwan Committee, International Academy of Comparative Law主辦，2012年5月24-26日。

法學界的研究成果³⁰²。尚有由不同留學國別的臺灣學者與日本學者共同參與，同時使用華語、日語的「台日憲法論壇」。前述國際間法學論壇見證了臺灣與德、日法學界長期的友誼。此外，由於中國政府不承認臺灣的國家性，而以「兩岸」為名的臺灣與中國的法學交流（使用華語），也在近十餘年來雙方政治關係解凍後相當蓬勃的展開，有助於相互了解。

在國際學術界發表學術論文，固然是於2000年代，各個世代臺灣法學者的新挑戰，但也是提升臺灣法學研究品質的新契機。按法學界不能自外於2000年代包括鄰近的中國崛起在內的整個全球化浪潮，故如何將臺灣的法學研究成果帶至國際學術舞臺，並與國際學術界對話，已成為新的挑戰與課題。由於在進行國際學術討論時，經常有表述本國法制或法學經驗之必要，故在地化實為國際化的基礎。臺灣已累積了百年以上現代法制的施行經驗，又經數個世代的赴國外取經，已有能力使用作為當今世界學術主流的法學概念與理論，表述臺灣在地的法律發展經驗，或進行普世性法律議題的討論。因此國際化的壓力反而將促使臺灣的法學者，更加重視對在地法律實務運作及其社會效應之研究，並關心臺灣同儕的研究成果³⁰³。其結果，不但使臺灣整體的法學論述更貼近在地社會脈動、

302 參見翁岳生，推薦序，收於：Christian Starck著，李建良等譯，法的起源，序頁5（2011年）。據許宗力教授表示，德臺研討會（Deutsch-taiwanesisches Kolloquium）的催生人主要是其在德國唸書時的指導教授Christian Starck與臺灣的翁岳生教授，第一屆於1999年在德國哥廷根大學舉辦，第二屆2002年於臺北，第3屆2006年再於德國哥廷根、第4屆2008年於臺北、第5屆2011年於德國哥廷根，第6屆2014年亦於臺北舉辦。其每屆均訂一個主題，有6至7個更具體的次主題，每一個次主題都分別由臺、德各一位學者報告。由於會議論文使用德文，故每一屆結束後均集結成冊由德國著名出版公司Nomos出版，這套書提昇了臺灣公法學研究成果在德語世界的能見度。

303 例如，為了到國際學界介紹臺灣的發展現狀，當然須說明臺灣在地的法律實踐及法學論述，進而促使臺灣的法學者改變目前在論文引註上偏向使用外國文獻，卻較少引用臺灣同儕之研究成果的現狀，按如果論述上處處以外國法為師，自然傾向於直接引用外國文獻。關於期刊論文之少引用同儕作品，參見黃昭元（註290），頁80-81。

更有助益於本國的立法、司法與行政，且經由與其他國家法學者的交流，更能把外國法作為本國制法與執法上的選項，且更增進本國與外國相互間的了解與合作。在國際化的趨勢下，能否運用作為國際學界主要語言的英語，對於法學研究者的重要性日增。不過最關鍵而根本的因素，似乎仍在於法學研究的議題及其論述品質，而非法學研究者的語言能力³⁰⁴。所屬世代、留學國別等等，都不是前進國際學術界的障礙。

陸、結論：外來學術知識的在地化

源自近代西方的現代法學，先藉由日本人之手而進入臺灣社會。在東亞首先自近代西方繼受現代法學的日本，於1895年開啟在臺的殖民統治後不久，即形塑出以探究臺灣漢人乃至原住民之法律傳統為核心關懷的舊慣法學。惟學術上發展舊慣法學的根本宗旨是政治的，亦即以提供殖民統治當局在行政、司法乃至立法上之參考為目的，也因此當日本帝國的殖民政策於1919年轉向「內地延長」後即告沒落。然而其的確已為幾個世代後、於1990年代崛起以臺灣為主體的法學研究，留下豐沛的學術資源。

其實於1920年代，某些接受現代法學教育的臺灣政治異議者，已顯現出從臺灣人立場思考法律議題的「臺灣人法學」傾向，但當時無從打入以日本人為主、以內地延長為尊的殖民地臺灣的法學界，而法學大眾化就算有進展也十分有限。其後，雖不乏臺灣人的法學者，但在當時的政治氛圍及法學知識主流下，其所熟悉的幾乎

³⁰⁴ 透過翻譯即能克服法學研究的語文問題，例如筆者不能以日文發表研究成果，但以華文書寫的論文已有十餘篇被翻譯成日文，並將當中的10篇以「台灣法中的日本元素」為書名出版日文的法學論文集，持之與日本學者為學術交流。參見王泰升著，鈴木賢等譯，台灣法における日本の要素（2014年）。

都是為日本法條的解釋適用服務、心態上自居於西方法學殖民地而以德國法學為標竿的戰前日本法學，少有人進行或注意到立基於臺灣社會的法學論述，縱令研究臺灣人習慣亦僅侷限於國家法尚接納的親屬繼承等事項。尤其在日治晚期的戰時法體制底下，殖民地臺灣的法學籠罩在一片法西斯化中，只剩殖民性，而少有現代性。

戰後臺灣起初是延續同樣受日本影響、來自民國時代中國的現代法學。戰後初期於日本人法學者離臺後所形成的臺灣第一代法學者，大多數係承襲著中國從清末到民國時代法學經驗的外省人，僅少數是擁有戰前日本法學的訓練並熟悉日治臺灣法學內涵的本省人。然而清末民初中國深受日本法學影響，形成了以西方法／比較法作為新式立法或司法的典範或論證上根據的學風。中國國民政府雖催生出許多對中華民國歐陸式法典進行法釋義的論著，但實際上係將歐陸及日本的學說不加分析批判地全盤移植，具有中國特色者竟是依訓政體制所形成的「黨國法學」，並於戰時與日本同樣走向法西斯化。因此臺灣於戰後初期，法學界仍籠罩在戰前日本，外加民國時代中國的法學傳統下，帶有濃厚國家主義色彩者更為戒嚴戡亂時期統治階層所歡迎；另一方面，中國戰後之初曾暫露曙光的自由主義法學，隨著1949年國民黨政權將中央政府遷至臺灣施行戰時法制，而難有發揮空間。

不過1960年代中期以後，學院內的臺灣第二代法學者逐漸帶回歐陸與日本於戰後較傾向自由民主的法學內涵，並致力於移植該等外國學說，包括以之撰寫教科書，且因為欲闡述來自國外的法學理論，而開始解析臺灣本地的法院判決等司法實務見解。這般將歐陸法釋義學去脈絡地套用於臺灣的社會現實，實乃先驗地將外國法律條文及其法釋義等視為具有普世的「先進」性，再據以期待國內法做相對應的修改，但此係為避免觸怒執政當局所不得不然。惟已有學者認為可超越繼受母國學說，來尋求臺灣社會最適的法制。在此同時，深入特定議題研究的單篇論文，逐漸成為發表學術成果的重

要方式。於1980年代中期之後加入了第三代法學者，當時雖仍處於威權統治底下，但戰後40餘年來的發展與累積已使臺灣法學的深度與廣度達到一定的規模。

臺灣在地的政治情勢於1987年解嚴後遽變，自由開放的風氣使法學呈現前所未有的活潑與多元。法學者不再僅限於對既有法規範為注釋，而已強化其立法論上研究，甚或實際參與立法，以打造嶄新的自由民主法制。和其他學門的合作與對話也逐漸被重視，並設立以「科際整合」為目標的法學教育機構。學術表達方式亦呈現多樣化，不再侷限於過去的教科書撰寫，除了單篇論文、集結成冊的論文集外，專論式專書的寫作正方興未艾。在源自近代西方的自由民主理念已成為臺灣法學界基調後，於2000年代出現了第四代法學者，法學研究人才倍增。整個臺灣法學界逐漸走出單純繼受外國法學理論的窠臼，採取多源而多元的研究途徑，關注臺灣社會的需求，發展出具有在地特色的臺灣法學。四個世代累積而成的臺灣法學正積極的在國際學界發聲，或表述臺灣的法律經驗，或進行普世性法律議題的探究；這般國際學術交流亦可回饋給臺灣法學者重新思考在地法律的運作實態，以再深化臺灣法學的內涵。

綜論之，源自近代西方的法學知識體系，自19世紀末起，由分別來自戰前日本、民國中國的政權攜入臺灣。存在於臺灣的法學知識，起初不脫其從屬於日本帝國、民國時代中國的性格。然而外來的法學者，業已或多或少貢獻其心力於建立與臺灣相關的法學知識。臺灣本地法學者在吸收來自日、中兩國的法學知識後，再繼受戰後歐美日本的法學，而形塑出具臺灣特色的法學體系，並持之與國際學界交流。

參考文獻

1. 中文部分

- 大公報（1947），評中華民國憲法草案修正案，中華法學雜誌，5卷9、10期（49、50號合刊：制憲專號），頁213-218。
- （1947），論憲草中的政府責任，中華法學雜誌，5卷9、10期（49、50號合刊：制憲專號），頁218-221。
- 山中永之佑等著，堯嘉寧、阿部由里香、王泰升、劉晏齊譯（2008），新日本近代法論，臺北：五南。[山中永之佑編（2002），新・日本近代法論，京都：法律文化社。]
- 中央研究院民族學研究所編譯（2007-2015），臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會——蕃族調查報告書，共8冊，臺北：中央研究院民族學研究所。
- 中國國民黨（1979），關於司法制度之完成及其改良進步之規劃案——民國十八年六月十七日通過，收於：秦孝儀編，中國國民黨歷屆歷次中全會重要決議案彙編（一），革命文獻第79輯，頁131，臺北：中國國民黨中央委員會黨史委員會。
- 王世杰、錢端升（1947），比較憲法，增訂8版，上海：商務印書館。
- 王甲乙、楊建華、鄭健才（1960），民事訴訟法論，臺北：自版。
- 王建朗（2000），中國廢除不平等條約的歷程，南昌：江西人民出版社。
- 王家瑩（1983），法學宗師——王寵惠的故事，臺北：近代中國出版社。
- 王泰升（2002），國立臺灣大學法律學院院史（1928-2000）：臺大法學教育的回顧，臺北：國立臺灣大學法律學院。

- (2004), 自由民主憲政在臺灣的實現：一個歷史的巧合，臺灣史研究，11卷1期，頁167-222。
- (2005), 「鬱卒」的第一代台灣法律人：林呈祿，收於：台灣法的世紀變革，頁71-101，臺北：元照。
- (2005), 台大法學教育與台灣社會（1928-2000），收於：台灣法的世紀變革，頁103-269，臺北：元照。
- (2006), 台灣主體性的法律史研究，收於：台灣法律史的建立，2版，頁35-56，臺北：自版。
- (2006), 撥雲見日的台灣法律史研究，收於：台灣法律史的建立，2版，頁57-96，臺北：自版。
- (2006), 日治時期台灣特別法域之形成與內涵——台、日的「一國兩制」，收於：台灣法律史的建立，2版，頁99-158，臺北：自版。
- (2006), 台灣日治時期憲法史初探，收於：台灣法律史的建立，2版，頁183-255，臺北：自版。
- (2007), 清末及民國時代中國與西式法院的初次接觸——以法院制度及其設置為中心，中研院法學期刊，1期，頁105-162。
- (2008), 台灣法學教育的發展與省思：一個法律社會史的分析，臺北大學法學論叢，68期，頁1-40。
- (2009), 國民黨在中國的「黨治」經驗——民主憲政的助力或阻力？，中研院法學期刊，5期，頁69-228。
- (2010), 具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證，臺北：自版。
- (2011), 日治時期高山族原住民族的現代法治初體驗：以關於惡行的制裁為中心，臺大法學論叢，40卷1期，頁1-98。
- (2011), 四個世代形塑而成的戰後台灣法學，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1367-1428。
- (2012), 台灣法律史概論，4版，臺北：元照。

- （2012），四個世代形塑而成的戰後台灣法學，收於：台灣法學會台灣法學史編輯委員會編，戰後台灣法學史（上冊），頁1-66，臺北：元照。
- （2012），殖民現代性法學：日本殖民統治下臺灣現代法學知識的發展（1895-1945），政大法學評論，130期，頁199-255。
- （2014），台灣日治時期的法律改革，修訂2版，臺北：聯經。
- （2015），臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」，臺北：中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣大學出版中心。
- （2015），論台灣社會上習慣的國家法化，臺大法學論叢，44卷1期，頁1-69。
- 王泰升、阿部由里香、吳俊瑩（2015），台灣人的國籍初體驗：日治台灣與中國跨界人的流動及其法律生活，臺北：五南。
- 王泰升、堯嘉寧、陳韻如（2004），戴炎輝的「鄉村臺灣」研究與淡新檔案——在地「法律與社會」研究取徑的斷裂、傳承和對話，法制史研究，5期，頁255-325。
- 王泰升、曾文亮（2011），台灣法學會四十年史：自由民主法治的推手，臺北：台灣法學會。
- 王泰升、薛化元、黃世杰編著（2016），追尋臺灣法律的足跡：事件百選與法律史研究，增訂3版，臺北：五南。
- 王寵惠（2008），今後司法改良之方針（一）（1929年3月3日），收於：張仁善編，王寵惠法學文集，頁285-287，北京：法律出版社。
- 王覺源（1989），徐樹錚與徐道鄰父子，收於：近代中國人物漫譚，頁429-450，臺北：東大圖書。
- 北京圖書館編（1990），民國時期總書目（1911-1949）：法律，北京：書目文獻出版社。
- 台灣法學會編（1996），台灣法制一百年論文集，臺北：自版。

司法行政部民法研究修正委員會編（1976），中華民國民法制定史料彙編（下冊），臺北：司法行政部總務司。

司法院司法行政廳編（2004），台灣法界耆宿口述歷史（第一輯），臺北：司法院。

——（2006），台灣法界耆宿口述歷史（第二輯），臺北：司法院。

——（2007），台灣法界耆宿口述歷史（第三輯），臺北：司法院。

——（2008），台灣法界耆宿口述歷史（第四輯），臺北：司法院。

民眾法律新報社（1933），刑罰之一般與在於家庭常易發生之犯罪之解說，民眾法律，2卷4號（漢文），頁7-9。

——（1933），刑法之由來，民眾法律，2卷4號（漢文），頁12-13。

——（1934），臺灣違警例，民眾法律，3卷8號（漢文），頁30-35。

——（1934），治安警察法，民眾法律，3卷8號（漢文），頁38-40。

永章生譯（1933），陪審法與一般的常識，民眾法律，2卷4號（漢文），頁14-21。

田金益（2008），閱讀「原創」的台灣法學，台灣法學雜誌，109期，頁1-3。

石畢凡（2004），近代中國自由主義憲政思潮研究，濟南：山東人民出版社。

吳文星（2008），日治時期臺灣的社會領導階層，臺北：五南。

吳密察（1991），從日本殖民地教育學制發展看台北帝國大學的設立，收於：台灣近代史研究，頁149-175，臺北：稻鄉。

吳經熊、金鳴盛（1936），中華民國訓政時期約法釋義，上海：會文堂新記書局。

吳豪人（2004），岡松參太郎論——殖民地法學者的近代性認識，收於：林山田教授退休祝賀論文編輯委員會編，戰鬥的法律人：林山田教授退休祝賀論文集，頁511-586，臺北：林山田

教授退休祝賀論文編輯委員會。

李定一（1978），中美早期外交史，臺北：傳記文學出版社。

李祖蔭、王選、王懋麟、徐家相校勘（1927），朝陽大學法律科講義：法學通論——法院編制法，6版，北京：北京朝陽大學。

李貴連（2001），中國近現代法學的百年歷程（1840年-1949年），收於：蘇力、賀衛方編，20世紀的中國：學術與社會·法學卷，頁214-319，濟南：山東人民出版社。

——（2002），近代中國法律的變革與日本影響，收於：近代中國法制與法學，頁69-95，北京：北京大學出版社。

——（2002），20世紀初期的中國法學（續），收於：近代中國法制與法學，頁202-233，北京：北京大學出版社。

李劍農（1957），中國近百年政治史（上冊），臺北：臺灣商務印書館。

沈家本（1985），釋貸借，收於：沈家本撰，鄧經元、駢宇騫點校，歷代刑法考：附寄移文存（四），北京：中華書局。

阮毅成（1935），中華民國訓政時期約法，上海：商務印書館。

居正（1935），司法黨化問題，東方雜誌，32卷10號，頁6-19。

松本巍著，蒯通林譯（1960），臺北帝國大學沿革史，臺北：蒯通林。

林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞（2008），憲法——權力分立，2版，臺北：新學林。

林山田（1977），法事實研究——一個亟待加強的法學研究，法學叢刊，88期（22卷4期），頁48-54。

林呈祿（原署名「林慈舟」）（1920），六三問題之運命，臺灣青年，1卷5號（漢文之部），頁16-29。

——（原署名「記者」）（1921），施行民法商法宜置除外例，臺灣青年，3卷4號（漢文之部），頁21-26。

林紀東（1952），中國行政法總論，臺1版，臺北：正中書局。

——（1960），中華民國憲法釋論，臺北：朝陽大學法律評論社。

- 林紀東教授追思紀念集編輯委員會編（出版年不明），高山仰止——林紀東教授追思紀念集，臺北：自版。
- 邱志紅（2008），朝陽大學法律教育初探——兼論民國時期北京律師的養成，史林，2008年第2期，頁48-57。
- 邱聯恭（1996），民事訴訟法學之回顧與展望，收於：施茂林編，當代法學名家論文集——慶祝法學叢刊創刊四十週年，頁151-193，臺北：法學叢刊雜誌社。
- （2000），程序保障論之新開展——評析其在我國之獨特性，收於：程序選擇權論，頁1-21，臺北：林雅英。
- （2000），處分權主義、辯論主義之新容貌及機能演變，收於：程序選擇權論，頁79-135，臺北：林雅英。
- 姚瑞光（1964），民事訴訟法論，臺北：自版。
- 胡有瑞、劉本炎、盧申芳紀錄（1996），王寵惠先生百年誕辰口述歷史座談會紀實，收於：陳鵬仁編，百年憶述——先進先賢百年誕辰口述歷史合輯，頁191-220，臺北：近代中國出版社。
- 范揚（1948），行政法總論，7版，上海：商務印書館。
- 孫森焱（1988），民法債編總論，增訂8版，臺北：三民。
- 孫慧敏（2002），從東京、北京到上海：日系法學教育與中國律師的養成（1902-1914），法制史研究，3期，頁157-196。
- 展恒舉（1973），中國近代法制史，臺北：臺灣商務印書館。
- 徐聖凱（2012），日治時期臺北高等學校與菁英養成，臺北：國立臺灣師範大學出版中心。
- 浦伊蓮（Lilian Pudles）著，許苗傑譯（2003），二十世紀初中國留日學生的法政教育，收於：《法國漢學》叢書編輯委員會編，法國漢學（第八輯）教育史專號，頁250-284，北京：中華書局。
- 翁岳生（2011），司法院大法官解釋與台灣民主政治及法治主義之發展，台灣法學雜誌，178期，頁1-22。
- （2011），推薦序，收於：Christian Starck著，李建良、范文

- 清、蔡宗珍、陳愛娥、楊子慧譯，法的起源，序頁1-7，臺北：元照。
- 翁岳生編（1998），行政法（上冊），臺北：自版。
- （1998），行政法（下冊），臺北：自版。
- 國史館中華民國史法律志編纂委員會編（1994），中華民國史法律志（初稿），臺北：國史館。
- 國立中央圖書館臺灣分館編（2000），國立中央圖書館臺灣分館日文臺灣資料目錄，2版，臺北：自版。
- 國立臺灣大學編（出版年不詳），接收台北帝國大學報告書，臺北：自版。
- 張仁善編（2008），王寵惠法學文集，北京：法律出版社。
- 張文貞（2009），人權保障與憲法解釋：對司法院大法官釋憲的期許，台灣法學雜誌，127期，頁94-98。
- 張永健編（2013），2011司法制度實證研究，臺北：中央研究院法律學研究所。
- 張知本（1933），憲法論，上海：會文堂新記書局。
- 張瑞成編（1990），光復臺灣之籌劃與受降接收，臺北：中國國民黨中央委員會黨史委員會。
- 張嘉尹（2010），憲法之「科際整合」研究的意義與可能性——一個方法論的反思，世新法學，3卷2號，頁1-49。
- 張彝鼎（1938），戰時法律概要，軍事委員會戰時工作幹部訓練團編，「抗戰建國叢書」，漢口：國民政府軍事委員會政治部。
- 教育部、文工會、青工會編（1978），大學院校哲學及法律學教學研討會資料彙編，臺北：自版。
- 許章潤（2004），書生事業：無限江山——關於近世中國五代法學家及其志業的一個學術史研究，收於：許章潤編，清華法學·第四輯：二十世紀漢語文明法學與法學家研究專號，頁40-70，北京：清華大學出版社。
- 陳自強（2011），臺灣民法與日本債權法之現代化，臺北：自版。

- 陳昭如（1997），初探台北帝大政學科的法學教育與法學研究，*Academia——台北帝國大學研究通訊——*，2號，頁13-68。
- （1997），離婚的權利史——臺灣女性離婚權的建立及其意義，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 陳昭如、傅家興（1996），文政學部一政學科簡介，*Academia——台北帝國大學研究通訊——*，創刊號，頁10-71。
- 陳紹馨（1979），臺灣的人口變遷與社會變遷，臺北：聯經。
- 陳新民（1995），驚鴻一瞥的憲法學彗星——談徐道鄰的憲法學理論，收於：公法學筭記，修訂2版，頁213-262，臺北：自版。
- 陳瑞華（1998），二十世紀的中國刑事訴訟法學，收於：李貴連編，二十世紀的中國法學，頁89-153，北京：北京大學出版社。
- 陳端志（1937），抗戰與民眾訓練，中國文化建設協會編，「抗戰小叢書」，上海：商務印書館。
- 陳樸生（1954），刑法各論，臺北：正中書局。
- （1956），刑事訴訟法實務，臺北：自版。
- （1966），刑法總論，臺北：正中書局。
- 曾士榮（1997），從「台北帝大」到「台灣大學」，*Academia——台北帝國大學研究通訊——*，2號，頁1-12。
- 曾文亮（1999），台灣法律史上的祭祀公業，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- （2010），全新的「舊慣」：總督府法院對臺灣人家族習慣的改造（1898-1943），*臺灣史研究*，17卷1期，頁125-174。
- 曾文亮、王泰升（2007），被併吞的滋味：戰後初期臺灣在地法律人才的處境與遭遇，*臺灣史研究*，14卷2期，頁89-160。
- 湯能松、張蘊華、王清雲、閻亞寧編著（1995），探索的軌跡——中國法學教育發展史略，北京：法律出版社。
- 湯熙勇（1997），戰後初期臺灣省政府的成立以及人事佈局，收於：黃富三、古偉瀛、蔡采秀編，*臺灣史研究一百年：回顧與*

- 研究，頁125-149，臺北：中央研究院臺灣史研究所籌備處。
- 程燎原（2003），清末法政人的世界，北京：法律出版社。
- 黃丞儀（2002），臺灣近代行政法之生成：以「替現」與「揭露」的書寫策略為核心，1885-1901，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 黃宗樂（1999），台灣本土法學雜誌創辦緣起，台灣本土法學雜誌，創刊號，頁1-2。
- 黃昭元（2010），2010年法律學門期刊評比報告，人文與社會科學簡訊，12卷1期，頁73-81。
- 黃舒芃著，鍾芳樺譯（2009），憲法中的釋義學與科際整合，收於：變遷社會中的法學方法，頁227-244，臺北：元照。[黃舒芃（2009），Dogmatik und Interdisziplinarität im Verfassungsrecht – Zum Rezeptionswandel in der taiwanischen Verfassungswissenschaft, 收於：變遷社會中的法學方法，頁201-225，臺北：元照。]
- 楊鴻烈（1967），中國法律發達史，臺1版，臺北：臺灣商務印書館。
- 葉俊榮（1999年），法律學門成就評估與發展，科學發展月刊，27卷6期，頁607-613。
- 葉俊榮編（2009），法治的開拓與傳承：翁岳生教授的公法世界，臺北：元照。
- 葉龍彥（1974），清末民初之法政學堂（1905-1919），中國文化學院史學研究所博士論文。
- 詹森林（2011），《臺大法學論叢》與臺灣民法學說、實務及立法之發展，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1595-1624。
- 雷震（1957），制憲述要，香港：友聯出版社。
- 管中閔、于若蓉（2000），「臺灣社會科學引文索引」資料庫的建置概況，人文與社會科學簡訊，3卷2期，頁66-70。
- 臺灣省行政長官公署民政處編（1946），臺灣民政（第一輯），臺

北：自版。

褚劍鴻（1954），刑事訴訟法論，臺北：大東。

趙琛（1946），行政法總論，新1版，上海：會文堂新記書局。

劉恆姝（2004），日治與國治政權交替前後台籍法律人之研究，收於：林山田教授退休祝賀論文編輯委員會編，戰鬥的法律人：林山田教授退休祝賀論文集，頁587-637，臺北：林山田教授退休祝賀論文編輯委員會。

——（2005），從知識繼受與學科定位論百年來台灣法學教育之變遷，國立臺灣大學法律學研究所博士論文。

劉寶東（2006），法學家王寵惠：生平・著述・思想，收於：胡文俊編，王寵惠與中華民國，頁100-121，廣州：廣東人民出版社。

樓桐孫（1953），法學通論，臺2版，臺北：正中書局。

歐素瑛（2006），傳承與創新——戰後初期臺灣大學的再出發（1945-1950），臺北：台灣古籍。

歐陽谿（1937），法學通論，6版，上海：會文堂新記書局。

潘公展（1938），戰時政治制度，上海：正中書局。

——（2006），本叢書發刊旨趣，收於：全國圖書館文獻縮微複製中心編，抗日戰爭時期中國國情史料匯編（13），復刻版，頁3-4，北京：全國圖書館文獻縮微複製中心。

蔡桓文（2007），國家法與原住民族習慣規範之衝突與解決，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

蔡樞衡（2005），中國法理自覺的發展，北京：清華大學出版社。

鄭松筠（原署名「鄭雪嶺」）（1921），就民商法施行而言，臺灣青年，3卷4號（漢文之部），頁17-21。

鄭政誠（2005），臺灣大調查：臨時臺灣舊慣調查會之研究，臺北：博揚文化。

鄭梓（1994），戰後臺灣的接收與重建——臺灣現代史研究論集，臺北：新化圖書。

- 鄭麗玲（2011），戰時體制時期臺北帝大的「學生生活調查」，臺灣風物，61卷1期，頁41-84。
- 賴澤涵、黃富三、黃秀政、吳文星、許雪姬（1994），二二八事件研究報告，臺北：時報文化。
- 錢端升等（1946），民國政制史，增訂2版，上海：商務印書館。
- 薛化元（1993），民主憲政與民族主義的辯證發展——張君勱思想研究，臺北：稻禾。
- 薛化元、陳翠蓮、吳鯤魯、李福鐘、楊秀菁（2003），戰後臺灣人權史，臺北：國家人權紀念館籌備處。
- 謝在全（1989），《民法物權論》，臺北：自版。
- 韓秀桃（2003），司法獨立與近代中國，北京：清華大學出版社。
- 韓忠謨（1955），刑法原理，臺北：自版。
- （1962），法學緒論，臺北：自版。
- 薩孟武（1950），論立法權的運用，自由中國，2卷12期，頁5-8。
- （1952），論修改憲法與解釋憲法，自由中國，7卷2期，頁4-7。
- （1958），由出版法談到委任命令及自由裁量，自由中國，19卷2期，頁12-13。
- 龐德（1967），改進中國法律的初步意見，收於：張文伯編，龐德學述，頁141-154，臺北：中華大典編印會。
- （1967），中國法律教育改進方案，收於：張文伯編，龐德學述，頁161-190，臺北：中華大典編印會。
- 蘇永欽（1996），台灣的社會變遷與法律學的發展，收於：施茂林編，當代法學名家論文集——慶祝法學叢刊創刊四十週年，頁551-582，臺北：法學叢刊雜誌社。
- （2003），法律作為一種學問，月旦法學雜誌，98期，頁178-182。
- 蘇國賢、呂妙芬、章英華、黃寬重（2013），學術自主與控管之間，臺北：國立臺灣大學出版中心。

鶴見俊輔著，邱振瑞譯（2008），戰爭時期日本精神史（1931-1945），臺北：行人出版社。[鶴見俊輔（2001），戰時期日本の精神史——1931-1945年，東京：岩波書店。]

2. 外文部分

(1) 日文

- 姉齒松平（1923），契約解除に關する諸問題，臺法月報，17卷10號，頁28-35。
- （1923），契約解除に關する諸問題，臺法月報，17卷11號，頁20-28。
- （1923），契約解除に關する諸問題，臺法月報，17卷12號，頁38-48。
- （1924），契約解除に關する諸問題，臺法月報，18卷1號，頁42-48。
- （1924），契約解除に關する諸問題，臺法月報，18卷2號，頁32-43。
- （1924），不當利得の效果，臺法月報，18卷6號，頁44-50。
- （1924），不當利得の要件に關して，臺法月報，18卷4號，頁22-37。
- （1924），不當利得の要件に關して，臺法月報，18卷5號，頁54-66。
- （1924），臺灣特例大正十一年勅令第四百七號第八條論，臺法月報，18卷8號，頁53-62。
- （1926），大正十一年勅令第四百七號第十六條に關する疑問，臺法月報，20卷6號，頁6-24。
- （1938），本島人ノミニ關スル親族法並相續法ノ大要，臺北：臺法月報發行所。

- (1938), 祭祀公業並臺灣ニ於ケル特殊法律ノ研究, 改訂版, 東京: 東都書籍。
- 有水常次郎 (1920), 無登記墾耕の効力に就きて, 臺法月報, 14卷5號, 頁25-31。
- 安藤靜 (1904), 北部臺灣に於ける共有に關する舊慣, 臺灣慣習記事, 4卷6號, 頁19-29。
- (1904), 北部臺灣に於ける共有に關する舊慣, 臺灣慣習記事, 4卷7號, 頁14-23。
- (1904), 北部臺灣に於ける業主權の限界に關する舊慣, 臺灣慣習記事, 4卷12號, 頁11-19。
- (1905), 北部臺灣に於ける業主權の限界に關する舊慣, 臺灣慣習記事, 5卷1號, 頁15-24。
- (1907), 臺灣に於ける共有舊慣, 臺灣慣習記事, 7卷7號, 頁1-12。
- (1907), 臺灣に於ける共有舊慣, 臺灣慣習記事, 7卷8號, 頁26-38。
- 飯岡隆 (1933), 行政裁判法を臺灣に實施す可し, 臺法月報, 27卷6號, 頁1-7。
- (1942), 戰時下の工業所有權に關する法令, 臺法月報, 36卷2號, 頁31-43。
- (1942), 戰時下の工業所有權に關する法令, 臺法月報, 36卷3號, 頁12-28。
- (1942), 戰時下の工業所有權に關する法令, 臺法月報, 36卷4號, 頁1-9。
- (1942), 戰時下の工業所有權に關する法令, 臺法月報, 36卷5號, 頁33-38。
- (1942), 戰時下の工業所有權に關する法令, 臺法月報, 36卷6號, 頁6-14。
- (1942), 戰時下の工業所有權に關する法令, 臺法月報,

36卷7號，頁5-10。

石坂音四郎（1910），臺灣に於ける土人法制定の必要，法院月報，4卷1號，頁45-57。

——（1910），臺灣に於ける土人法制定の必要，法院月報，4卷2號，頁25-35。

井出季和太（1997）（1937），臺灣治績志，復刻版，臺北：南天。

岩澤彰二郎（1920），未登記墾耕と無登記墾耕，臺法月報，14卷7號，頁1-14。

——（1920），未登記墾耕と無登記墾耕，臺法月報，14卷8號，頁6-16。

——（1920），未登記墾耕と無登記墾耕，臺法月報，14卷9號，頁9-20。

——（1920），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，14卷5號，頁4-24。

——（1920），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，14卷6號，頁6-16。

——（1920），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，14卷10號，頁9-16。

——（1920），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，14卷11號，頁7-15。

——（1921），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，15卷2號，頁7-11。

——（1921），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，15卷3號，頁2-6。

——（1921），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，15卷4號，頁6-10。

——（1921），臺灣に於ける不動産物權に付て，臺法月報，15卷5號，頁7-19。

——（1924），『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁

- 判權に關する研究，臺法月報，18卷5號，頁2-31。
- （1924），『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷6號，頁12-35。
- （1924），『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷7號，頁2-31。
- （1924），『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷8號，頁15-43。
- （1924），『判決請求權』を論ず：權利保護理論及實體的裁判權に關する研究，臺法月報，18卷9號，頁2-41。
- 上内恒三郎（1906），支那法系の法制及慣習の認めたる財産制，臺灣慣習記事，6卷1號，頁1-7。
- （1906），支那法系の法制及慣習の認めたる財産制，臺灣慣習記事，6卷2號，頁1-7。
- （1906），支那法系の法制及慣習の認めたる財産制，臺灣慣習記事，6卷4號，頁1-9。
- （1908），本島相續制度の大要，法院月報，2卷10號，頁67-76。
- （1909），合股の舊慣，法院月報，3卷2號，頁47-56。
- （1909），合股の舊慣，法院月報，3卷6號，頁49-65。
- （1909），合股の舊慣，法院月報，3卷9號，頁60-68。
- （1924），捜査上の強制處分手續，臺法月報，18卷3號，頁2-18。
- （1924），捜査上の強制處分手續，臺法月報，18卷4號，頁2-10。
- （1924），捜査上の強制處分手續，臺法月報，18卷5號，頁31-44。
- （1924），捜査上の強制處分手續，臺法月報，18卷6號，頁35-43。
- （1930），我が國體に就て，臺法月報，24卷1號，頁2-10。

- (1930), 我が國體に就て, 臺法月報, 24卷2號, 頁2-10。
 - (1930), 我が國體に就て, 臺法月報, 24卷4號, 頁2-13。
 - (1930), 我が國體に就て, 臺法月報, 24卷5號, 頁2-7。
 - (1930), 我が國體に就て, 臺法月報, 24卷6號, 頁2-8。
 - (1935), 國體と國民の責任, 臺法月報, 29卷10號, 頁1-11。
 - (1935), 國體と國民の責任, 臺法月報, 29卷11號, 頁13-21。
 - (1935), 國體と國民の責任, 臺法月報, 29卷12號, 頁3-9。
 - (1936), 國體と國民の責任, 臺法月報, 30卷2號, 頁1-9。
 - (1936), 國體と國民の責任, 臺法月報, 30卷3號, 頁33-36。
 - (1936), 國體と國民の責任, 臺法月報, 30卷4號, 頁9-12。
 - (1936), 國體と國民の責任, 臺法月報, 30卷5號, 頁5-13。
 - (1936), 國體と國民の責任, 臺法月報, 30卷6號, 頁1-10。
 - (1936), 國體と國民の責任, 臺法月報, 30卷9號, 頁1-9。
 - (1936), 國體と國民の責任, 臺法月報, 30卷10號, 頁1-9。
 - (1937), 國體と國民の責任, 臺法月報, 31卷2號, 頁1-8。
 - (1937), 國體と國民の責任, 臺法月報, 31卷3號, 頁1-10。
 - (1937), 國體と國民の責任, 臺法月報, 31卷5號, 頁1-5。
 - (1937), 國體と國民の責任, 臺法月報, 31卷6號, 頁1-7。
 - (1937), 國體と國民の責任, 臺法月報, 31卷8號, 頁1-7。
 - (1937), 國體と國民の責任, 臺法月報, 31卷9號, 頁1-5。
 - (1937), 國體と國民の責任, 臺法月報, 31卷10號, 頁1-9。
- 潮見俊隆 (1975), 末弘巖太郎, 收於: 潮見俊隆、利谷信義編, 日本の法学者, 頁335-365, 東京: 日本評論社。
- 王泰升著, 鈴木賢、松田恵美子、西英昭、黃詩淳、陳宛妤、松井直之、阿部由理香譯 (2014), 台灣法における日本の要素, 臺北: 國立臺灣大學出版中心。

- 岡野才太郎（1906），生蕃人の國法上の地位，臺灣慣習記事，6卷11號，頁1-13。
- 岡松參太郎（1901），大租權の法律上の性質，臺灣慣習記事，1卷1號，頁4-14。
- （1901），大租權の法律上の性質，臺灣慣習記事，1卷3號，頁1-13。
- （1901），親族相續，臺灣慣習記事，1卷4號，頁25-33。
- （1901），親族相續，臺灣慣習記事，1卷8號，頁12-24。
- （1901），親族相續，臺灣慣習記事，1卷9號，頁1-19。
- （1901），親族相續，臺灣慣習記事，1卷10號，頁18-37。
- （1903），臺灣現時の法律，臺灣慣習記事，3卷1號，頁1-9。
- （1910），敘言，收於：臨時臺灣舊慣調查會編，臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書——臺灣私法（第一卷上），敘言頁1-8，神戶：自版。
- （1921），敘言，收於：臺灣總督府蕃族調查會編，臺灣蕃族慣習研究（第壹卷），敘言頁1-10，臺北：自版。
- 織田萬（1905），臨時臺灣舊慣調查會第一部報告書——清國行政法（第壹卷），神戶：臨時臺灣舊慣調查會。
- （1914），臨時臺灣舊慣調查會第一部報告書——清國行政法（第壹卷上），東京：臨時臺灣舊慣調查會。
- 清輝生（1933），會社の問題，民眾法律，2卷4號（和文），頁35-39。
- 吳豪人（1999），「台灣法史」の可能性：法社会的・法思想史的試論，京都大学大学院法学研究科博士論文。
- （2006），植民地の法学者たち——「近代」パライソの落とし子，收於：酒井哲哉編，「帝国」日本の学知（第1卷）——「帝国」編成の系譜，頁123-169，東京：岩波書店。
- 小島由道（1923），親族相續に關する慣習，臺法月報，17卷1號，頁95-111。

—— (1923), 親族相續に關する慣習, 臺法月報, 17卷3號, 頁53-59。

—— (1923), 親族相續に關する慣習, 臺法月報, 17卷4號, 頁57-65。

—— (1923), 親族相續に關する慣習, 臺法月報, 17卷6號, 頁64-72。

後藤新平 (1901), 臺灣經營上舊慣制度の調査を必要とする意見, 臺灣慣習記事, 1卷5號, 頁24-38。

—— (1901), 臺灣經營上舊慣制度の調査を必要とする意見, 臺灣慣習記事, 1卷6號, 頁25-35。

後藤武秀 (2009), 台湾法の歴史と思想, 京都: 法律文化社。

後藤和佐二 (1921), 無登記賤耕と承賤者の權利, 臺法月報, 15卷5號, 頁1-5。

—— (1921), 無登記賤耕と承賤者の權利, 臺法月報, 15卷6號, 頁3-6。

—— (1921), 無登記賤耕と承賤者の權利, 臺法月報, 15卷7號, 頁9-13。

—— (1921), 無登記賤耕と承賤者の權利, 臺法月報, 15卷8號, 頁10-14。

小林里平 (1902), 清國政府時代に於ける臺灣司法制度, 臺灣慣習記事, 2卷12號, 頁12-28。

—— (1903), 清國政府時代に於ける臺灣司法制度, 臺灣慣習記事, 3卷2號, 頁10-25。

—— (1903), 清國政府時代に於ける臺灣司法制度, 臺灣慣習記事, 3卷3號, 頁1-14。

—— (1903), 保甲制度, 臺灣慣習記事, 3卷5號, 頁1-15。

—— (1903), 保甲制度, 臺灣慣習記事, 3卷6號, 頁1-13。

—— (1903), 保甲制度, 臺灣慣習記事, 3卷7號, 頁1-14。

—— (1903), 保甲制度, 臺灣慣習記事, 3卷8號, 頁1-16。

- (1903), 保甲制度, 臺灣慣習記事, 3卷9號, 頁13-32。
- (1903), 保甲制度, 臺灣慣習記事, 3卷11號, 頁22-29。
- (1908), 本島親族制度の大要, 法院月報, 2卷10號, 頁49-54。
- 鈴木宗言 (1901), 臺灣の舊訴訟法, 臺灣慣習記事, 1卷2號, 頁1-17。
- (1901), 臺灣の舊訴訟法, 臺灣慣習記事, 1卷3號, 頁14-23。
- (1901), 臺灣の舊訴訟法, 臺灣慣習記事, 1卷4號, 頁1-25。
- (1904), 危急存亡, 臺灣慣習記事, 4卷7號, 頁78-83。
- (1907), 慣習研究會解散に就て一言す, 臺灣慣習記事, 7卷8號, 頁3-5。
- 蘇樹發 (1937), 法庭詭辯, 民眾法律, 1卷3號 (和文), 頁49-51。
- 園部敏 (1943), 行政法概論——特に臺灣行政法規を顧慮して——, 改訂版, 臺北: 臺灣出版文化。
- 戴炎輝 (1937), 近世支那並臺灣の養子法, 臺法月報, 31卷7號, 頁49-63。
- (1937), 近世支那並臺灣の養子法, 臺法月報, 31卷8號, 頁67-77。
- (1937), 近世支那並臺灣の養子法, 臺法月報, 31卷9號, 頁15-25。
- (1937), 近世支那並臺灣の養子法, 臺法月報, 31卷10號, 頁35-39。
- (1937), 近世支那並臺灣の養子法, 臺法月報, 31卷11號, 頁17-21。
- (1938), 招婿婚に就て, 臺法月報, 32卷3號, 頁21-27。
- (1938), 招婿婚に就て, 臺法月報, 32卷4號, 頁22-30。
- (1938), 招婿婚に就て, 臺法月報, 32卷5號, 頁30-37。

- (1938), 招婿婚に就て, 臺法月報, 32卷6號, 頁36-43。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷3號, 頁33-41。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷4號, 頁28-38。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷5號, 頁33-45。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷6號, 頁31-43。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷7號, 頁23-28。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷8號, 頁36-41。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷9號, 頁26-34。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷10號, 頁49-51。
- (1939), 臺灣舊慣上の合會(賴母子講), 臺法月報, 33卷11號, 頁37-40。
- 田井輝雄(戴炎輝)(1945), 臺灣の家族制度と祖先祭祀團體, 收於: 金關丈夫編, 台灣文化論叢(第二輯), 頁181-264, 臺北: 清水書店。
- 臺法月報發行所編(1923), 臺法月報, 17卷1號: 民法商法施行紀念特大號, 頁4-111。
- 臺灣慣習研究會(1903), 再び本會の博覽會出品に就て, 臺灣慣習記事, 3卷2號, 頁85-89。
- 高田富藏(1908), 本島婚姻制度の大要, 法院月報, 2卷10號, 頁54-60。
- 高見澤磨、鈴木賢(2010), 中国にとって法とは何か——統治の

道具から市民の権利へ，東京：岩波書店。

瀧野種孝（1911），合股令案に就て，臺法月報，5卷3號，頁37-41。

伴野喜四郎（1929），除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷1號，頁2-9。

——（1929），除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷2號，頁2-17。

——（1929），除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷3號，頁2-17。

——（1929），除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷4號，頁14-21。

——（1929），除外例を設けて民法親族篇相續篇を本島人に適用するの急務なることを論ず，臺法月報，23卷5號，頁2-9。

中生勝美（2000），ドイツ比較法学派と台湾旧慣調査，收於：宮良高弘、森謙二編，歴史と民族における結婚と家族——江守五夫先生古稀記念論文集——，頁373-400，東京：第一書房。

中島利郎、宋宜靜編（1999），『台法月報』総目録，東京：綠蔭書房。

長嶺茂（1911），合股令修正意見，臺法月報，5卷4號，頁48-52。

西英昭（2009），『臺灣私法』の成立過程——テキストの層位学的分析を中心に，福岡：九州大学出版会。

野津三次郎（1911），合股令に對する私見，臺法月報，5卷4號，頁44-48。

——（1911），再び合股令案に就て，臺法月報，5卷6號，頁82-85。

春山明哲（1993），法学博士・岡松參太郎と台湾，收於：台湾近現代史研究会編，台湾近現代史研究Ⅱ，第6號，復刻版，頁197-216，東京：綠蔭書房。

- （1993），台湾旧慣調査会と立法構想——岡松參太郎による調査と立案を中心に——，收於：台湾近現代史研究会編，台湾近現代史研究Ⅱ，第6號，復刻版，頁81-114，東京：綠蔭書房。
- 坂野正高（1975），織田萬，收於：潮見俊隆、利谷信義編，日本の法学者，頁129-147，東京：日本評論社。
- 福島正夫（1995），岡松參太郎博士の台湾旧慣調査と、華北農村慣行調査における末弘巖太郎博士，收於：戒能通厚編，福島正夫著作集（第六卷）——比較法，頁389-424，東京：勁草書房。
- 藤井乾助（1906），生蕃人の國法上の地位，臺灣慣習記事，6卷12號，頁1-28。
- （1908），本島養子制度の大要，法院月報，2卷10號，頁60-67。
- （1913），臺灣の舊慣立法に就て，臺法月報，7卷6號，頁31-35。
- 増田福太郎（1938），天岩戸の精神と帝國憲法（法理小稿・五）——寛博士の示教——，臺法月報，32卷11號，頁1-10。
- （1938），所謂天皇機關說の內在的批判（法理小稿・六）——正木教授の業績——，臺法月報，32卷12號，頁6-13。
- （1939），皇學としての憲法學（法理小稿・七）——憲法學方法論批判——，臺法月報，33卷2號，頁1-10。
- （1957），未開社會における法の成立，岡山：岡山大学法経学会。
- 宮平真弥（2004），中村哲先生の植民地法研究について，沖繩文化研究，31期，頁523-542。
- 民眾法律新報社（1933），假差押申請，民眾法律，2卷4號（和文），頁39-50。
- 安井勝次（1907），生蕃人の國法上の地位，臺灣慣習記事，7卷1

號，頁1-27。

安平政吉（1940），臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷2號，頁1-21。

——（1940），臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷3號，頁4-29。

——（1940），臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷4號，頁3-18。

——（1940），臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷6號，頁1-24。

——（1940），臺灣高砂族の犯罪と刑罰，臺法月報，34卷7號，頁1-19。

山田示元（1911），臺灣合股令案に付て，臺法月報，5卷6號，頁76-82。

——（1911），臺灣合股令案に就て（二），臺法月報，5卷7號，頁60-67。

——（1915），舊慣立法に就いて，臺法月報，9卷5號，頁31-43。

山根幸夫（1967），清国行政法解説，收於：山根幸夫編，清國行政法索引，解説頁1-21，東京：大安。

——（1976），臨時台湾旧慣調査会の成果，收於：論集——近代中国と日本，頁79-122，東京：山川出版社。

山本留藏（1901），臺灣に於て流質となるべき場合，臺灣慣習記事，1卷11號，頁16-31。

——（1902），典より生ずる法律關係は果して之を條件付賣買と見るべきや，臺灣慣習記事，2卷8號，頁11-23。

——（1902），典より生ずる法律關係は果して之を條件付賣買と見るべきや，臺灣慣習記事，2卷9號，頁6-15。

——（1904），典主は債權的關係に於て原典價銀の辨濟請求權利を有するものに非らず，臺灣慣習記事，4卷9號，頁1-13。

——（1908），本島土地に關する權利の大要，法院月報，2卷10

號，頁37-49。

臨時臺灣舊慣調查會編（1910），臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書——臺灣私法（第一卷上），神戸：自版。

林呈祿（1922），民法親族規定を臺灣人に適用する法案の疑義，臺灣青年，3年6號（和文之部），頁21-35。

渡邊洋三（1979），日本ファシズム法体制・総論，收於：東京大学社会科学研究所編，ファシズム期の国家と社会（4）戦時日本の法体制，頁3-70，東京：東京大学出版会。

渡邊里樹（1926），民法第六百二條の期間を超えたる贖耕契約の民法施行後に於ける效力，臺法月報，20卷11號，頁6-19。

——（1926），債權の競合は破産宣告の要件なりや，臺法月報，20卷2號，頁19-29。

渡部正綱（1911），合股令案に就て，臺法月報，5卷5號，頁60-64。

(2) 西文

Chen, Lung-chu. 2016. *The U.S.-Taiwan-China Relationship in International Law and Policy*. New York, NY: Oxford University Press.

Chen, Lung-chu, and W. Michael Reisman 1972. Who Owns Taiwan: A Search for International Title. *Yale Law Journal* 81:599-671.

Henderson, Dan Fenno. 1968. Law and Political Modernization in Japan. Pp. 387-456 in *Political Development in Modern Japan*, edited by Robert E. Ward. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Lo, Chang-fa. 2006. *The Legal Culture and System of Taiwan*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Okamatsu, Santaro. 1971. *Provisional Report on Investigation of Law and Customs in the Island of Formosa*. Taipei: Ch'eng Wen.

Wang, Tay-sheng. 1997. Chapter 4: Taiwan. Pp. 124-161 in *Asian Legal Systems: Law, Society and Pluralism in East Asia*, edited by Poh-

Ling Tan. Sydney: Butterworths.

———. 2013. The Modernization of Civil Justice in Colonial Taiwan, 1895-1945. *Zeitschrift für Japanisches Recht / Journal of Japanese Law* 36:95-116.

Yeh, Jiunn-rong. 2016. *The Constitution of Taiwan: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.

The Legal Science in Taiwan: A Historical Perspective

*Tay-Sheng Wang**

Abstract

Taiwan could not develop modern knowledge of law until she was ruled by Japanese colonialists, who had received modern law and legal science from the West before acquiring Taiwan. During the former period of Japanese rule, “old customs jurisprudence,” incorporating legal practice in Taiwan, was shaped to carry out the Japanese “special rule” policy toward Taiwan. After the policy of the colonial governance turned to “the extension of mainland” in 1919, the legal science in colonial Taiwan was nothing but a branch of prewar Japanese legal science. The first institute for modern legal education in Taiwan was established in 1928 and was named the Legal Division, College of Liberal Arts and Political Science, Taihoku Imperial University. This division paid more attention to Japanese laws and modern jurisprudence than to legal issues in Taiwan. Some Taiwanese dissidents advocated “Taiwanese jurisprudence” in order to protect the identity and interests of the Taiwanese; however, they were excluded from the academic circle of colonial Taiwan. In fact, few Taiwanese jurists became active in colonial academic circles. In the late period of Japanese rule, the Fascist approach gradually dominated the legal community of Taiwan, who had to follow in the steps of wartime Japan.

After World War II, the Republic of China (ROC) legal system, derived from Republican China became effective in Taiwan. The

* NTU Chair Professor, College of Law, National Taiwan University; Joint Appointment Researcher Fellow, Institute of Taiwan History and Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

majority of the first-generation legal scholars in post-war Taiwan came from Mainland China, with the experiences of legal science in Republican China. The minority were those people who were native Taiwanese, with the experiences of legal science in colonial Taiwan. The contents of Taiwan's legal science then were largely the statutory interpretation of the ROC laws; however, these legal scholars, regardless of their ethnic or occupational background, were considerably influenced by pre-war Japanese legal science. After the mid-1960s, the second-generation legal scholars who were teachers in law schools brought liberal and democratic jurisprudence from Europe or Japan to Taiwan. They criticized tactfully Taiwan's Fascist positive law made by the KMT regime and deepened the quality of given statutory interpretations. In the mid-1980s, the third generation of legal scholars emerged. Accompanying the liberalization and democratization of Taiwan in the 1990s, Taiwan's legal scholars paid more attention to reform in legislation, and sometimes played a leading role in reforming the law. In addition, they began to cooperate with scholars who were trained in non-legal disciplines, and to publish their academic works in diverse styles. In the 2000s, the fourth generation of legal scholars emerged. Taiwan's legal scholars do not merely receive foreign legal theories any more, but take different approaches to deal with local legal issues with diversity in sources. They have also made their voices heard in the international community to address the legal experiences of Taiwan.

In conclusion, the knowledge of legal science derived from the modern West was brought to Taiwan by foreign regimes from pre-war Japan and Republican China, and thus the legal science in Taiwan was initially not shaped for Taiwan's people. After absorbing the legal knowledge mentioned above, Taiwanese legal scholars have continuously received legal science in post-war Europe, the U.S., and post-war Japan, and finally developed a system of legal science with characteristics of Taiwan so as to share their ideas with other scholars in the international community.

KEYWORDS: legal science, old customs, pre-war Japan, colony, reception, the extension of mainland, fascist, post-war Taiwan, Republican China.

